

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

|                |
|----------------|
| Reg.nº 1586/12 |
|----------------|

/// la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre del año dos mil doce, se reúne la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Eduardo R. Riggi como Presidente y los doctores Mariano H. Borinsky y Liliana E. Catucci como Vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncin, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto contra la decisión obrante a fojas 25.612/25.813 de la presente causa n 13.085/13.049 del registro de esta Sala, caratulada:"Albornoz, Roberto Heriberto y otros s/recurso de casación". El Ministerio Público Fiscal es representado por el señor Fiscal General doctor Ricardo Gustavo Wechsler. Los querellantes: 1) Fernando Carlos Araldi (querellante) por Diana Irene Oesterheld y Raul Carlos Araldi, apoderado Dr. Daniel Adrián Mendivil; 2) Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y FADETUC, (Asociación Familiares de Desaparecidos de Tucumán) (querellantes) por Marta Coronel y Rolando Coronel, apoderados Dres. Bernardo Lobo Bugeau (Secretaría de Derechos Humanos), Dres. Emilio Guagnini y Julia Vitar (FADETUC); 3) Joaquín Ariño (h) (querellante) por Joaquín Ariño, apoderada Dra. Laura Figueroa; 4) Silvia Magdalena Frías de Díaz (querellante) por Hugo Alberto Díaz, apoderada Dra. Laura Figueroa; 5) Irma Noemí

Argañaraz (querellante) por Carlos Roman Apaza, apoderada Dra. Laura Figueroa, 6) Darío Abdala como Presidente de ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) (querellante) y Pablo Argañaraz (querellante) por Graciela Bustamante de Argañaraz, apoderada, Dra. Valentina Garcia Salemi y Dr. Daniel Weisemberg; 7) Pedro Ramos (querellante) por Eduardo Ramos y Alicia Cerrota de Ramos, apoderado Dr. Bernardo Lobo Bougeau.

La defensa del imputado Luciano Benjamín Menéndez, es ejercida por el doctor Horacio Laurindo Guerineau, la de Roberto Heriberto Albornoz por el doctor Ezequiel Avila Gallo; la de Luis Armando De Cándido y Carlos De Cándido por el Defensor Público Oficial doctor Juan Carlos Sambuceti (h).

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo: Mariano Hernán Borinsky, Eduardo R. Riggi y Liliana Elena Catucci.

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

El señor juez **doctor Mariano Hernán Borinsky** dijo:

**PRIMERO:**

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Tucumán, en la causa n° J - 29/09 de su registro, resolvió, mediante veredicto dictado en fecha 8 de julio de 2010, cuyos fundamentos fueron leídos en fecha 23 de agosto de 2010:

I) DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del requerimiento fiscal de elevación a juicio, obrante a fs. 13.840/13.870 vta., en lo que se refiere a la imputación a ROBERTO HERIBERTO ALBORNOS del delito de usurpación del inmueble de calle Frías

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

Silva N° 231 de San Miguel de Tucumán, conforme se considera (art. 166 y ccdtes. del C.P.P.N.).-

II) NO HACER LUGAR a la pretensión de las defensas técnicas de los imputados de remitir los antecedentes del testigo Domingo Antonio Jerez al Sr. Fiscal Federal a los efectos de que se investigue su posible participación en la comisión de algún delito, conforme se considera.-

III) NO HACER LUGAR al planteo de nulidad formulado por la defensa técnica de LUIS ARMANDO DE CÁNDIDO y CARLOS ESTEBAN DE CÁNDIDO respecto al reconocimiento realizado durante la audiencia por el testigo Demetrio Chamatrópulos, conforme se considera (arts. 166 y ccdtes. del C.P.P.N.).-

IV) NO HACER LUGAR a la pretensión de las querellas de remitir los antecedentes del testigo Carlos Acuña al Sr. Fiscal Federal a los efectos de que se investigue su posible participación en la comisión de los delitos de falso testimonio y/o apología del delito, conforme se considera.-

V) NO HACER LUGAR a la pretensión de la defensa de LUIS ARMANDO DE CÁNDIDO y CARLOS ESTEBAN DE CÁNDIDO de remitir los antecedentes del testigo Oscar Enrique Conte al Sr. Fiscal Federal a los efectos de que se investigue su posible participación en la comisión del delito de falso testimonio, conforme se considera.-

VI) NO HACER LUGAR al planteo de nulidad formulado por la defensa técnica de LUIS ARMANDO DE CÁNDIDO y CARLOS ESTEBAN DE CÁNDIDO respecto a la declaración testimonial de Ana Lía Marteau conforme se considera (arts. 166 y ccdtes. del C.P.P.N.).

VII) CONDENAR a LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de PRISIÓN PERPETUA e INHABILITACIÓN ABSOLUTA y PERPETUA, ACCESORIAS LEGALES por igual tiempo que el de la condena y COSTAS, por ser autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de violación de domicilio de calle Santiago del Estero N° 4000, Santiago del Estero N° 3.750, Avenida Roca N° 370, Frías Silva N° 231, Avenida Soldati N° 266, Chacabuco N° 476/478, San Lorenzo N° 1142, Blas Parera N° 252, Avenida Roca N° 713 y Fortunata García N° 1398, todos de San Miguel de Tucumán (art. 151 Código Penal) en concurso ideal (art. 54 Código Penal) con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada (art. 144 bis y 142 inc. 1º del Código Penal) en perjuicio de Marta Ángela López, Ceferina Rosa López, Juan Carlos López, Ramón Francisco López, Hugo Alberto Díaz, José Eduardo Ramos, Alicia Dora Cerrota de Ramos, Marta Coronel, Rolando Coronel, Daniel Fontanarrosa, Joaquín Ariño, Ángel Mario Garmendia y Dante Edgardo Bordón; privación ilegítima de la libertad (art. 144 bis del C.P.) en perjuicio de Diana Irene Oosterheld y Fernando Carlos Araldi; privación ilegítima de la libertad agravada (arts. 144 bis y 142 inc. 1º del Código Penal) en perjuicio de Raúl Mauricio Lechessi, Enrique Abdón Pastor Cerezo, Graciela Bustamante de Argañarás, Ricardo Torres Correa; privación ilegítima de la libertad (art. 144 bis del C.P.) en perjuicio de Adriana Cecilia Mitrovich, Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba y Carlos Román Apaza; imposición de tormentos agravada (art. 144 ter Código Penal según ley 14.616 por ser

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

ley penal más benigna) en perjuicio de Marta Ángela López, Ceferina Rosa López, Juan Carlos López, Ramón Francisco López, Hugo Alberto Diaz, Mauricio Lechessi, Diana Irene Oesterheld, José Eduardo Ramos, Alicia Dora Cerrota de Ramos, Enrique Abdón Pastor Cerezo, Adriana Mitrovich, Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba, Graciela Bustamante de Argañarás, Ricardo Torres Correa, Daniel Fontanarrosa, Joaquín Ariño, y Ángel Mario Garmendia; torturas seguida de muerte (art.144 ter del Código Penal según ley 14.616 por ser ley penal más benigna) en perjuicio de Marta Coronel y Rolando Coronel; homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes (art. 80 incs. 2, 3 y 4 del Código Penal vigente al tiempo de comisión de los hechos, conforme la ley 11.179 y a la ley 20.642) en perjuicio de Ceferina Rosa López, Juan Carlos López, Ramón Francisco López, Hugo Alberto Diaz, Mauricio Lechessi, Diana Irene Oesterheld, Raul Carlos Araldi, José Eduardo Ramos, Alicia Dora Cerrota de Ramos, Enrique Abdón Pastor Cerezo, Adriana Mitrovich, Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba, Graciela Bustamante de Argañarás, Ricardo Torres Correa, Carlos Román Apaza, Daniel Fontanarrosa, Joaquín Ariño, Angel Mario Garmendia y Dante Edgardo Bordón; todo en concurso real (art. 55 del Código Penal) calificándolos como delitos de lesa humanidad (arts. 12, 19, 29 inc 3º, 40 y 41 del Código Penal; arts. 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación), conforme se considera.

VIII) CONDENAR a ROBERTO HERIBERTO ALBORNOZ, de las

condiciones personales que constan en autos, a la pena de PRISIÓN PERPETUA e INHABILITACIÓN ABSOLUTA y PERPETUA, ACCESORIAS LEGALES por igual tiempo que el de la condena y COSTAS, por ser coautor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de organizador (art. 210 del Código Penal); por ser autor material penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio de calle Santiago del Estero N° 4000 y Santiago del Estero N° 3750 de San Miguel de Tucumán en concurso ideal (art. 54 Código Penal) con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada (arts. 144 bis y 142 inc. 1º del Código Penal) en perjuicio de Marta Ángela López, Ceferina Rosa López, Juan Carlos López, Ramón Francisco López; privación ilegítima de la libertad (art. 144 bis del C.P.) en perjuicio de Hugo Alberto Díaz, Diana Irene Oesterheld, José Eduardo Ramos, Alicia Dora Cerrota de Ramos, Enrique Abdón Pastor Cerezo, Adriana Mitrovich, Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba, Graciela Bustamante de Argañaras, Ricardo Torres Correa, Carlos Román Apaza, Marta Coronel, Rolando Coronel, Daniel Fontanarrosa, Joaquín Ariño y Dante Edgardo Bordón; autor mediato penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio Avenida Soldati N° 266, calle Chacabuco N° 476/478, San Lorenzo N° 1142, Blas Parera N° 252, Avenida Roca N° 370, Fortunata García N° 1398 y Frías Silva N° 231, todos de la ciudad de San Miguel de Tucumán; privación ilegítima de la libertad (art. 144 bis del C.P.) en perjuicio de Fernando Carlos Araldi; imposición de tormentos agravada (art. 144 ter Código Penal según ley 14.616 por ser ley penal más benigna) en perjuicio de Marta Ángela López, Ceferina Rosa López, Juan Carlos López, Ramón Francisco

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

López, Hugo Alberto Díaz, Diana Irene Oesterheld, José Eduardo Ramos, Alicia Dora Cerrota de Ramos, Enrique Abdón Pastor Cerezo, Adriana Mitrovich, Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba, Graciela Bustamante de Argañarás, Ricardo Torres Correa, Daniel Fontanarrosa y Joaquín Ariño; torturas seguida de muerte (art.144 ter del Código Penal según ley 14.616 por ser ley penal más benigna) en perjuicio de Marta Coronel y Rolando Coronel; homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes (art. 80 incs. 2, 3 y 4 del Código Penal vigente al tiempo de comisión de los hechos, conforme la ley 11.179 y a la ley 20.642) en perjuicio de Ceferina Rosa López, Juan Carlos López, Ramón Francisco López, Hugo Alberto Díaz, Diana Irene Oesterheld, Raul Carlos Araldi, José Eduardo Ramos, Alicia Dora Cerrota de Ramos, Enrique Abdón Pastor Cerezo, Adriana Mitrovich, Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba, Graciela Bustamante de Argañarás, Ricardo Torres Correa, Carlos Román Apaza, Daniel Fontanarrosa, Joaquín Ariño y Dante Edgardo Bordón; todo en concurso real (art. 55 del Código Penal) calificándolos como delitos de lesa humanidad (arts. 12, 19, 29 inc 3º, 40 y 41 del Código Penal; arts. 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación), conforme se considera.

IX) CONDENAR a LUIS ARMANDO DE CÁNDIDO, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de DIECIOCHO AÑOS DE PRISIÓN e INHABILITACIÓN ABSOLUTA y PERPETUA, ACCESORIAS LEGALES por igual tiempo que el de la condena y COSTAS, por ser coautor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita agravada (art. 210 bis

del Código Penal según ley n° 21.138) autor material penalmente responsable del delito de violación del domicilio de calle Chacabuco n° 476/478 de San Miguel de Tucumán (art. 151 Código Penal) en concurso ideal (art. 54 Código Penal) con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada (arts. 144 bis y 142 inc. 1º del Código Penal) en perjuicio de Marta y Rolando Coronel; torturas seguida de muerte (art. 144 ter del Código Penal según ley 14.616 por ser ley penal más benigna) en perjuicio de Marta Coronel y Rolando Coronel; usurpación (art. 181 del Código Penal) del inmueble de calle Chacabuco N° 476/478 de San Miguel de Tucumán; todo en concurso real (Art. 55 del Código Penal) calificándolos como delitos de lesa humanidad. (Arts. 12, 19, 29 inc 3º, 40 y 41 del Código Penal; arts. 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación), conforme se considera.

X) CONDENAR a CARLOS ESTEBAN DE CÁNDIDO, de las condiciones personales que constan en autos a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN de EJECUCIÓN CONDICIONAL, al cumplimiento de las REGLAS DE CONDUCTA que se establecen en los considerandos y COSTAS, por ser autor material penalmente responsable de la comisión del delito de usurpación (art. 181 del C.P.) del inmueble de calle Jujuy N° 1062 de San Miguel de Tucumán, de propiedad de Rolando Coronel; calificándolo como delito de lesa humanidad. (arts. 26, 27 bis inc. 1º, 2º y 8º; 29 inc. 3º; 40 y 41 del C.P. del Código Penal; arts. 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación), conforme se considera.-

XI) DIFERIR el pronunciamiento sobre la forma de cumplimiento de la pena de prisión impuesta a LUCIANO BENJAMÍN MENENDEZ para la etapa de ejecución (libro V del C.P.P.N.),

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

manteniéndose hasta esa instancia la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva vigente en autos; DISPONIÉNDOSE la custodia de la Policía Federal, prohibición de salir del país y de ausentarse de la jurisdicción sin autorización del Tribunal.

XII) REVOCAR la prisión domiciliaria de la que gozaba hasta la fecha ROBERTO HERIBERTO ALBORNOZ, ORDENANDO su inmediato traslado y alojamiento en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza, dando cumplimiento con lo normado por los arts. 66, 68, 144 y 146 de la ley 24.660, conforme se considera.

XIII) DISPONER la inmediata detención en prisión preventiva de LUIS ARMANDO DE CÁNDIDO, ORDENANDO su traslado y alojamiento en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza, dando cumplimiento con lo normado por los arts. 66, 68, 144 y 146 de la ley 24.660, conforme se considera (art. 494 2° párrafo del C.P.P.N.).

XIV) IMPONER las COSTAS por la actuación de los letrados querellantes en representación de las víctimas, a los condenados. IMPONER las COSTAS por la actuación de los letrados querellantes en representación de las asociaciones (ANDHES y FA.DETUC.) y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el orden causado (art. 403 del C.P.P.N.). -vid. fs. 25.810 vta./25.813 vta.-

Contra dicha decisión la defensa técnica de Roberto Heriberto Albornoz, representada por el doctor Ezequiel J. Avila Gallo interpuso recurso de casación a fs. 25836/25844 vta. el que, concedido por el a quo a fs. 26382/26383 vta., fue mantenido oportunamente a fs. 26.036.

A fs. 25.853/25.891 vta. el Defensor Público Oficial,

doctor Ciro Vicente Lo Pinto por la defensa técnica de los imputados Luis Armando de Cándido y Carlos De Cándido dedujo recurso de casación, el que concedido por el *a quo* a fs.26382/26383 vta. fue mantenido a fs. 26.035.

A fs. 25.915/25.944 vta. el doctor Horacio L. Guerineau por la defensa técnica del imputado Luciano Benjamín Menéndez dedujo recurso de casación, el que concedido por el *a quo* a fs. 26.382/26.383 vta., fue mantenido a fs. 26.055.

A fs. 25.892/25.914 vta. el señor representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Leopoldo Peralta Palma dedujo recurso de casación el que, queja mediante fue finalmente concedido por esta Cámara a fs. 26.414, siendo mantenido a fs. 26.417.

Durante el término de oficina, se presentó el Fiscal General, doctor Ricardo Weschler, quien en base a los fundamentos obrantes en su dictamen de fs. 26.444/26.463 vta., solicitó el rechazo de los recursos de casación interpuestos por las defensas técnicas de los imputados y asimismo petitionó que se haga lugar al recurso deducido por el Fiscal General subrogante doctor Leopoldo Oscar Peralta Palma.

A fs. 26.468/26.483 vta. se presentó en el mismo término, el Defensor Público Oficial, doctor Juan Carlos Sambuceti (h), ejerciendo la defensa de los imputados Luis Armando De Cándido y Carlos De Cándido y solicitó con fundamento en las consideraciones vertidas en su escrito se haga lugar al recurso incoado por el Defensor Público Oficial doctor Ciro Vicente Lo Pinto y se rechace el recurso fiscal.

Superada la etapa prevista por el art. 468 del CPPN, oportunidad en la que la Defensa Oficial de Luis Armando de Cándido y Carlos Esteban De Cándido y el Fiscal General, doctor Ricardo Gustavo Weschler presentaron breves notas y, habiéndose efectuado las audiencias de *visu* en los términos del art. 41 del CP, las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas (cfr. fs. 26.570 y 26.571, respectivamente).

**SEGUNDO:**

**I- Recurso del fiscal.**

El libelo recursivo fue encauzado bajo los dos motivos previstos en el art. 456 del CPPN.

1- En primer término, el representante de la vindicta pública se agravió de que el tribunal no haya considerado, ni en la parte resolutive ni en sus considerandos, el pedido de pérdida del grado militar del condenado Luciano Benjamín Menéndez, que fuera formulado oportunamente por esa parte.

Principió su crítica al decisorio recordando el tenor del art. 12 del CP para detenerse en el análisis de la ley 26.394 -que, a su entender, resulta aplicable a la especie por ser más benigna- que derogó el Código de Justicia Militar y estableció el nuevo régimen disciplinario de los militares que incurran en alguna falta de conducta.

Refirió que el art. 13 inc. 23 *ibídem* prevé que constituye falta gravísima la comisión de un delito cuya pena máxima sea superior a un año, aclarando que este tipo de falta se encuentra penada, según el art. 14, con la destitución (pena mayor).

Señaló que el fondo de la cuestión, en lo que hace a la sanción que se solicita, es tratado de modo similar en ambas legislaciones, tanto en la ley 14.029 vigente al momento de los hechos, como en la actual ley 26.394.

Recordó que este planteo ya fue tenido en cuenta en la causa 13/84 en cuya sentencia se estableció, al tratar las sanciones accesorias, que la naturaleza y duración de las penas fijadas conduce a la imposición de sanciones accesorias previstas tanto en la ley común como en la militar (arts. 12 del CP y 538 del CJM) para todos los condenados.

Por último, sostuvo que resulta un contrasentido y hasta un absurdo que un condenado a prisión perpetua por ser penalmente responsable de la comisión de delitos de lesa humanidad durante el desempeño de sus funciones militares y en franca rebelión contra la Constitución Nacional y las leyes de la República siga ostentando el grado de General de la Nación, el estado militar y que continúe recibiendo tales tratamientos.

2- Bajo el título errónea calificación legal en el caso de Luis Armando De Cándido señaló que, sin bien coincide con el tribunal en considerar que las torturas padecidas por las víctimas de esta causa se verificaron desde el momento mismo de su detención, oportunidad en la que fueron sometidas no sólo a torturas físicas sino también psicológicas, discrepa con la calificación de la conducta desplegada por Luis Armando De Cándido pues no se condice con las probanzas de autos ni con la gravedad de los delitos que perjudicaron a Rolando y Marta Coronel.

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

Manifestó que un análisis detenido en la sucesión de los ilícitos perpetrados y ventilados en esta causa permite afirmar que las conductas realizadas describen acabadamente la secuencia secuestros-torturas-desapariciones, a la que el tribunal hace referencia en su explicación de la desaparición forzada de personas y que siguiendo tal razonamiento, la última parte de dicha secuencia estaría faltando respecto de Marta y Rolando Coronel, es decir, que su desaparición forzada estaría impune.

En tal orden de ideas, sostuvo que si se condena a una persona como autor material de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos, cuanto menos, en consideración al lugar que ocupaba Luis De Cándido dentro de la estructura policial y del SIC, cabría reprocharle también la negativa de revelar la suerte o paradero de la familia Coronel.

Adujo que el tribunal para fundamentar su posición se apoya exclusivamente en el testimonio de Oscar Conte, de cuyo contenido surge claramente que Rolando Coronel falleció en el preciso momento en el que era trasladado en un móvil de la policía provincial luego de haber sido secuestrado, agregando el recurrente que también está probado que su cuerpo nunca más apareció, por lo que -concluyó- la calificación legal que realiza el tribunal no refleja el devenir de los acontecimientos tal cual sucedieron.

A su entender, si se tiene por acreditado -como lo hizo el tribunal- que Luis Armando De Cándido era integrante de

la patota que se encargaba de secuestrar y de torturar a las víctimas y que en especial integró el grupo de tareas que concretó los injustos de que fueran víctimas Marta Coronel y Rolando Coronel, corresponde condenar al antes mentado por la desaparición forzada de Rolando y Marta Coronel; esto es, homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más partícipes y con el fin de lograr impunidad.

Señaló que con mucho menos prueba se tuvieron por acreditados los homicidios de las veinte personas a las que aludió en su escrito (cfr. fs. 25.905 y vta.) mientras que en lo que respecta a las dos muertes tanto de Rolando como de Marta Coronel verificadas y probadas por varios testigos el *a quo* se limita a sostener que fueron víctimas del delito de tortura seguida de muerte.

Indicó que, conforme quedó acreditado, desde el momento mismo de la detención clandestina, pasaron a ser desaparecidos lo que les permitió a los imputados disponer con total impunidad de su destino final, de su vida. Ello quedó evidenciado con la documentación original del D2 aportada por el testigo Clemente, entre la que se encuentra la lista de personas calificadas como delincuentes subversivos y en particular los nombres de Marta Coronel con el número 55 Marta (fs. 02) y con el número 56 Rolando Coronel (fs. 02) ambos con la siglas DF a la par del nombre.

Aclaró que tal disposición sobre el destino de las víctimas fue planificada y ejecutada por las fuerzas de seguridad que actuaban bajo el control y dirección operacional

*Cámara Federal de Casación Penal*

del imputado Albornoz y por ende en virtud de la cadena de mandos ascendentes del imputado Menéndez y en cadena de mando descendente a Luis Armando de Cándido. Ellos -afirmó- tenían el control absoluto del curso causal de los hechos.

En tal orden de ideas, refirió que no existe indicio alguno que permita creer que las víctimas se encuentren actualmente con vida; por el contrario, ha sido probado judicialmente la implementación de un plan sistemático que consistía en el secuestro, tortura, detención clandestina, eliminación y ocultamiento del cadáver (causa 13/84).

Expresó que los testigos Juan Martín Martín y Juan Carlos Clemente se refirieron a que los detenidos eran trasladados en un camión higiénico y que en concordancia con ellos se pronunció el testigo Osvaldo Alberto Jerez quien relató que "cuando estaba en Arsenales se producían traslados desde el Arsenal hacia Jefatura y al revés... había un traslado cada quince días y en el Arsenal los fusilaban... se podían escuchar los tiros, ráfagas de tiros, el humo, el olor a gente quemada , el olor a combustible... el traslado era en un camión furgón Mercedes Benz 608..." y asimismo Domingo Antonio Jerez -ex conscripto que se desempeñó como chofer en la época de los hechos- quien expresó que "me hacían sacar nafta y gasoil del camión, una mezcla para que los quemara, en la zona de Caspichango, cinco kilómetros de la base hacia el cerro" (cfr. fs. 25.906)

Indicó que el tribunal consideró acreditados los asesinatos de las víctimas aun cuando no hayan aparecido los cadáveres pues ello no resulta óbice para establecer que se ha producido la muerte, destacando el recurrente que si bien es cierto que ningún testigo declaró haber presenciado la

ejecución, la disposición de “destino final” que pesaba sobre las víctimas es determinante para formar la convicción de que se cumplió con ese designio.

Ello, -adunó- aunado al transcurso del tiempo por más de treinta años sin que se hayan tenido noticias de ninguna de las víctimas, las torturas padecidas, el trato propiciado a los detenidos en el centro clandestino que funcionó en la ex Jefatura, la situación de privación de libertad continuada de cada uno de los ofendidos permiten arribar al grado de certeza necesarios para tener por probados los asesinatos.

Afirmó que se trata de homicidios agravados por cuanto los autores actuaron sin riesgo para su persona y aprovechándose de la indefensión de las víctimas, es decir, con alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de lograr su impunidad. En tal dirección, sostuvo que los autores preordenaron su conducta para matar con total indefensión de las víctimas y sin peligro para sus personas toda vez que estaban atadas y vendadas y a total disposición de quienes contando con armas y medios eliminaron ,de esta manera, toda posibilidad de resistencia y de ayuda de terceros.

Refirió que también concurre la agravante del concurso premeditado de dos o más personas pues quedó probado que ésa fue la mecánica general de traslado y posterior ejecución de las víctimas.

Por último, afirmó que quedó acreditada la concurrencia del agravante que califica el homicidio cometido con el fin de asegurar la impunidad pues el transcurso de más de treinta años desde la fecha de los hechos demuestra la eficacia que tuvo en el caso la búsqueda de impunidad, situación que se

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

vio favorecida por el posterior ocultamiento del cuerpo de la víctima.

Por otra parte, manifestó su disconformidad con el criterio del tribunal en cuanto a la determinación del monto de la pena en el caso de Luis Armando De Cándido al considerar como atenuante de culpabilidad su condición de cuadro intermedio de las fuerzas de seguridad que de ninguna manera significa justificación de su comportamiento pero si atenuación en el ámbito de su competencia, de la exigibilidad de otra conducta. Es decir, aclaró- tenía dominio funcional dentro del ámbito de su competencia pero estaba alcanzado por cierto nivel de subordinación, por ello no se le aplicó el máximo de la pena.

A su entender, el *a quo* reedita con ello, el espíritu de las leyes de punto final y obediencia debida.

En conclusión, entendió que la calificación que corresponde aplicar en el caso de los Coronel es la descripta en el art. 80 incs. 2, 3 y 4 del CP vigente al momento de la comisión de los hechos.

3- Bajo el título errónea calificación legal y condicionalidad de cumplimiento de la pena impuesta a Carlos Esteban De Cándido comienza advirtiéndole que ese Ministerio había solicitado la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por el máximo tiempo previsto por la ley, accesorias legales y costas por ser autor directo penalmente responsable de los delitos de usurpación de la propiedad de Rolando Coronel ubicada en la calle Jujuy 1062 (art. 181 del CP en su redacción actual) y encubrimiento (art. 277 incisos 1,3, y 3 en su redacción actual) todo en concurso real (arts. 45, 181 y 277

incs. 1, 2, y 3 y 55 del CP y 18 de la CN) calificándoselos como delitos de lesa humanidad, ordenándose su inmediata detención, traslado y alojamiento en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza de esta ciudad.

Se quejó de que el tribunal no hubiera realizado una ajustada apreciación de la conducta del condenado en el contexto desarrollado durante la última dictadura militar y la gravedad de los delitos cometidos, esto es, habitar una vivienda a sabiendas que provenía de un delito (desaparición forzada de sus propietarios) y no haber realizado las conductas que por su condición de agente público (policía) le era exigible (denuncia pertinente) y abandono inmediato del inmueble. A su entender, la gravedad de los delitos descripta por el tribunal no se ve reflejada ni considerada en la aplicación de la pena.

En segundo lugar, se agravio de la no consideración del delito de encubrimiento y por ende del concurso de delitos, lo que trae aparejado la imposibilidad de una condena efectiva en virtud del delito considerado (usurpación).

Refirió que a su asistido se lo condenó a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de las reglas de conducta, lo que se conecta con lo establecido en el art. 26 del CP.

Al respecto, argumentó que es una facultad del tribunal disponer el modo de cumplimiento, no siendo una cuestión automática el hecho de que si una pena es igual o inferior a tres años debe aplicarse esta modalidad. Destacó que tal decisión debe ser fundada bajo sanción de nulidad en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la pena de prisión.

Sostuvo que en este punto existe una errónea aplicación de la ley sustantiva a la vez que una contradicción en el cuerpo de la sentencia pues si se analiza cada uno de los tópicos que se señala en este artículo la consecuencia lleva a la imposibilidad de aplicación de este instituto.

Así, indicó que el condenado es un ex agente de policía que desarrolló su actividad durante los años más terribles de la dictadura militar, que en tal carácter recibió la autorización de ocupar un inmueble (botín de guerra) de propiedad de desaparecidos con un parentesco putativo con el condenado Albornoz.

En cuanto a la actitud posterior al delito, afirmó que según lo probado, aquélla era desafiante impune y descarada.

Finalmente, agregó que conforme surge del art. 27 del CP la condena se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro años contados a partir de la fecha de la sentencia firme el condenado no cometiere un nuevo delito. A su entender, el criterio del tribunal conlleva a una absolución ficta puesto que por el sólo transcurso del tiempo, opera como exonerante de responsabilidad.

A ello adunó que tratándose de delitos de lesa humanidad, una de cuyas características es la imprescriptibilidad no solo de la acción sino también de la pena, no se podría aplicar el art. 27 del CP. Por tal motivo, concluyó afirmando que estamos en presencia de una grave contradicción.

4- Denunció que no hay consideración por parte del *a quo* de que los delitos perpetrados en contra de Cerafina Rosa López, Ramón Francisco López, Marta Angela López y Juan Carlos López, Hugo Alberto Díaz, Diana Irene Oesterheld y Raúl Carlos Araldi, Eduardo Ramos y Alicia Dora Cerrota de Ramos, Marta y Rolando Coronel, Enrique Abdón Pastor Cerezo, Adriana Mitrovich, Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba, Graciela Del Valle Bustamante de Argañaraz y Ricardo Torres Correa, Carlos Ramón Apaza, Rolando Coronel, Daniel Fontanarrosa Joaquín Ariño Dante Edgardo Bordón, Raúl Mauricio Lechessi y Angel Mario Garmendia puedan subsumirse en el tipo del derecho penal internacional de genocidio, aclarado que esa parte había solicitado al requerir la condena de prisión perpetua que se declarase expresamente que estos delitos eran constitutivos de genocidio.

Manifestó que el tribunal descarta el calificativo solamente porque la Convención al expresar taxativamente el concepto de genocidio excluye expresamente a opositores políticos, y además porque tales opositores deberían formar parte de un grupo homogéneo e identificado y por último porque en la legislación nacional no se encuentra tipificado el delito de genocidio.

En su crítica a dicha argumentación, sostuvo que el hecho de que los opositores políticos no se encuentren entre los grupos pasibles de persecución genocida no significa que no puedan llegar a serlo. A ello adunó que, el hecho de que estos opositores estuviesen incluidos en el proyecto pero no en el texto definitivo de la Convención tiene su explicación en que toda la legislación internacional de esa época tuvo como principal fuente generadora la Conferencia de Yalta, lo que dio

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

origen a la llamada guerra fría. En tales circunstancias, refirió, no hubiese sido razonable que las propias potencias firmantes se prohibieran la persecución de los opositores mientras el stalinismo masacraba millones de disidentes en la URSS y el macartismo perseguía a los suyos en EEUU, habiendo destacado que precisamente esa guerra fría fue la que irrumpió en nuestro país en los años 60 y 70 y que provocó los delitos de lesa humanidad.

Expresó que la exigencia de que los opositores políticos formaran un grupo homogéneo compacto e identificable en este caso se comprueba por vía de la contradicción, pues el único grupo que tenía estas características era el llamado "partido militar" que intentó eliminar a todo el que se le opusiera, sin importar raza, etnia, religión o pensamiento político.

A su entender, el hecho de que el genocidio tipificado como delito internacional no contemplara a los opositores políticos no obsta a que estos delitos de lesa humanidad sean considerados tales, de modo que si el tribunal considera que no hay precedentes bien puede tomar la iniciativa de un *leading case* que lo siente.

Manifestó que la calificación de genocidio no pasa de ser la adjetivización de un sustantivo que en nuestro derecho penal no acarrea consecuencias, por lo que se cuestionó cuál es el temor en calificar los delitos cometidos contra las personas antes mentadas como genocidio, advirtiéndole que la razón de ello residiría en la dificultad que traería este ítem al momento de considerar la concesión del beneficio de la prisión

domiciliaria.

En virtud de lo expuesto, consideró que tanto Menéndez, Albornoz como De Cándido son genocidas en el estricto sentido de la acepción, de modo que declararlos meramente autores de delitos de lesa humanidad no abarca la gravedad de los delitos cometidos en el marco de un plan sistemático de secuestro, tortura y asesinato, del cual indubitadamente fueron víctimas Cerafina Rosa López, Ramón Francisco López, Marta Angela López y Juan Carlos López, Hugo Alberto Díaz, Diana Irene Oesterheld y Raúl Carlos Araldi, Eduardo Ramos y Alicia Dora Cerrota de Ramos, Marta y Rolando Coronel, Enrique Abdón Pastor Cerezo, Adriana Mitrovich, Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba, Graciela Del Valle Bustamante de Argañaraz y Ricardo Torres Correa, Carlos Ramón Apaza, Rolando Coronel, Daniel Fontanarrosa, Joaquín Ariño, Dante Edgardo Bordón, Raúl Mauricio Lechessi y Angel Mario Garmendia.

Como colofón, peticionó se casen los puntos recurridos de la sentencia conforme el art. 470 del CPPN y se ordene la pérdida definitiva del grado militar de Menéndez, se modifique la calificación legal de tortura seguida de muerte por la de desaparición forzada y homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más partícipes y con el fin de lograr impunidad (arts. 79 y 80 incs. 2, 6 y 7 del CP) en perjuicio de Rolando y Marta Coronel para Luis Armando De Cándido.

Asimismo solicitó se modifique la calificación de la usurpación en forma exclusiva agregándosele la del delito de encubrimiento (art. 277 incisos 1, 2 y 3 en su redacción actual) para Carlos Esteban De Cándido y se case la condicionalidad de

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

la ejecución de la pena que le fuera impuesta. Finalmente, peticionó se declare que los delitos cometidos en contra de las personas antes nombradas son constitutivos del delito de genocidio.

Formuló reserva del caso federal.

**II- Recurso de casación presentado por la defensa de Luciano Benjamín Menéndez.**

La defensa de Luciano Benjamín Menéndez encarriló su presentación recursiva en ambos supuestos del artículo 456 del C.P.P.N., en la inteligencia de que la resolución cuestionada resulta errónea en la interpretación de la ley sustantiva y arbitraria en su fundamentación.

1-Bajo el tópico intitulado "la excepción de prescripción y la prohibición de retroactividad de la ley penal" advirtió que las acciones penales correspondientes a los delitos atribuidos a Menéndez se encuentran prescriptas por imperio del principio de legalidad, de las normas del Código Penal que rigen en la materia y del instituto de la cosa juzgada, atento que la ley 25.779 resulta inconstitucional por declarar la nulidad de las leyes 23.492 y 23.521.

Adujo que el tribunal de juicio al rechazar la excepción de prescripción interpuesta, citó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad, que fue adoptada por la ONU el 26 de noviembre de 1968 y respecto de la cual el Poder Ejecutivo Nacional dispuso su adhesión en el mes de agosto de 2003 (Decreto 579/2003), lo que demuestra a las claras su incompatibilidad con los principios de irretroactividad de la ley penal y de legalidad

establecidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Explicó que el texto de la Convención americana sobre desaparición forzada de personas –en su art. VII- y de la Convención sobre imprescriptibilidad de los delitos de guerra y lesa humanidad, se refieren a la prescripción con la suficiente laxitud como para que el Estado Argentino cumpla con la norma internacional sin violentar el artículo 18 de nuestra Carta Magna. A su entender, es un compromiso de los Estados adoptar las medidas necesarias para que las reglas de prescripción internas sean abolidas a futuro, pero de ningún modo autorizan su aplicación retroactiva, debiendo regir lo establecido en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El reconocimiento del derecho de gentes.

Los sentenciantes indicaron que al momento de los hechos –abril de 1976- existía una norma de derecho internacional consuetudinario, reconocida en el artículo 118 de la C.N., que establecía que los delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles.

A tenor de dicha norma internacional, concluyen que las leyes de obediencia debida y punto final resultan inconstitucionales.

Al respecto, la defensa indicó que la norma constitucional mencionada se refiere a delitos contra el derecho de gentes cometidos fuera del país. Ello encuentra su razón en que el constituyente partió de la base de que la normativa existente resultaba suficiente para eventualmente juzgar este tipo de hechos cuando fueran cometidos dentro del país. De ahí que –a contrario de lo sostenido por el tribunal- sea

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

exclusivamente la recepción del principio de extraterritorialidad, arguyendo que en el caso se ha forzado la letra de la constitución para ampliar el *ius puniendi* estatal.

Asimismo, con cita de doctrina, destacó que la costumbre como fuente del derecho internacional debe ser probada a través de la actitud adoptada por el Estado frente a esa normativa y la recepción interna que ésta haya tenido.

Adujo que en 1995 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió respecto a un pedido de extradición, en el caso "Priebke", calificando los hechos como crímenes de guerra con el carácter de imprescriptibles y en 2004 en el caso "Arancibia Clavel", momento a partir del cual consideró que puede señalarse como el de inicio de la recepción jurisprudencial de la costumbre internacional.

Sin perjuicio de ello, señaló que también hubo casos negativos, como el de los autos "Ragnar Hagelin c/Tte. de Navío Alfredo Ignacio Astiz", en el que dicho Tribunal expresó que *"los agravios fundados en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad adoptado por la XXIII reunión general de las Naciones Unidas el 23 de noviembre de 1968, referentes a la inaplicabilidad del beneficio a los hechos investigados, también resultan importantes por carecer de apoyo legal, habida cuenta de que la República Argentina no prestó su adhesión a aquélla, ni tampoco la ratificó..."*, por lo que concluyó que la recepción de la costumbre en el ámbito judicial fue posterior a los hechos que se le imputan a su defendido, habiéndose negado incluso cualquier tipo de "virtualidad".

Agregó que en materia legislativa la Convención americana sobre desaparición forzada de personas se incorporó recién en 1996 y la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad fue aprobada en 1995 y ratificada por el Poder Ejecutivo en el 2003.

De ello coligió que la falta de aprobación en la década del 80' de instrumentos internacionales que permitirían la persecución penal *in eternum* de los delitos de lesa humanidad fue producto de un acto de voluntad expreso y claramente relacionado con las reservas que el Estado argentino mantuvo siempre con la incorporación a su legislación de normas que violentaran el fuerte contenido garantista del artículo 18 de la Constitución Nacional.

Refirió que, por su parte, el Poder Ejecutivo ha dado sobrados ejemplos acerca de su posición con el dictado de las leyes de obediencia debida y punto final y posteriormente en 1989 una serie de indultos.

Aclaró que esta argumentación fue ensayada al momento de las conclusiones finales sin haber obtenido ninguna respuesta específica por parte del *a quo*.

En cuanto a la aplicación retroactiva de la Convención Americana sobre imprescriptibilidad de los delitos de guerra y lesa humanidad y la Convención Americana sobre desaparición forzada de personas expresó que que en forma regular se afirma que la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad fue sancionada con el propósito de su aplicación en forma retroactiva, lo que habría sido afirmado en el fallo "Barrios Altos" de la CIDH.

Adujo el impugnante que la Convención Americana sobre

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

desaparición forzada de personas, en su art. VII, se refiere a la prescripción con suficiente laxitud como para que el estado argentino cumpla con la norma internacional pero sin violentar el art. 18 de la CN. Por su parte, destacó que la Convención sobre imprescriptibilidad de los delitos de guerra y lesa humanidad no autoriza la aplicación retroactiva pues es clara la norma del art. IV en cuanto a que los Estados se comprometen a adoptar, aclarando el recurrente, que ello es luego de incorporada la Convención- las medidas que fueren necesarias para que las reglas de prescripción internas sean abolidas a futuro.

A su entender, por tratarse de un supuesto fáctico sustancialmente distinto, no resulta aplicable al caso argentino la doctrina emanada de la sentencia de la CIDH en el caso "Barrios Altos", pues lo que allí se discutió fue la validez de las leyes de auto amnistía, mientras que en nuestro país la controversia se centra en la validez de las leyes de amnistía dictadas por un gobierno democrático legítimo y en ejercicio de facultades constitucionalmente asignadas.

Conforme a lo expuesto, concluyó sosteniendo que las acciones penales imputadas a su defendido se encuentran prescriptas.

Asimismo, estimó que las consecuencias intrasistemáticas del fallo "Simón" dictado por la CSJN y reeditado en éste y otros procesos alteran la seguridad jurídica del Estado Nacional y atentan contra el propio Estado de Derecho, configurando un caso de gravedad institucional por cuanto implica admitir que la actuación de los tres poderes del

Estado fue contraria a derecho.

2-Por otra parte, refirió que el tribunal ha caracterizado a los distintos delitos imputados como delitos de lesa humanidad en base a una serie de pautas legales y jurisprudenciales.

En primer lugar señaló que rebate en forma acabada los fundamentos del *a quo* que utilizando argumentaciones carentes de apoyatura jurídica llega a dicha conclusión.

Con cita de Andrés D'Alessio, sostuvo que "usar al *ius cogens* como fuente de cognición del derecho penal internacional, como modo de crear figuras punibles, equivale a violar, rotundamente, la exigencia de que la pena solo sea aplicada como consecuencia de alguna conducta claramente descripta en tipos cerrados" -cfr. fs. 25939 vta.-.

Luego de referirse, con remisión a fallos de Tribunales Internacionales sobre la materia, a los elementos necesarios para la configuración de un delito de lesa humanidad, destacó que también resulta exigible que el autor tenga una clara representación del resultado de su conducta y que la naturaleza de los crímenes cometidos sea de conocimiento común.

En tal sentido, afirmó que no hay prueba alguna de que Menéndez haya ordenado la consumación de los delitos atribuidos y mucho menos, que haya urdido la complicada maniobra que a esos efectos se trató de probar. Tampoco resulta concebible que hubiera conocido los distintos pasos que aparecen a la luz de la investigación, desde la violación de domicilio efectuada casi brutalmente, usurpación de propiedades, las eventuales torturas para obtener una posible delación del mismo, los pasos seguidos para obtener con su consentimiento la información contenida en

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

distintas carpetas y con mucha mayor razón que tuviera conocimiento de posibles operatorias de desaparición.

Manifestó que es claro que nos encontramos ante un hecho puntual que no pertenece ni está contenido en el art. 7 del Estatuto de Roma.

A partir de ello, precisó que no se tratan de ataques generalizados o sistemáticos, sino de actos singulares o aislados que de ninguna manera implican ataques contra una población civil, del que haya podido tener conocimiento su asistido.

A modo de colofón, sostuvo que en términos generales, las órdenes impartidas, de ningún modo podían llevar a la desaparición forzada de personas. De hecho, la existencia del objetivo político-militar no representaba un plan en el sentido amplio de la palabra, para destruir, perseguir o debilitar una comunidad y menos aún representaba, *per se*, la perpetración de un acto criminal en muy gran escala contra un grupo de civiles.

3- Bajo el tópico intitulado "Opiniones de Políticos, Escritores, Periodistas y Ex- Guerrilleros", señaló que la temática de este acápite no fue considerada por el tribunal, aclarando que las mentadas opiniones que definían la situación nos da una pauta certera del rechazo que imperó y que hoy subsiste con respecto al accionar subversivo, no soslayando que dichas citas no ameritan una conclusión definitiva ni con un grado de provisoriedad respecto a excesos que se cometieron.

Afirmó que no hay prueba alguna documental ni tan siquiera indiciaria que acredite fehacientemente a nivel de culpabilidad y condena, que pudo existir un plan sistemático que

permitiera y apoyara la usurpación de propiedades, el robo o hurto de bienes económicos, el tráfico o entrega de niños o menores, la tortura o la desaparición de personas tendientes a contrarrestar la guerra generalizada existente.

A su vez no hay dudas que existió una guerra pues los propios guerrilleros y los libros y publicaciones pro guerrilleras así lo sostienen. Así, refirió que en junio de 1970 el PRT realizó su V Congreso, que da Carta de fundación al ERP y donde se declara: "la guerra civil revolucionaria ha comenzado" -cfr. fs. 25.928-.

La defensa puntualizó que en una guerra, frente a un contendiente que precisa el frente de batalla -parafraseando a "el Che", estableciéndolo en "los refugios guerrilleros, en las ciudades, en las casas de los combatientes"- no puede hablarse de delitos tipificados en el Código Penal, por violación de domicilio, o en su caso homicidio agravado por alevosía por el concurso premeditado o delitos de lesa humanidad, por cuanto la confrontación con quienes precisan el frente de batalla, de ninguna manera, -enfaticó el defensor- puede constituir un ataque sistemático masivo contra una población civil.

En apoyo a ello, trajo a colación el testimonio del General Auel, quien manifestó que "La guerra contrarrevolucionaria no tuvo planeamiento estratégico, no funcionó el estado mayor junto con las fuerzas armadas, que de acuerdo a la legislación de aquellos días, era el instrumento estatal el responsable de la elaboración del planeamiento estratégico. Pasé muchos años para entender que esto no era un mero hecho policial y local sino que era un tema global y delicado. Sin embargo se lo enfrentó con la doctrina del "Plan

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

Estratégico", que nunca se construyó" -fs. 25.929 vta.--.

4- El recurrente alegó interferencia grave al ejercicio de la defensa en juicio, habida cuenta que su defendido en la actualidad carga alrededor de 1500 causas, la mayoría por considerárselo coautor mediato penalmente responsable, por lo que tanto en el caso concreto como en otros la sustanciación de procesos paralelos constituye la mentada interferencia. Citó en aval de su postura varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A ello debe sumarse, agregó, que dada la fundamentación del tribunal en responsabilizar a Menéndez como autor mediato con dominio de voluntad en virtud de aparatos organizados de poder, lo coloca en una responsabilidad penal en las diez provincias que componen el Comando del III Cuerpo del Ejército. De ese modo, todas las imputaciones y condenas emergen en la mayoría de los casos como resultados en razón de la fungibilidad de los ejecutores, a una distancia referida a lugares geográficos, que si por lógica o sentido común –no jurídico– fue de imposible percepción, hoy en día, encontrándose detenido, con mayor razón constituye un impedimento para la aportación de pruebas que puedan arrimar elementos a los fines de lograr la verdad real, material o histórica, necesaria en toda defensa.

Resaltó que su defendido no pudo ni puede aportar pruebas puntuales en respuesta a la imputación fáctica.

5- Por otra parte, adujo que la sentencia en crisis carece de la debida fundamentación y por ende es arbitraria, toda vez que contiene valoraciones contradictorias y falta de

correspondencia entre la valoración del plexo probatorio y la conclusión a la que se arriba, tornándola antojadiza y asentada en afirmaciones dogmáticas, habiendo aclarado el recurrente que ello, lejos de ser una mera discrepancia sobre la forma en que el Tribunal hizo la apreciación de los hechos, es constitutivo de notoria arbitrariedad, por ser manifiestamente violatorio de la garantía de defensa en juicio.

Asimismo, indicó que ciertas circunstancias irregulares surgidas del propio debate, impusieron una duda racional que hacían imposible afirmar que su defendido haya tenido efectiva participación en los episodios delictivos materia de juicio, a punto tal de no haberse podido determinar cuál habría sido el aporte concreto efectuado en cada uno de los casos.

Explicó que no hay pruebas de autoría sobre los hechos en particular y que se pretende suplir dicha situación con una fórmula dogmática impropia de un juicio de certeza porque no se formula una descripción concreta de la actividad que se le atribuye. Ello obedece -afirmó- a que no hay prueba de autoría sobre los hechos en particular (art. 3 del CPPN).

Arguyó que ello demuestra que no hubo una valoración racional y objetiva de los elementos de juicio colectados durante la audiencia de debate y tenidos en cuenta para la decisión condenatoria.

Adujo, si bien bajo el título de "violación del principio de razón suficiente" que la ausencia de fundamentación lógica en el fallo se refleja en las aseveraciones de naturaleza conjetural usadas por el *a quo* cuando se pretende subsanar y justificar el debilitado valor de los testimonios y sus graves

contradicciones, como en el caso de Martín y Jerez, sin dar respuesta al planteo efectuado, que se centró en el llamativo recuerdo de sucesos que nunca antes habían sido referidos o en su ostensible alteración a través de sucesivas declaraciones.

También alegó violación a la doctrina de los actos propios, mediante la aplicación de soluciones diferentes en el mismo proceso a conductas similares (art. 16 CN). fs. 25920 vta.

6- Valoración de la prueba. Prueba testimonial.

Destacó que en el fallo en crisis no existe valoración de prueba cierta y concordante, por lo que el resultado condenatorio asume un carácter de absurdo jurídico. En esta inteligencia, criticó el valor probatorio atribuido a la prueba testimonial.

Refirió que la mayoría de las testimoniales recibidas no aportaron nada respecto al hecho puntual y que en otros casos fueron prestadas con un alto grado de parcialidad, marcada en algunas oportunidades con odios o vocablos tendientes a la grosera ubicación de actos inhumanos acontecidos todos ellos a la vista o en la proximidad de terceros, en formaciones militares (Bussi apaleando a una víctima) e inclusive en un sistema carcelario que alojaba presos por delitos comunes, incluidos a los políticos en un número aproximado al millar.

Las escasas apreciaciones existentes denotan una clara parcialidad jurisdiccional. La mayoría de las declaraciones testimoniales prestadas durante el debate llevan consigo el signo de la complacencia, de la falsedad y de una construcción que se evidencia ilógica a la luz de la experiencia común.

Después de cuestionar que se pretenda esclarecer lo ocurrido en las décadas de los 70' y 80' con las declaraciones de las partes en lucha, criticó el valor otorgado al testimonio prestado por Juan Carlos Clemente. Calificó su relato como poco creíble y concluyó que la documentación presentada fue recolectada de modo parcial y caprichoso y carece de eficacia probatoria, por haber sido aportado extemporáneamente y sin posibilidad de control alguno.

Consideró que el testimonio de Juan Martín Martín tampoco puede ser tenido en cuenta, atento que resulta imposible admitir que los calificados como "represores" hayan paseado al testigo, en su condición de secuestrado, por cuatro o cinco destinos diferentes de la Provincia de Tucumán.

De igual manera, se agravió de que en la sentencia en crisis se hayan valorado los dichos de Domingo Antonio Jerez. Al respecto expresó que nunca se acreditó su condición de soldado conscripto durante los años 1976 y 1977, ni mencionó el nombre ni características de ninguno de sus compañeros soldados. Caracterizó a su relato como un verdadero "cuentito" que dio lugar a que varios defensores lo impugnaran, solicitando la remisión de testimonios al juzgado federal en turno.

A su entender, es ingenuo creer que un soldado se pueda mover individualmente a voluntad, o que haya participado en formaciones abiertas donde se mata a golpes o a palos a un detenido.

Aseveró que tampoco es aceptable un testimonio con un grado de parcialidad y complacencia como el efectuado por la abogada Mántaras, que no puede dar una versión sobre el verdadero objetivo del terrorismo y que se permite hablar de

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

jóvenes idealistas con signos de románticos, sin poder justificar su accionar homicida con alevosía.

7-Afectación del principio de contradicción y del derecho a la defensa en juicio.

Manifestó que la sentencia en crisis no se ha referido ni ha valorado el alegato de la defensa, por lo que consideró vulnerado el principio de contradicción, inherente al derecho de defensa en juicio.

8- Bajo la rúbrica "Indebida extensión de la responsabilidad penal" la defensa expuso que, contrariamente a lo indicado en la sentencia, las declaraciones de su asistido sólo dan cuenta de su actividad militar y de la existencia de una verdadera guerra, pero de ninguna manera importan un reconocimiento expreso de conductas ilícitas realizadas en el marco del artículo 29 de la Constitución Nacional.

Por otra parte, señaló que el supuesto aparato organizado de poder que ha sido reconocido en la causa n°13/84, no es comprensiva de la actividad y conducta asumida y reconocida por el General Menéndez.

Así también objetó la aplicación de la categoría de autor mediato en el dominio del hecho conforme a la teoría de Roxin.

A su entender, no es posible establecer la responsabilidad penal de su defendido sin haber efectuado la más mínima precisión sobre la conducta del imputado como Comandante del III Cuerpo del Ejército, salvo la alusión a la pertenencia del mismo dentro de la cadena orgánica de mandos.

Sostuvo que no se puede afirmar que Menéndez haya

tenido conocimiento real y efectivo sobre las derivaciones de la detención, asesinato de por medio y desaparición del cuerpo de las víctimas. Con mayor razón, si se aprecia que las pruebas dan cuenta de una historia que no es propia de un acontecimiento militar. El sentido común no indica que para aniquilar resulte necesaria la participación de militares, policías y guardia cárceles y el paso de la persona detenida por el sector policial (Brigada de Investigaciones), la penitenciaría y, posteriormente, por un centro clandestino de detención –ambos en el centro urbano de la ciudad-.

Refirió que si bien en estos casos la imputación penal puede fundarse en las formas de participación, correspondientes a la instigación, la coautoría o la autoría mediata, debe hacerse en forma convincente, con un criterio que vincule adecuadamente la acción con la figura central del suceso.

Denunció que lesiona el principio constitucional de exigencia de la ley penal previa al hecho del proceso la interpretación del art. 45 del C.P. que admite la aplicación extensiva del concepto de autor del hecho a través de la fórmula del autor mediato, ya sea infiriéndola de las expresiones “tomasen parte en la ejecución del hecho” o “hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo”, contenidas en la norma aludida. En aval de su postura citó jurisprudencia del tribunal cimero.

Asimismo, con remisión al Código Militar vigente al momento de los hechos y de doctrina especializada, señaló que es dable distinguir la responsabilidad del superior por actos de sus subordinados respecto de los cuales “estaba al tanto” de aquellos actos que le eran desconocidos –cfr. Fs. 25.930 vta.-.

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

Agregó, con cita de Kai Ambos, que la amplia responsabilidad establecida por el art. 28 del Estatuto de Roma no debe ser extendida por la jurisprudencia internacional convirtiéndola en una forma de responsabilidad objetiva, antes bien, debe desarrollar criterios que la limiten.

En dicha inteligencia, destacó que el fallo en crisis contiene una errónea valoración del plexo probatorio, dado que no sólo no se han desvirtuado las defensas esgrimidas, sino que resalta y valoriza circunstancias de un hecho criminoso que no integra la conducta de Menéndez, que mal pudo prever o considerar hechos aislados que no estaban en su pensamiento e incluso no formaban parte del mal llamado "plan sistemático".

Resaltó que las fuerzas policiales, en la mayoría de los casos, actuaron por una delegación lógica, ya sea por ser conocedores del medio o constructores de los antecedentes o planillas prontuariales. Tampoco puede responsabilizarse a nadie en forma general, respecto a excesos individuales por parte de quienes actuaron a través de una alteración morbosa de sus facultades o en busca de beneficios económicos en provecho propio.

Por otra parte, puntualizó que tampoco puede sostenerse la complicidad de Menéndez, mediante una acción previa o concomitante, respecto a cada hecho puntual que se le imputa. No se ha acreditado que tuviera conocimiento de los hechos ni que fuera receptor de ninguna notificación o pregunta por parte de algún familiar interesado.

Sostuvo que los fundamentos vertidos en la sentencia son manifiestamente contrarios al principio de responsabilidad

subjetiva que impera en el derecho penal.

Manifestó que ninguna forma de inducción o instigación puede presumirse, por ende, sólo puede existir una responsabilidad disminuida que pertenece a la ley y vida militar, circunstancia que nunca fue negada por el General Menéndez, quien, invariablemente asume la responsabilidad del buen militar, conforme al art. 514 del Código Militar, vigente a la época de los hechos.

9- En el acápite intitulado "responsabilidad-culpabilidad" alegó la existencia de un error de prohibición.

Sostuvo que la conclusión del tribunal vulnera flagrantemente el principio de inocencia y culpabilidad (como culpabilidad subjetiva de haber querido la producción del hecho) al no haber formulado concreta relación de la forma y modalidad de la acción que atribuyen para justificar la pretendida autoría sobre los hechos ventilados en este juicio, recurriendo casi permanentemente a la invocación de supuestos ajenos al proceso. En tal dirección, remarcó que con los mismos indicios pretenden probar tanto la materialidad ilícita como la autoría mediata.

Expresó que, en el caso concreto, a Menéndez no puede exigírsele la comprensión de la antijuridicidad de su injusto ya que es evidente que su actividad operó en todo caso, en una situación de error de prohibición invencible, habida cuenta de que al tiempo del hecho, objeto del presente, no pudo comprender su carácter criminal y por ello no le puede ser reprochado jurídicamente sin violar reglas elementales de racionalidad.

Refirió que antes del golpe militar, desde fines del año 1974 su asistido se encontraba en error de prohibición por simple compresión pues la ley militar vigente a la sazón no pudo

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

sino provocar el referido error. De igual forma la vigencia del estado de sitio durante los años 1975 y 1976.

De esa manera, Menéndez y toda la cadena intermedia militar no podía sino motivarse de acuerdo a dichas leyes, siendo el Código Militar el orden normativo que los protegía y que también los podía castigar, implicando para ellos la certeza de que las limitaciones de las garantías constitucionales existían.

Recién en agosto de 1977 la CSJN se inclinó por un mayor control judicial sobre la racionalidad del arresto en el caso "Zamorano" y en julio de 1978, en el caso "Timmerman", acentuó el control de razonabilidad, estableciendo lo que se llama la relación garantía-conmoción interior y proporción del acto restrictivo.

Como corolario, cuestionó que Menéndez pudiera en ese contexto, tener un criterio jurídico diferencial que le permitiera concebir una conceptualización distinta a la dispuesta ya sea por el gobierno constitucional o de facto.

Aclaró que todos los militares en la cadena intermedia de mandos debían responder, bajo pena de distintas sanciones, en forma plena a las disposiciones o normativas del Estado Nacional, aún tratándose de un gobierno de facto, al que toda la doctrina y jurisprudencia le otorgaban un viso de legalidad en sentido material y no formal.

10- Autoría mediata.

Según su criterio, la teoría de Roxin no resulta aplicable a su defendido, atento que la decisión inductiva fue obra de Juan Domingo Perón, Isabel Martínez de Perón e Italo

Luder y no puede admitirse una repetición de inducción en cadena, con relación a los miembros intermedios que transmitieron la orden.

Finalmente, dejó formulada la reserva del caso federal.

**III- Recurso de casación interpuesto por la defensa de Luis Armando De Cándido y Carlos De Cándido.**

El Defensor Oficial, doctor Ciro Vicente Lo Pinto, interpuso recurso de casación contra los puntos dispositivos II) III), V), VI), IX), X) y XIII) de la sentencia ahora puesta en crisis.

El recurrente encarriló la vía impugnativa bajo los dos supuestos previstos en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

1- Modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva. Como primera cuestión se agravio de que se haya dispuesto el alojamiento de Luis Armando De Cándido en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza cuando éste se encontraba excarcelado por la CNCP a la fecha del dictado de la sentencia condenatoria, habiendo aclarado el defensor, que con anterioridad, su asistido cumplió la prisión preventiva mediante el arresto domiciliario.

Por tal motivo, consideró que existe una privación arbitraria e ilegítima de la libertad y un agravamiento ilegítimo de las condiciones en las que se cumple, lo que le causa gravamen irreparable de imposible reparación ulterior por lo que solicitó se forme incidente por cuerda separada a fin de que se le otorgue tratamiento prioritario y con habilitación de días y horas.

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

Señaló que en este caso se plantean dos cuestiones; a saber; se da ejecución inmediata a la sentencia condenatoria que no se encuentra firme y se agrava la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva.

Con respecto a lo primero, denunció afectación al principio de igualdad ante la ley toda vez que no nunca se produjo una situación como ésta en las causas tramitadas ante ese Tribunal.

Manifestó que aún cuando su asistido ha sido condenado, hasta tanto la sentencia condenatoria no quede firme no se puede variar el *status* de presunto inocente que lo ampara por mandato constitucional (art. 18 de la CN), a lo que debe sumarse que como lo indica el art. 442 del CPPN la presentación del recurso de casación tendrá efecto suspensivo. Citó en aval de su postura jurisprudencia de esta Sala.

En segundo lugar, en cuanto al agravamiento de las condiciones de detención de su asistido, comenzó recordando que Luis Armando De Candido estuvo en prisión preventiva por la presente causa desde el 28/7/04 al 9/1/08 excediéndose con creces los límites legales.

Criticó que el tribunal no haya valorado su edad (71 años) ni las enfermedades que padece, cuyas constancias obran a fs. 15134/15140 de autos (tales como hipertensión, problemas en sus piernas, refiriendo que camina con muletas).

Sostuvo que al encontrarse acreditado el requisito etario previsto por el art. 32 de la ley 24.660 la situación de su asistido se adecua a los estándares legales a lo

que se suma que no existe peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación.

Asimismo, destacó que no se produjeron hechos en la audiencia que hagan variar el estado que goza su defendido siendo que durante todo este tiempo no hubo denuncias ni presentaciones de terceros ante los fiscales o jueces.

En virtud de lo expuesto, consideró que el decisorio recurrido adolece de falta de fundamentación por lo que debe declararse su nulidad, dado que no esgrime causales contundentes que justifiquen el cambio de modalidad en el cumplimiento de la prisión preventiva.

2- Falta de motivación (inobservancia de las normas del CPPN).

Afirmó que en la sentencia se interpretó y valoró la prueba producida durante el debate y la instrucción en forma arbitraria, siendo sus fundamentos escuetos e insuficientes para sustentar una sentencia condenatoria, por lo que solicitó que se declare la nulidad de la sentencia o, en su caso, se absuelva a sus defendidos en razón del principio *in dubio pro reo*.

a) Con relación al testimonio de Domingo Antonio Jerez, refirió que durante el curso del debate había solicitado que se remitan las presentes actuaciones al fiscal federal que corresponda en el entendimiento de que Domingo Antonio Jerez podía ser partícipe de los delitos de homicidio, encubrimiento y violación de domicilio.

En su crítica sostuvo que el tribunal rechazó su planteo sin fundamentación alguna a lo que adicionó la errónea postura evidenciada en los últimos ocho renglones de la argumentación transcripta.

Aclaró enfatizando que nunca solicitó que el tribunal realice actos procesales para que se inicie un proceso penal en contra de Jerez, sino que solicitó que se remitan las actuaciones al fiscal que por turno corresponda atento a los hechos relatados por el testigo y que se suspenda la audiencia de debate a fin de que poder trasladarse, junto a los funcionarios que corresponda, al lugar en el que el testigo refirió que están enterradas personas desaparecidas. Resaltó que la sentencia omitió pronunciarse al respecto.

b) En lo concerniente al planteo de nulidad del reconocimiento realizado en la audiencia de debate del testigo Demetrio Chamatrópolis consideró que la omisión de requerir el reconocimiento en rueda de personas durante la instrucción o en los actos preliminares al debate como instrucción suplementaria no pudo usarse en contra del imputado, mediante la admisión de reconocimientos impropios durante el debate, sin cumplir con las formalidades contempladas en los artículos 272 y 274 del CPPN.

Puntualizó, con cita de jurisprudencia del Máximo Tribunal, que las exigencias incumplidas no revisten el carácter de meras formalidades sino que desde la perspectiva del derecho de defensa, configuran requisitos estrechamente ligados a la seguridad de la prueba de reconocimiento. Y ello es así pues la rueda de personas como el interrogatorio previo a los testigos constituyen válvulas de garantía que operan a favor de la exactitud, de la seriedad y de la fidelidad del acto.

c) En cuanto al planteo de falso testimonio realizado respecto de Oscar Enrique Conte, denunció una colisión violenta

entre sendas declaraciones prestadas por el testigo; la primera, al presentarse en forma espontánea ante el fiscal federal y la segunda, ante el tribunal, oportunidad en la que relató hechos totalmente distintos a los que había referido antes y asumiendo la calidad de víctima, manifestó que también fue secuestrado junto a Marta y Rolando Coronel.

Señaló que para el tribunal resultó contundente para desestimar la imputación de falso testimonio el propio testimonio del imputado Albornoz, quien declaró que "Conte no figura en la lista, no se registra porque no había orden de aprehensión o detención, el cayó porque estaba ahí, entonces había que mantenerlo libre, yo no lo vi en la Jefatura. Los que hicieron el procedimiento lo llevaron para garantizar que todo salga bien" -cfr. 25.872-.

El recurrente objetó tal argumentación destacando que Albornoz no reviste la calidad de testigo sino de imputado por lo que no tiene obligación de decir verdad, a ello adicionó que no se puede valorar esta declaración en forma parcial, es decir, tener por cierto parte de sus dichos, y negarle veracidad al resto.

Indicó que además existen numerosas pruebas que corroboran el falso testimonio de Oscar Conte, expresando que no hay seguridad alguna de que él haya estado en el domicilio de los Coronel al momento que sucedieron los hechos ya que surge de su propia declaración ante el fiscal y de los dichos de María Magdalena Blanco quien corroboró la presencia de Conte en el domicilio de Marta y Rolando Coronel sólo el día anterior al secuestro.

Refirió que igualmente tienen importancia las

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

declaraciones de personas que estuvieron detenidas en la Jefatura de Policía en el mismo período señalado por Conte, como el testigo Juan Martín (quien mencionó a 82 personas y no figura Conte), Raúl Elías (quien expresamente dijo que no lo conoce), Carlos Soldati, Carlos María Gallardo, Demetrio Angel Chamatropulos, Gustavo Enrique Holmquist y Juan Carlos Clemente, ninguno de ellos menciona a Conte.

Adujo que otro hecho que no se pudo comprobar es que Conte haya obtenido su libertad por intermedio del alcalde mayor del servicio penitenciario, a quien se refirió como "Guillermo Wolkys". Y ello es así pues tanto el tribunal como el fiscal verificaron los dichos del testigo, arribando a la conclusión de que quien había prestado servicios en la penitenciaría como odontólogo adjunto era Guillermo Boeykens; quien no tenía la autoridad o influencia para lograr "tamaño objetivo".

Así el recurrente coligió que Conte nunca tuvo relación con Boeykens, dado que no pudo indicar con exactitud ni su apellido ni su domicilio y desconocía que había fallecido el 10 de mayo de 2004.

Por último, reafirmó que Conte no figura en la documentación aportada por Clemente, prueba ésta que no puede ser valorada de manera fragmentada, sino completa.

Expresó que todos los argumentos vertidos permiten colegir que Conte incurrió en falso testimonio agravado en audiencia pública y oral, ocasionando un perjuicio grave a la situación de su defendido ya que sus dichos configuran la base fundamental y exclusiva en que se sustenta la acusación,

destacando que la sólo afirmación de la " tonada cordobesa" no puede ser considerada una prueba determinante.

Al respecto, precisó que la descripción efectuada por Conte de "la persona que le pega" como "gordo grande y pelirrojo y de tonada cordobesa" no se corresponde en nada con la filiación morfológica y cromática de su defendido a la fecha del hecho, según la documentación obrante a fs. 5 del legajo, que lo describe con cabello negro, tes trigueña y de cuerpo mediano.

En cuanto a la inspección ocular ordenada por el tribunal en la que participó Oscar Conte, el recurrente señaló que el lugar que se visitó es público y que no se preservó en su estado histórico por lo que el testigo tuvo desde el año 2004 la posibilidad de conocer las instalaciones y preparar su declaración.

d-Bajo el título "Violación de domicilio" criticó la fundamentación realizada en la sentencia para imputarle dicho delito a Luis Armando De Cándido, destacando que ni el Ministerio Público Fiscal ni las querellas pudieron demostrar que su asistido haya participado en el secuestro de Marta y Rolando Coronel, pues nadie sostuvo que él haya estado presente, sólo el testigo Conte hizo alusión a una persona con tonada cordobesa.

A su entender, este argumento de "una tonada cordobesa" no puede servir para fundar una sentencia de condena de dieciocho años de prisión, sólo podría ser tomada como indicio para realizar una investigación en relación a cuántas personas de Córdoba fueron destinadas a la provincia de Tucumán a la fecha de los hechos a fin de prestar el servicio militar, habiendo aclarado que dicha provincia dependía del IIIer Cuerpo

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

del Ejército con asiento en Córdoba.

e-En lo concerniente a la privación ilegítima de la libertad agravada, el impugnante indicó que al momento del hecho Luis De Candido prestaba servicios como oficial sub ayudante en el Servicio de Inteligencia D2 integrado por varios agentes, por lo que pudo haber sido otro cordobés que formara parte del mismo.

Enfatizó que el resultado negativo de la pericial caligráfica practicada sobre la documentación (en la que había una firma de "Luis") aportada por Clemente no fue meritado, resultando ésta una prueba determinante para la causa.

Expresó que para el tribunal no existen dudas de que el cordobés al que se refiere Conte era Luis Armando De Cándido, pues además fue reconocido por otros testigos en otros operativos, empero objetó el recurrente no detalló de que testimonios se trata y además aludió a otros operativos cuando Luis De Candido sólo fue juzgado por el hecho que damnificó a Rolando y Marta Coronel.

De tal modo calificó a la sentencia de arbitraria, antojadiza, subjetiva e irresponsable.

f- En lo que respecta a la calificación de "torturas seguida de muerte", sostuvo que no se acreditó en forma fehaciente que su defendido haya torturado a Marta Coronel y a Rolando Coronel.

Afirmó que la propia querella fue quien señaló, con sustento en los dichos de Juan Martín, que fue el doctor Ricardo Galdeano el autor material de la muerte de Marta Coronel, pues

le había puesto una inyección para que se muriera y dejara de sufrir. De este modo, fue dicho médico el autor material de la muerte y no su asistido.

En cuanto a la muerte de Rolando Coronel, el recurrente afirmó en base a la declaración de Conte, que se produjo el día del hecho por causas naturales y durante su traslado en la camioneta, destacando que ello resulta conteste con los dichos del abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos, quien sostuvo que Rolando Coronel sufrió un infarto de miocardio.

Hizo hincapié en la imposibilidad de fundar un fallo condenatorio en meras presunciones, pues aquél requiere certeza absoluta de la culpabilidad de la persona.

g-En lo que respecta a la calificación de asociación ilícita manifestó que en el presente caso el requerimiento de elevación a juicio se ve desnaturalizado al no haber podido ser enjuiciados Antonio Domingo Bussi, Alberto Luis Cattáneo y Mario Alberto Zimmerman, por tanto, no se pudo demostrar bajo ningún punto de vista la existencia de una cadena de mando ni que Luis De Cándido, que era sub oficial ayudante y como tal último eslabón de ella, haya respondido a órdenes de sus superiores, siendo un elemento fungible de la misma.

Es decir, no es posible condenar al último eslabón si no pudo probarse la existencia de los restantes elementos que conforman la parte superior de la cadena de mando (autores mediatos).

Ante ello, tampoco se encuentra acreditado el requisito numérico que exige el artículo 210 del C.P. Explicó que no hay en este juicio tres personas que puedan ser miembros de una

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

organización, ya que por el rango que ostentaba De Cándido no podía pretender estar a la altura de los jefes militares, ni participar en igualdad de condiciones con sus superiores habida cuenta de la característica de tipo vertical de toda organización militar.

Sostuvo que esto se encuentra corroborado por lo manifestado por las querellas y por el Ministerio Público Fiscal, cuando le atribuyen a Luis De Cándido el carácter de fungible, es decir de prescindible, de ese modo no formaba parte de la organización como miembro permanente, como lo exige la figura en cuestión.

Ante ello, no puede aseverarse que nos encontramos ante un miembro de una asociación ilícita.

Invocó idénticos argumentos con relación al caso de Carlos De Cándido, quien era agente de la policía de la Provincia de Tucumán pero no pertenecía al SIC.

h-En cuanto a la usurpación de propiedad, el recurrente sostuvo que el tribunal omitió merituar la declaración vertida por los imputados y la prueba aportada por esa defensa. Afirmó que la sentencia se apoya en una hipótesis fáctica equivocada y parcial y por ende resulta inmotivada y carente de toda fundamentación, por lo que deviene irregular y susceptible de ser anulada.

Aseveró que la sentencia sólo describe las declaraciones y otros actos procesales, sin analizar su veracidad ni relacionar dichos elementos con la presencia -circunstanciada, en tiempo, modo y lugar- de Luis De Cándido en cada hecho que se

le atribuyó..

Concluyó que no fue respetado el principio de inocencia ni el principio *in dubio pro reo* y que tampoco fue acreditado el elemento subjetivo del delito.

3- Bajo el tópico "Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva" señaló que Luis y Carlos De Candido son condenados por delitos de lesa humanidad sin que exista una prueba contundente de su existencia o participación en el lugar de los hechos, sólo por formar parte de la policía de la Provincia de Tucumán al momento de su ocurrencia.

Según su criterio se realizó una errónea aplicación de la ley sustantiva "al condenar por una norma que no se compadece con la realidad ni con los actos realizados en el expediente y la prueba producida en el debate" -cfr. fs. 25.887 vta.-.

**V- Recurso de casación interpuesto por la defensa de Roberto Heriberto Albornoz.**

En primer término, se agravio de lo dispuesto en el punto XII de la parte resolutive de la sentencia impugnada en cuanto se revocó la prisión domiciliaria de su defendido, peticionando, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, se trate y revoque dicha modificación, disponiéndose el inmediato restablecimiento de la prisión domiciliaria que gozaba.

Señaló que se resolvió revocar la prisión domiciliaria de Roberto Heriberto Albornoz con sustento en las declaraciones de una testigo de identidad reservada quien había manifestado haberlo visto en un supermercado de la ciudad de Tucumán, de Aldeco y de Juan Carlos Clemente.

Expresó que en la incidencia que se llevó adelante con

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

la producción de pruebas, entre otras, la declaración testimonial del custodio de la Policía Federal -el agente Arias- aunado al resultado de la inspección ocular del domicilio fijado como lugar de detención, ha quedado demostrado que Albornoz no se ha sustraído de la prisión domiciliaria.

Cuestionó el testimonio de Aldeco -quien manifestó que le comprendían las generales de la ley por ser enemiga del imputado- por su subjetividad y, además, por su ambigüedad toda vez que no precisó lugar y tiempo en que fue visto Albornoz en la calle. Así su relato genérico y ambiguo afecta el derecho de defensa en juicio porque no permite ofrecer prueba de descargo.

En tercer lugar, con respecto al testimonio de Juan Carlos Clemente, señaló que ha sido parte integrante del aparato represor y recién en el momento del juicio se manifestó contrario a la represión. Refirió que hasta entonces era un ex integrante de la Policía que posiblemente terminaría en las mismas condiciones que los otros con un mayor agravante, su estrecha relación con personal del ejército y el manejo directo de documentación altamente comprometedora. Estimó que ello torna poco creíble las supuestas amenazas que dice haber sufrido.

Sostuvo, con sustento en el voto en disidencia del juez Casas, que no existen elementos que permitan presumir fundadamente que Albornoz intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones que se llevan adelante.

Destacó que Albornoz es una persona anciana ya que actualmente tiene 79 años y sufre una variada gama de

enfermedades crónicas como su hipertensión arterial que necesitan de cuidados médicos que resultan sumamente difíciles de ser prestados en una institución carcelaria, por lo que consideró que la procedencia de la prisión domiciliaria encuentra sustento en los artículos 11 y 33 de la ley 24.660 y la doctrina que surge del fallo plenario “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/recurso de inaplicabilidad de ley”, dictado por esta Cámara el 30/10/2008.

- Coautoría material del delito de asociación ilícita.

El impugnante objetó la aplicación del delito previsto en el artículo 210 del Código Penal por considerar que se trata de una figura de tipo formal que alude a conductas ilícitas futuras, por lo que queda excluida por la contenida en el ilícito que hayan cometido.

Recordó que el delito de asociación ilícita carece de lesividad y no puede concurrir idealmente con otros hechos que encuentran, cada uno de ellos, su propia adecuación legal.

-Autor material del delito de violación de domicilio y privación ilegal de la libertad de Marta Angela López, Ceferina Rosa López, Juan Carlos López y Ramón Francisco López.

Relató que Roberto Heriberto Albornoz fue considerado autor material de la violación de los domicilios ubicados en la calle Santiago del Estero 4000 y 3750 de la ciudad de San Miguel de Tucumán y del delito de privación ilegítima de la libertad agravada, en perjuicio de Marta Angela López, Ceferina Rosa López, Juan Carlos López y Ramón Francisco López.

El impugnante cuestionó el valor probatorio atribuido al testimonio de Marta Angela López pues a su ver resulta insuficiente para motivar en los términos de los

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

artículos 399 y 123 del C.P.P.N. una sentencia condenatoria.

En tal sentido argumentó que fue prestado ante la Comisión Bicameral de la Legislatura de la provincia de Tucumán y que su lectura revela que la nombrada tomó conocimiento del hecho a través de su progenitora, quien le transmitió que en una oportunidad el Comisario Inspector Quinteros le dijo que participó de los secuestros por orden de Albornoz.

A su entender, para su incorporación a la causa deberían haberse cumplido con las formalidades previstas en los artículos 239 y concordantes del CPPN toda vez que se trataría de una testigo de "dichos de dichos", cuestionando a su vez, el valor probatorio ya que Quinteros sólo habría referido el apellido Albornoz, no pudiéndose afirmar que su defendido sea la única persona con ese apellido entre todos los integrantes de la Policía de Tucumán.

Consideró que el testimonio de López sólo sirve como indicio para abrir una línea investigativa pero no resulta suficiente para acreditar un hecho y motivar una condena.

Autor material del delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Hugo Alberto Díaz, Diana Irene Oesterheld, Raúl Carlos Araldi, José Eduardo Ramos, Alicia Cerrota de Ramos, Enrique Abdón Pastor Cerezo, Adriana Mitrovich, Horacio Ramón Torres Correa, Carlos Román Apaza, Daniel Fontanarrosa, Joaquín Ariño y Dante Edgardo Bordón.

Sostuvo el defensor que se condenó a Albornoz por haberse concluido que como Jefe del Servicio de Información Confidencial, en ese carácter -hecho indemostrado en autos-

tenía a su cargo la custodia de los presos llevados a la Jefatura de Policía.

Aclaró que los antes mentados se encontraban detenidos en la Jefatura de Policía por disposición de la Comunidad de Inteligencia y Albornoz no tenía facultades para disponer la detención, privación o la libertad de los detenidos, destacando que ello se encuentra narrado en la declaración de Juan Martín. Lo único que podía hacer su defendido era custodiar la no evasión, cualquier otra intromisión en los asuntos concernientes a la Comunidad de Inteligencia le podían costar su propia vida, existiendo antecedentes al respecto.

Coligió que la conducta de Albornoz consistente en custodiar a los presos de la Comunidad de Inteligencia en la Jefatura de Policía no le resulta imputable por aplicación del artículo 34, inciso 2º, del Código Penal, pues obró violentado por las amenazas vertidas por el Teniente González Naya, de que si incumplía la orden o conversaba con alguno de los detenidos podría terminar sus días en uno de esos calabozos.

Relató que en aquella época un Teniente, con su sola presencia, provocaba temor reverencial a terceros y subalternos, destacando que la Jefatura de Policía de Tucumán se encontraba totalmente militarizada desde la realización del Operativo Independencia y que tanto su Jefe como Subjefe eran militares de alto rango y en actividad.

Por ello, sostuvo que en el caso particular de Albornoz se debería haber ajustado su conducta a la norma prevista en el art. 34 inc. 2 del CP tal como fue alegado por esa parte, pues su participación a todas luces se puede apreciar como involuntaria por existencia de vicio en la voluntad ante la

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

amenaza de seguir la misma suerte de los cautivos.

Finalmente, afirmó que ante dicho planteo que fue alegado por esa parte los judicantes no han realizado ningún tipo de mención para sostener que dicha eximente no se encuentra acreditada, por lo que coligió que han incurrido en arbitrariedad manifiesta.

- Autoría mediata de los delitos de violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos agravado, torturas seguida de muerte, homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr la impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes.

Manifestó que en la sentencia impugnada se lo condena a Roberto Albornoz como autor mediano de los delitos supra referenciados, todos en concurso real, lo que a su entender, dado su cargo en aquella época resulta inaplicable para su defendido pues dicha autoría requiere que el sujeto activo de la relación penal detente cierto poder de decisión en los hechos que se le atribuyen.

En tal sentido, indicó que los elementos probatorios aportados en autos no logran demostrar que Albornoz, como Jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía de Tucumán, haya tomado la decisión de secuestrar, torturar, privar de la libertad, matar o hacer desaparecer personas.

Ello así, -explicó- pues conforme la requisitoria de elevación a juicio y el testimonio de Juan Martín, tales decisiones eran tomadas en la Comunidad de Inteligencia que estaba integrada por el Jefe de la División Inteligencia de la

5ta. Brigada de Infantería, el Jefe de Destacamento de Inteligencia 142, el Jefe de la Policía de la Provincia de Tucumán, el Jefe de la Delegación de la SIDE en la Provincia, el Jefe de Inteligencia de la Policía Federal, el Jefe de la Sección Inteligencia del Comando de la Zona de Operaciones y el Jefe del Grupo de Interrogadores, no encontrándose compuesta dicha comunidad por el Jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía de Tucumán.

Resaltó que tampoco durante el juicio no se probó tal supuesto. En tal aspecto, argumentó que si su asistido no integraba la Comunidad de Inteligencia no tenía injerencia alguna en las mencionadas decisiones y, por tanto, no pudo ser considerado autor mediato. La propia jerarquía de Albornoz no le permitía ostentar el mando que se exige para ser autor mediato, pues no tenía decisión directa sobre los hechos criminales que se le atribuyen.

Disposiciones legales violadas o erróneamente aplicadas. Finalmente, el defensor criticó la relación concursal escogida por el *a quo* por resultar manifiestamente improcedente toda vez que la comisión de los delitos individuales excluye la figura de la asociación ilícita.

Reiteró, una vez más, el argumento de que se trata de un delito formal que se perfecciona con la asociación para cometer ilícitos en el futuro, y que una vez cometido dicho objetivo queda excluida la asociación para aplicarse el tipo configurativo de dicho delito y si es con la participación de tres o más sujetos activos se estaría en la comisión del delito en banda.

Por ello, sostuvo que no puede existir concurso ideal

con los delitos perpetrados y que eran en definitiva el objeto de la asociación, pudiendo sólo concurrir en forma real cuando los delitos realizados no constituían el objeto de la asociación.

Por otra parte, y reiterando idéntico agravio, alegó violación de la norma contenida en el art. 123 del CPPN pues la sentencia adolece de fundamentación al excluir del tratamiento la eximente de responsabilidad del art.34 inc. 2 del CP alegada por esa parte y las defensas esbozadas en los alegatos y los testimonios desacreditantes de los hechos atribuidos a su asistido. Todo ello, concluyó, infringe el art. 18 de la CN.

**TERCERO: Tratamiento de agravios**

A los fines de un abordaje racional e integral de las cuestiones planteadas, los mismos serán expuestos en el orden que se detalla sin perjuicio del orden cronológico de presentación de los recursos de casación.

**I-Recurso de casación presentado por la defensa de Luciano Benjamín Menéndez.**

1-Al emprender el abordaje del tópico intitulado "la excepción de prescripción y la prohibición de retroactividad de la ley penal", advierto que dicho planteo resulta insustancial habida cuenta de que la decisión del tribunal de grado se encuentra debidamente fundada con arreglo a la doctrina que emana de Fallos: 328:2056 ("Simón, Julio Héctor") no habiendo introducido el recurrente nuevos elementos que permitan

apartarse del criterio uniforme consolidado por la Corte Suprema.

En tal dirección, esta Cámara se ha pronunciado sosteniendo la imprescriptible e inderogable obligación del Estado Argentino de investigar y de sancionar los delitos de lesa humanidad, deber que, como es sabido, se erige como imperativo jurídico para todos los Estados y que tiene primacía sobre cualquier disposición en contrario de los ordenamientos jurídicos internos (cfr, al respecto, "Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/ recursos de casación e inconstitucionalidad" causa n° 7896, rta. el 18/5/07, reg. 10488, causa n° 7758, "Simón, Julio Héctor s/recurso de casación, rta. el 15-05-07; y causa n° 9517, "Von Wernich, Christian Federico s/recurso de casación, rta. el 27-03-09, reg. n° 13.516; causa n° 13.073, "Arias, Carlos Alberto y Zírpolo, Luis Ángel s/recurso de casación", rta. el 24-11-11, reg. n° 18.879 y "Videla, Jorge Rafael s/rec. de casación", causa n 14.571, rta. el 22-6-12, reg. n 19.679, (fallada por el suscripto), todas de la Sala I; "Barcos, Horacio Américo s/recurso de casación, rta. el 23-03-12, reg. n° 19.754 y causa n° 10.431, "Losito, Horacio y otros s/recurso de casación", rta. el 18-04-12, reg. n° 19.853 y "Brusa, Victor Hermes s/rec. de casación, causa n° 12314, rta. el 18/5/12, reg. n° 19959 de la Sala II; causa n° 9896, "Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/recurso de casación", rta. el 25-08-10, reg. n° 1253/10 de esta Sala III; y causa n° 11.545, "Mansilla", reg.

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

nº 15.668, rta. el 26-09-11; causa nº 12.821, "Molina, Gregorio Rafael s/recurso de casación", rta. el 17-02-12, reg. nº 162/12; causa nº 10.609, "Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/recurso de casación, rta. el 13-02-12, reg. nº 137/12; causa nº 13.877, "Rezett, Fortunato Valentín s/recurso de casación", rta. el 16-04-12, reg. nº 516/12, (las últimas tres sentencias falladas por el suscripto) todas de la Sala IV.

No cabe soslayar que el Máximo Tribunal ha precisado que en hechos, como los que se investigan en estas actuaciones, el Estado Argentino debe, de conformidad con el derecho internacional que lo vincula, garantizar su juzgamiento, puesto que se trata de delitos de lesa humanidad y que el incumplimiento de tal obligación compromete la responsabilidad internacional del Estado Argentino (Fallos 328:2056 y 330:3248).

En virtud de lo expuesto, considero que la defensa técnica de Menéndez no ha logrado confutar la doctrina jurisprudencial de la CSJN que fluye de Fallos: 327:3312; 328:2056 y 330:3248, y la que dimana de los precedentes de esta Cámara *supra* mencionados, por lo que postulo el rechazo por inadmisibile de dicho agravio pues no satisface el requisito de mínima fundamentación del recurso interpuesto.

2- En cuanto al planteo concerniente a la falta de prueba de que Menéndez haya ordenado la consumación de los delitos atribuidos y que no revisten el carácter de lesa

humanidad, he de proponer también su rechazo por las siguientes razones.

Como es dable apreciar de la lectura de los sólidos fundamentos del fallo, el tribunal *a quo* a partir del *factum* fehacientemente acreditado, concluyó en la autoría responsable de Menéndez y en la afirmación de que todos los injustos cometidos en el marco de estas actuaciones configuran delitos de lesa humanidad.

Ciertamente el plexo probatorio críticamente examinado no deja hesitación alguna de que la actuación del imputado Menéndez se produjo en el contexto de un ataque de carácter generalizado y sistemático contra una población civil, “de conformidad con una política de estado o de una organización o para promover esa política”. Elementos normativos éstos que son exigidos por el tipo penal internacional de delito de lesa humanidad, conforme el art. 7 del Estatuto de Roma.

De allí, como lógica derivación su imprescriptibilidad (desde el ámbito temporal) y la jurisdicción universal (desde el ámbito espacial) entre otras consecuencias.

Cabe evocar que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado el 17 de julio de 1998 y ratificado por nuestro país mediante ley n° 25.390 -B.O. 23.1.01- e implementado por ley 26.200 -B.O. 9.1.07-, establece en el art. 7 apartado primero, el concepto del delito de lesa humanidad en los siguientes términos 1. [...] cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

o sistemático contra población civil y con conocimiento de dicho ataque:... a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

A los efectos del párrafo 1: a) Por 'ataque contra una población civil' se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política...".En este orden de ideas, no resulta ocioso memorar lo

sostenido por el Máximo Tribunal al resolver el recurso de hecho deducido por los querellantes en la causa "Derecho, René Jesús s/ inc. de prescripción penal de la acción" -causa nº 24.079-", del 11 de julio de 2007, oportunidad en la que se remitió a los fundamentos y conclusiones del Procurador General. Se destaca en su dictamen que "la comunidad internacional ha realizado un esfuerzo conjunto para definir, en una evolución cuyo último punto sobresaliente lo constituye el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en qué consisten los crímenes de lesa humanidad [...]. Los crímenes de lesa humanidad, al igual que los delitos contra las personas, implican ambos la lesión de derechos fundamentales de los seres humanos. La distinción tiene su punto de partida en que los crímenes de lesa humanidad no lesionan sólo a la víctima que ve cercenados por el delito sus derechos básicos, sino que también implican una lesión a toda la humanidad como conjunto. Esta es la característica que fundamenta, entre otras cosas, la jurisdicción universal de este tipo de crímenes. El autor comete un crimen contra toda la humanidad, no sólo contra su víctima directa. En este sentido explica Satzger, el autor de un crimen de lesa humanidad, con su conducta, se rebela contra un estándar mínimo de derechos de la humanidad en su conjunto. Los tipos penales de los crímenes de lesa humanidad protegen sólo de manera secundaria los bienes jurídicos de las personas individuales (Helmut Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht. Baden- Baden, Alemania, 2005, pag. 203)".

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

En cuanto a los requisitos típicos que deben reunirse para que un acto puede calificarse de ese modo, se señaló en dicho precedente que, a la luz de la doctrina "...el requisito más relevante para que un hecho pueda ser considerado delito de lesa humanidad consiste en que haya sido llevado a cabo como parte de un ataque que a su vez -y esto es lo central- sea generalizado o sistemático. Este requisito recibió un tratamiento jurisprudencial en el fallo Prosecutor v. Tadic, dictado por el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia el 7 de mayo de 1997. Allí se explicó (apartados 647 y ss.) que la inclusión de los requisitos de generalidad o sistematicidad tenía como propósito la exclusión de hechos aislados o aleatorios de la noción de crímenes contra la humanidad. Generalidad, significa, según el fallo, la existencia de un número de víctimas, mientras que sistematicidad hace referencia a la existencia de un patrón o de un plan metódico...".

Asimismo se aclaró que hay un consenso generalizado de que no es necesario que los dos requisitos previstos en la primera condición se den acumulativamente, advirtiéndose que ellos "fueron también definidos por el Tribunal Internacional para Rwanda del siguiente modo: '...El concepto ´generalizado´ puede ser definido como masivo, frecuente, de acción a gran escala, llevado a cabo colectivamente con seriedad considerable

y dirigido a una multiplicidad de víctimas. El concepto 'sistemático' puede ser definido como completamente organizado y consecuente con un patrón regular sobre la base de una política común que involucra recursos públicos o privados sustanciales (The Prosecutor versus Jean-Paul Akayesu, case nº ICTR-96-4-T)..."

Con respecto, al restante requisito, "policy element", se sostuvo que "sirve para excluir del tipo penal de los crímenes de lesa humanidad hechos aislados, no coordinados y aleatorios y configura el elemento propiamente internacional de esta categoría de crímenes [...]".

Volviendo al *sub examine*, a la luz de las directrices antes establecidas es dable destacar que las presentes actuaciones trasuntan hechos notorios no controvertidos pues a este devenir no queda resquicio de duda de que ciertamente se sucedieron en el contexto de un ataque generalizado y sistemático emprendido desde el Estado contra una población civil, subsumiéndose, por ende, en el tipo penal internacional de delito de lesa humanidad, calificación ésta que no ofrece reparo alguno.

Y no empece a tal aserto el argumento defensorista de que se trató de hechos singulares, pues, más allá de que ello carezca de asidero fáctico, desde una perspectiva normativa lo que reclama la estructura dogmática del tipo de lesa humanidad es que el ataque como núcleo del supuesto de hecho descrito en la norma revista las cualidades de general y sistemático, con

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

prescindencia, por ende, de cada uno de los hechos particulares que se verifiquen en ese contexto de actuación.

En este orden de ideas, autorizada doctrina sostiene que "...lo decisivo es que el autor sepa que no actúa aisladamente, sino en el marco de un ataque generalizado o sistemático, sin que deba tener, sin embargo, un conocimiento detallado de ese ataque".

Ello es así, y aquí la respuesta al punto axial del agravio, pues "si se exige un conocimiento preciso por parte del autor de la política o plan sobre el que se basan los crímenes contra la humanidad, entonces difícilmente se podrá demostrar el conocimiento de alguno de los intervinientes en tales crímenes. La planificación de una política criminal está reservada típicamente al pequeño grupo de conducción, el cual cuidará de que los ejecutores exteriores de esa política conozcan sólo lo estrictamente necesario" (cfr. Ambos, Kai "La parte general del derecho penal internacional. Bases para una elaboración dogmática". Ed. Kas Temis-Duncker & Humblot. Uruguay, 2005, págs 402 y 403).

En tal inteligencia y en observancia de las reglas prácticas sancionadas por esta Cámara no corresponde ahondar en mayores argumentaciones en relación al agravio esgrimido por el recurrente (Ac. C.F.C.P. nº 1/12 de fecha 28 de febrero de 2012, Regla Cuarta), por lo que propongo su rechazo.

Tampoco prosperará el planteo de la asistencia técnica de Menéndez íntimamente vinculado con la cuestión anterior de que existió una guerra y que en esas circunstancias la confrontación con quienes precisaron el frente de batalla de ningún modo podía constituir un ataque sistemático masivo contra una población civil.

La alegación defensiva tendiente a introducir una causa de justificación que elimine la antijuridicidad de la conducta de su asistido deviene a todas luces trivial pues se contrapone sin argumentación plausible alguna con hechos notorios que no admiten una interpretación disímil, como es la existencia de un plan sistemático implementado por el denominado proceso de reorganización nacional, que ha quedado plenamente acreditado a partir de la causa n° 13/84, pero por sobre todo encuentra un ineludible óbice en el plexo jurídico del derecho humanitario.

Tales normas, como es sabido, configuran un infranqueable límite, indisponible aún y precisamente en la eventualidad de un conflicto armado. Se ha destacado la función que cumplen los distintos tratados de derecho humanitario en la preservación de normas fundamentales justamente en esos contextos en los que se encuentra particularmente amenazada la primacía del derecho (cfr. Chetail, Vincent "La contribución de la Corte Internacional de Justicia al Derecho Internacional Humanitario", Revista Internacional de la Cruz Roja, n° 850, P. 235, citada *in re* "Etchecolatz").

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

En dicho precedente se sostuvo que sus disposiciones revisten el *status* de *ius cogens*, por lo tanto participan de los atributos de obligatoriedad e indisponibilidad, e impone a los Estados las obligaciones de tutela y investigación y sanción frente su violación. En este sentido la Corte Internacional de Justicia ha dicho que "las normas fundamentales de derecho humanitario debe ser respetadas por todos los Estados, hayan ratificado o no las convenciones en que están inscritas, pues constituyen principios intransgredibles de derecho internacional consuetudinario" (opinión consultiva "Legality of the use Threat or Use of Nuclear Weapons", ICJ Reports, p. 258, párr. 83).

No resulta ocioso recordar que el artículo tercero de los cuatro Convenios de Ginebra, contiene *inter alia*, la expresa prohibición de los atentados contra la vida y la integridad corporal, los tratos crueles, los suplicios, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes y el cercenamiento de las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Cabe aclarar que nuestro país ya con anterioridad a la ocurrencia de los hechos que aquí se juzgan había dado recepción legislativa a los cuatro convenios de Ginebra y a la Convención de La Haya sobre Leyes y Costumbre de la Guerra Terrestre.

En tal orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que aun en tiempos de guerra en que ciertos derechos sufren un eclipse parcial o temporario subsiste siempre la conservación, como intangible, de la protección al bien jurídico vida dentro de un mínimo internacional local o de un mínimo de orden jurídico interno admitido internacionalmente y que no se puede desconocer" (cfr. Fallos: 318:2148 voto del doctor Gustavo A. Bossert, considerando 30).

En sentido similar, se ha expedido el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia afirmando que los delitos de homicidio y tratos crueles acarrearán responsabilidad penal (Cfr. Prosecutor v. Tadic, planteo de jurisdicción, rta. el 2 de octubre de 1995 y Prosecutor v. Naser Orić, rta. el 30 de junio de 2006, parág. 261).

Por su parte, la Corte Internacional de Justicia observó "que la protección dispuesta en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no cesa en tiempo de guerra, salvo cuando se aplica el artículo 4, que permite la derogación de algunas disposiciones en situaciones de emergencia nacional. El respeto del derecho a la vida (garantizado por el artículo 6 del Pacto Internacional) integra sin embargo, esas disposiciones. El derecho de las personas a no ser privadas arbitrariamente de la vida también se aplica durante las hostilidades (opinión consultiva "Legality of the use Threat or Use of Weapons", ICJ Reports, p.240 párr. 25) - *in re* "Etchecolatz"-.

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

*Ex abundantia*, no caben dudas que en el momento en que ocurrieron los hechos de autos no existía una guerra, antes bien, existía, como ha quedado establecido con el contundente acervo probatorio reunido en esta causa, una maquinaria estatal diseñada para ejercer el terrorismo sobre aquellas personas - civiles- que con manifiesta arbitrariedad reputaban "subversivos".

*A fortiori* si se hubiera verificado la hipótesis de contexto bélico que conjetura el recurrente, esto es, un leal combate, tal extremo tampoco justificaría el accionar de Luciano Benjamín Menéndez pues ninguna de las consabidas normas convencionales que rigen en tiempos de guerra habilitan a proceder de tal modo, haciendo desaparecer personas.

La ejecución sumaria de civiles desarmados, después de haber sido sometidos a diversos tormentos, y sin juicio previo conspira contra principios elementales de toda sociedad que parten del prístino *nemim non laedere*, y por ende resultan violatorias del derecho humanitario por lo que, la pretensión de legalidad elucubrada por la defensa carece de asidero lógico no resistiendo por ende, el menor análisis. Dejo de esta forma, sucintamente esbozada mi propuesta de rechazo al presente agravio.

4- También habrá de denegarse el planteo vinculado con la afectación al ejercicio de la defensa en juicio del imputado debido a la sustanciación de procesos paralelos.

De la lectura de estas actuaciones advierto que Luciano Benjamín Menéndez fue oportunamente impuesto de sus facultades constitucionales, habiendo optado por manifestarse en la audiencia de debate, ocasión en la que en forma liminar dejó sentado su criterio de que los juicios eran inconstitucionales motivo por el cual "se negaba a declarar" -cfr. fs. 25.642/25.642 vta.-

Es decir, el imputado contó con la oportunidad real y concreta para expresarse libremente durante el juicio a fin de contrarrestar la imputación dirigida en su contra, explicando su versión de los hechos, ora produciendo prueba en aval de su postura, ora sindicando algún dato relevante para la dilucidación del caso, en definitiva pudo ejercer materialmente su derecho de defensa, a tenor del art. 294 del digesto ritual.

El imputado discurrió sobre aspectos tales como el carácter de lesa humanidad del que, a su entender, carecerían los hechos investigados, la incompetencia del tribunal actuante, la cosa juzgada, el principio de legítima defensa, la inaplicabilidad de la ley penal más benigna.

Ergo, no puede ahora agravarse con sustento en que se le hubo vulnerado su derecho de defensa porque él mismo decidió adoptar aquel temperamento, acompañado en todo momento por su asistencia técnica.

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

Por lo demás, advierto que la alegación defensiva no se condice con las constancias que surgen de la causa, a modo ejemplificativo, repárase que tuvo una participación activa durante la audiencia de debate, al preguntarle directamente al testigo Julio Jorge Alsogaray el motivo por el cual "fueron los guerrilleros al monte si eran tan escasos" -fs. 25.709-.

Por otra parte, el imputado no ha señalado concretamente qué medidas no ha podido producir como así tampoco ha expresado de qué modo ellas hubieran incidido en la solución final que a la postre se adoptó.

Por tal motivo, cabe rechazar su pretensión en esta instancia.

5-Corresponde abordar ahora la alegada arbitrariedad de la sentencia por violación al principio de razón suficiente.

Liminarmente cabe memorar que el Código adjetivo ha adoptado el sistema de la sana crítica racional -art. 398, 2º párrafo- que conforme al precepto constitucional que exige que todo pronunciamiento debe ser fundado, requiere que las conclusiones arribadas en el veredicto deban ser consecuencia de una valoración racional de las pruebas, respetándose las leyes de la lógica -principios de identidad, tercero excluido, no contradicción y razón suficiente- de la psicología y de la experiencia común.

Este criterio rige asimismo en los tribunales internacionales en cuanto a la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica evitando adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para sustentar un fallo (cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos *in re*: “Bulacio vs. Argentina”, Sentencia del 18 de septiembre de 2003; “Myrna Mack Chang vs. Guatemala”, Sentencia del 25 de noviembre de 2003; “Maritza Urrutia vs. Guatemala”, Sentencia del 27 de noviembre de 2003; y “Herrera Ulloa v. Costa Rica”, Sentencia del 2 de julio de 2004 cfr. “Videla” antes cit.).

El principio de razón suficiente implica que las afirmaciones a que llega una sentencia deben derivar necesariamente de los elementos de prueba que se han invocado en su sustento. Son pautas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que deben apoyarse (cfr. Sala II, “Di Fortuna, Juan Marcelo s/recurso de casación”, causa nº 3714, reg. nº 4923, rta. el 25/2/02).

En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puntualizado que si se verifica que se han ponderado testimonios, prueba de presunciones e indicios en forma fragmentada y aislada, incurriéndose en ciertas omisiones en cuanto a la verificación de hechos que conducen a la solución del litigio, sin haberse efectuado una visión de conjunto ni una

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

adecuada correlación de los testimonios y de los elementos indiciarios, ello constituye una causal de arbitrariedad que afecta las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso (Fallos 311:621).

En esta línea de pensamiento, se ha sostenido que la certidumbre en materia criminal explica que la certeza es la persuasión de una verdad, la convicción de que la idea que nos formamos de una cosa corresponde a la misma, puesto que siempre que se tiene por verdadera una cosa, hay certeza de ella, pues se trata de una verdad de tal naturaleza que se impone a la mente sin discusión. Así, la certeza constituye aquel estado del ánimo en virtud del cual se estima una cosa como indudable (cfr. Pietro Ellero, *De la certidumbre en los juicios criminales, Tratado de la prueba en materia penal*, Buenos Aires, 1998, pp. 21, 33 y 318).

De ahí entonces que si de los elementos convictivos reunidos no se puede arribar inexorablemente a la conclusión afirmada en la sentencia es porque ha existido una afectación al principio de razón suficiente lo que lleva a su nulidad.

Establecido lo que antecede he de abocarme al examen del pronunciamiento recurrido guiado por el estándar de la "máxima capacidad de rendimiento" sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 328:3399.

Cabe evocar que el tribunal de grado consideró que

Luciano Benjamín Menéndez debe responder por los delitos que aquí se le atribuyen, en calidad de autor mediato en virtud de su voluntad de dominio del hecho que le cupo en el seno del aparato organizado de poder en que se convirtieron tanto a las Fuerzas Armadas de la Nación como a las fuerzas de seguridad locales durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional, hechos que se cometieron entre el 24 de marzo de 1976 y el 05 de abril de 1976 -cfr. fs. 25.780 vta.-

Con cita de Claus Roxin, los judicantes advirtieron que este tipo de conductas no pueden aprehenderse selectivamente con los baremos del delito individual, siendo el factor decisivo para fundamentar el dominio de la voluntad en tales casos la fungibilidad del ejecutor.-cfr. fs. 25.781/25.781 vta.-

De seguido, sostuvieron que "Luciano Benjamín Menéndez integraba la cadena de mandos superiores mientras que Roberto Heriberto Albornoz se encontraba en un nivel jerárquico intermedio en esa maquinaria de poder en que se convirtió a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad locales, y decidían sobre la vida de aquellos que pudieran perturbar el denominado Proceso de Reorganización Nacional. Desde sus respectivas posiciones en esa estructura de poder, dispusieron los secuestros, el terror por medio de torturas y la posterior muerte de las víctimas de esta causa..."-fs. 25.781 vta.-

En tal inteligencia, afirmaron que "los asesinatos de las víctimas de esta causa, están conectados causal y normativamente con la acción de hacerlos desaparecer dispuesta

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

por Luciano Benjamín Menéndez [...] desde el momento que dispusieron de sus personas como objetos, desprovistos de derechos, sometidos absolutamente a la voluntad de los mencionados".

"Desde el punto de vista subjetivo, actuaron dolosamente: se representaron el resultado y lo quisieron. Conforme se ha demostrado en la audiencia, las vidas de Ceferina Rosa López, Juan Carlos López, Ramón Francisco López, Hugo Alberto Díaz, Raul Mauricio Lechessi, Diana Irene Oesterheld, Raul Carlos Araldi, José Eduardo Ramos, Alicia Dora Cerrota de Ramos, Enrique Abdón Pastor Cerezo, Adriana Cecilia Mitrovich, Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba, Graciela Bustamante de Argañaraz, Ricardo Torres Correa, Carlos Román Apaza, Daniel Fontanarrosa, Joaquín Ariño, Ángel Mario Garmendia y Dante Edgardo Bordón estaban bajo el dominio de Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Heriberto Albornoz".

En tal orden de ideas, aseveraron que "hay una realidad incontrastable: Menéndez y Albornoz dispusieron los secuestros de las mencionadas víctimas para aniquilarlas y obtuvieron el resultado que se representaron y quisieron. No es una cuestión de suerte que Ceferina Rosa López, Juan Carlos López, Ramón Francisco López, Hugo Alberto Díaz, Raúl Mauricio Lechessi, Diana Irene Oesterheld, Raúl Carlos Araldi, José Eduardo Ramos, Alicia Dora Cerrota de Ramos, Enrique Abdón Pastor Cerezo, Adriana

Cecilia Mitrovich, Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba, Graciela Bustamante de Argañaraz, Ricardo Torres Correa, Carlos Román Apaza, Daniel Fontanarrosa, Joaquín Ariño, Ángel Mario Garmendia y Dante Edgardo Bordón hayan desaparecido: ello respondió a la decisión de los mandos superiores -Luciano Benjamín Menéndez- y de los coordinadores locales -Roberto Heriberto Albornoz- quienes dispusieron aniquilarlos porque estaban en agrupaciones que podían resultar eventualmente perturbadoras" -fs. 25.781 vta./25.782-.

El tribunal señaló que conforme quedó probado en la causa N° 13/84 el sistema implementado por el denominado Proceso de Reorganización Nacional fue el de un aparato organizado de poder, cuyo accionar respondió a una planificación metódica, y científicamente delineada que tenía en su vértice superior a los arquitectos del plan, autores de escritorio o mediatos.

Después de discurrir acerca de cómo se organizó ese plan en todo el territorio nacional, explicó que su efectividad demandó la coexistencia de ciertos factores: una dominación jerárquica con una fuerte concentración de poder, la fungibilidad de sus operadores en las escalas intermedias y bajas y la previsibilidad casi total de las consecuencias ante cada uno de los delitos que formaban parte de estas órdenes.

Así advirtió que, conforme las directivas impartidas, quienes en cada jurisdicción asumían la responsabilidad de identificar a las personas a detener eran los Comandos de cada cuerpo del Ejército, en el caso de Tucumán correspondía al III

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

Cuerpo, cuya jefatura estaba a cargo de Menéndez -cfr. fs. 25.783-

El a quo sostuvo que el cargo que ejercía implicaba el lugar de poder, decisión y dirección de ejecución del plan criminal, el que se realizaba conforme las directivas generales emanadas de la Junta Militar, así lo disponía el art. 12 del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional: El PEN -a cargo de un integrante de la Junta Militar- proveerá lo concerniente a los gobiernos provinciales, y designará a los Gobernadores, quiénes ejercerán sus facultades conforme a las instrucciones que imparta la Junta Militar, la que solo se reservaba el control del cumplimiento de los objetivos del proceso de reorganización puesto en marcha. A su vez el artículo 11 del Acta del Proceso de Reorganización Nacional decía: *"Los Interventores Militares procederán en sus respectivas jurisdicciones por similitud a lo establecido para el ámbito nacional y a las instrucciones impartidas oportunamente por la Junta Militar"*. -fs. 25783 vta.-

Establecido ello, advierto, de adverso a lo argüido por el recurrente, que el a quo al abordar la imputación de los hechos delictivos y la correspondiente responsabilidad penal que le cupo al imputado, si bien partió de la consideración del rol que efectivamente desempeñó dentro del plan de terrorismo de estado, examinó la relación concreta con los delitos cometidos en perjuicio de Marta Ángela López, Ceferina Rosa López, Juan Carlos

López, Ramón Francisco López, Hugo Alberto Díaz, Raúl Mauricio Lechessi, Diana Irene Oesterheld, Fernando Carlos Araldi, José Eduardo Ramos, Alicia Dora Cerrota de Ramos, Enrique Abdón Pastor Cerezo, Adriana Cecilia Mitrovich, Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba, Graciela Bustamante de Argañaraz, Ricardo Torres Correa, Carlos Román Apaza, Daniel Fontanarrosa, Joaquín Ariño, Ángel Mario Garmendia y Dante Edgardo Bordón.-

En cuanto al punto crucial de concreto agravio del casacionista, de que no ha podido determinarse cuál habría sido el aporte concreto efectuado por Luciano Benjamín Menéndez en cada uno de los casos, es dable señalar que tal planteo evidencia tan sólo un mero disenso de la parte con la sólida argumentación desplegada por el tribunal, fundamentos éstos que no han podido ser confutados.

En efecto, el *a quo* ha formulado una descripción concreta de la situación en la que se encontraba Menéndez en la mentada estructura de poder, habiendo señalado con precisión cuál fue su rol y explicitado en qué consistió la actividad ilícita que se le atribuyó.

Así, indicó que en la cadena orgánica de mandos, Menéndez pertenecía dentro de este engranaje al grupo de personas posicionadas en las escalas superiores, con un alto poder de decisión y mando sobre todo lo acontecido bajo su correspondiente jurisdicción. Recordó el tribunal que Luciano Benjamín Menéndez se desempeñaba como Comandante del IIIer. Cuerpo de Ejército

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

desde setiembre de 1975 a setiembre de 1979, responsable de la zona 3 comprensiva, entre otras provincias, a la de Tucumán.

Al abordar la multiplicidad de los delitos endilgados a Menéndez el *a quo* señaló que el aparato de poder que desarrolló sus tareas ilegales durante el gobierno de facto desplegó una serie de actividades que de manera directa o indirecta, provocaron una enorme cantidad de focos de peligro para los bienes jurídicos de más alta apreciación para nuestro digesto penal: la vida, la libertad y la integridad física.

Y puntualizó que su actividad se dirigió sistemáticamente a organizar una estructura que puso en peligro la vida y la libertad de los individuos y que se transformaron posteriormente en resultados típicos de muerte, lesiones, torturas, violaciones de domicilio y privación de libertad, entre otros.

Como es dable apreciar de lo expuesto *supra*, la conexión causal de las conductas atribuidas al imputado ha sido efectuada a la luz de la llamada "teoría del dominio del hecho mediante la utilización de aparatos organizados de poder", complementándose con la teoría de la imputación objetiva del hecho, a cuyo tenor, se coligió que en el abanico de los ilícitos endilgados a Menéndez se constataban los elementos sobre los que se cimienta dicha construcción teórica.

A este devenir, está claro que la imputación que recae sobre Menéndez parte del rol jerárquico que detentaba dentro de la estructura de represión instaurada mas reposa esencialmente en el conocimiento y voluntad incondicionada de llevar adelante la práctica sistemática de desaparición forzada de personas, impartiendo directivas a sus inferiores para que realicen la secuencia secuestros, torturas, desapariciones. Ordenes que implicaban el total desprecio de las garantías constitucionales.

De tal modo, no resulta plausible, pues conspira contra las reglas de la experiencia y el sentido común, que ignorase que sus aportes estaban direccionados al cumplimiento del mentado plan sistemático, antes bien, como dije *supra*, conocía y comprendía perfectamente el contexto de ilegalidad en el que se desenvolvía, habiendo podido evitar o hacer cesar, con tan sólo impartiendo una orden, cada uno de los resultados producidos en los casos investigados en la presente causa. Es decir, ninguno de estos hechos aberrantes podían ocurrir sin su conocimiento, voluntad, aquiescencia y autorización, en fin, sin su intervención a título de autor mediato, como bien quedó delineado en la sentencia.

Así las cosas, considero que las razones dadas por los judicantes para concluir como lo hicieron lejos de constituir, como aduce el impugnante, una argumentación tan sólo dogmática en el sentido de eminentemente teórica y basada en una responsabilidad objetiva, guardan relación directa con los eventos recreados a lo largo del debate, base fáctica que se ha

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

erigido como corolario ineludible de un examen crítico de los elementos convictivos que emergen del juicio. En otras palabras, las conclusiones a las que se arriba derivan "necesariamente" de las pruebas invocadas en su sustento, pruebas que obviamente excluyen que los hechos hayan podido ser de otro modo, que es lo que en definitiva identifica al principio de razón suficiente.

Ergo, los extremos fácticos de la imputación delictiva han quedado acreditados con el grado de certeza apodíctica que una condena requiere.

Y no empee a tal colofón, la circunstancia alegada por la defensa de que los testigos Martín y Jerez habrían recordado sucesos que nunca antes habían sido referidos o los habrían alterado, pues el recurrente siquiera se ha encargado de precisar en qué consistirían esas supuestas contradicciones, habiéndose sólo limitado a señalar de modo abstracto tal objeción.

No obstante, resulta pertinente aclarar que la verosimilitud del relato no significa inexorablemente que el testigo deba brindar una versión de los sucesos por él percibidos de modo monocorde y lineal, sin variación alguna, pues ello podría causar una impresión dudosa en el juzgador ya que no consulta las reglas del recto pensamiento humano y de la experiencia común.

Pretender una recreación perfecta y detallada sin mínimas fisuras en el relato no sólo conspira contra la propia

esencia de la prueba testimonial, caracterizada precisamente por su espontaneidad y limitada por la posibilidad concreta de cada persona de rememorar una situación, sino que deviene casi una utopía ya que las percepciones humanas pueden alterarse en virtud de las sensaciones vividas en el momento y después, al evocarlas, por las huellas que imprime en la memoria, el transcurso del tiempo.

Ello es así, máxime aún, tratándose como en el *sub judice* de hechos que envuelven momentos de terror y que su reminiscencia por parte de quienes los padecieron significa reeditar ese sufrimiento: las condiciones indignas que debieron soportar y los tormentos a los que fueron sometidos, con las implicancias que ello conlleva.

Sufrimiento que, si bien es imposible olvidar, es elaborado de disímiles modos según la personalidad del individuo y la magnitud de lo vivenciado y que, ciertamente incide a la hora de recrear lo ocurrido y las sensaciones sobre ello. A lo que cabe adunar la incontrastable realidad de que desde el acaecimiento de los eventos han transcurrido más de treinta años.

Todas estas circunstancias no deben ser soslayadas del examen crítico al que se somete un testimonio a fin de aquilatar su mayor o menor fuerza convictiva en el caso concreto.

Y ello se verifica en la especie, toda vez que el *a quo*, como expresé, *ab initio*, ha sopesado en forma conglobada y de conformidad con la sana crítica los testimonios rendidos con indicios y otros elementos probatorios recabados, lo que ha

permitido arribar al juicio de reproche que se le formuló al imputado. Propongo pues, con sustento en lo expuesto, el rechazo del presente agravio.

6- Valoración de la prueba. Prueba testimonial.

En el presente acápite he de abocarme al análisis del planteo -estrechamente vinculado con el anterior- referido a la valoración atribuida a la prueba testimonial.

Adelanto desde ya que dicho agravio no podrá prosperar pues el tribunal ha procedido con arreglo a los principios que informan el sistema de libres convicciones, siendo su decisión consecuencia de un razonamiento lógico deductivo que comprende todo el material probatorio erigido en el debate.

No se soslaya que la mayoría de los testigos son víctimas de los hechos investigados -de ahí que se los llame "necesarios"- o bien, familiares de ellos, mas tal condición no enerva *per se* la verosimilitud de su relato, si va acompañado, como en el caso, del compromiso del testigo con la búsqueda de la verdad, mostrándose sus dichos veraces y coherentes y por ende, idóneos para formar convicción.

En otras palabras, tal extremo no resulta óbice para sustentar certidumbre suficiente en el juzgador si, como en el caso, la sinceridad de los testigos emana de la relación de los hechos y de las respuestas lógicas y coherentes ante un exhaustivo interrogatorio, y si la impresión subjetiva reposa

también en elementos objetivos: la credibilidad del discurso y las contestaciones razonables a las preguntas que pusieron a prueba la verosimilitud del relato, a lo que debe adunarse la concordancia con los resultados que arrojan otros elementos de prueba e indicios valorados en su conjunto.

Dicho confronte permite al juzgador formar convicción absoluta cuando, como en el caso, el testimonio se ve fortalecido y corroborado con el resto del acervo cargoso.

Resulta oportuno traer a colación lo sostenido por el Tribunal Internacional para la ex- Yugoslavia en cuanto a que en la valoración de los testimonios orales, bien debe prestarse consideración al tiempo transcurrido desde el acaecimiento de los hechos y su posible impacto en la precisión de los dichos y que por tanto, la existencia de discrepancias menores no desacreditan necesariamente el testimonio (cfr. TIPY, "Prosecutor v. Momcilo Perisic", parágrafo 23, rta. el 6/9/11, cit. *in re* "Brusa, Víctor Hermes y otros s/ rec. de casación" causa n° 12314, rta. el 18/5/12, reg. n° 19.959 de la Sala II de esta CFCP).

De la lectura de la sentencia, es dable observar que los testigos han realizado una descripción de sus agresores que ha permitido su identificación, ora porque han podido ver en algún instante sus rostros, ora por haber escuchado su voces, ora porque los conocían -cfr. lo declarado por el testigo Oscar E Conte, quien expresó que [durante el secuestro] "el que le pegó fue un gordo grande pelirrojo, que había uno que le pegaba cuando estaba tirado en el piso y tenía tonada cordobesa", obrante a fs.

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

25.630 vta./25.634 vta.-; lo declarado por el testigo Chamatrópulos quien reconoció a Luis De Cándido, fs. 25.676/25.678 vta.

Todos ellos han proporcionado versiones que resultan consistentes y convincentes para probar los sucesos acaecidos.

Las declaraciones, en lo sustancial, no presentan fisuras relevantes ni incoherencias sólo cierta matización, a mi ver, plausible, que lejos de denotar mendacidad revela la espontaneidad con la que se manifestaron los deponentes en su evocación de la dinámica de los eventos, atribuyéndose las diferencias menores a un olvido de detalles debido al transcurso del tiempo, que en sí mismas no resultan significativas ni tienen relevancia alguna. Y ello es así pues no afectan lo axial de sus dichos, cuyo contenido, destaco, se dirige unívocamente en dirección de la existencia del hecho y la intervención en él de sus responsables, en lo que aquí atañe, de Luciano Benjamín Menéndez.

Como expresé precedentemente, pretender un recuerdo absoluto acerca del hecho con todos los detalles circundantes no resulta plausible, menos aún que las supuestas falencias alegadas se traduzcan en una duda acerca de hechos que efectivamente ocurrieron y del grado de participación que en ellos le cupo al imputado. A menos que se consideren mendaces a todos los que han

depuesto en este juicio, repárese en el volumen de las declaraciones prestadas, que ascienden a 63 testigos.

En lo que respecta a la crítica al testimonio prestado por Juan Carlos Clemente y a la documentación aportada por éste, advierto que durante la audiencia de debate todas las defensas se opusieron a la incorporación de dicha documental en el entendimiento de que el término de ofrecimiento de prueba había precluído, de que los imputados no habían sido indagados sobre esa documental y por ende, que no habían podido hacer su descargo (conf. acta de debate obrante a fs. 25.570).

El órgano colegiado resolvió la cuestión planteada con sustento en el art. 388 del CPPN que prevé que si en el curso del proceso se tuviera conocimiento de nuevos medios de prueba manifiestamente útiles, el tribunal podrá ordenar su recepción. Ello sin perjuicio -como bien aclaró el *a quo*- de que los hechos investigados, por los que fueron indagados los imputados, siguen siendo los mismos, como así también se mantienen las imputaciones tal como han sido formuladas al momento de la elevación de la causa a juicio. A ello adunó que el temperamento adoptado recepta los lineamientos desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia probatoria, advirtiéndole finalmente que las partes pueden controlar perfecta y regularmente dicha prueba, no resultando por ende, vulnerado derecho constitucional alguno -cfr. fs. 25.570 vta.-

Habida cuenta de lo expuesto, como resulta asequible, el planteo que ahora introduce el recurrente es una reedición del

esbozado durante el debate, el que mereció por parte del *a quo* debido tratamiento y correcta solución.

El digesto adjetivo contempla precisamente la hipótesis de autos, al prever en el art. 388, como otra manifestación de las facultades autónomas de investigación otorgadas al tribunal de juicio –como una actividad típica del sistema inquisitivo que aún exhibe nuestro proceso mixto–, la de disponer aun de oficio, la recepción de nuevos medios de prueba manifiestamente útiles cuyo conocimiento se tuviera en el curso del debate, pudiendo asimismo las partes sugerirlas.

Esto último, se infiere del uso del adverbio "aun" utilizado como sinónimo de también o inclusive, lo que denota que nada obsta a que las partes puedan proponerlas (cfr. en este sentido, D'Albora Francisco, *Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado*, octava ed., corregida, ampliada, actualizada, Abeledo Perrot, Bs. As., 2009, p. 692).

Es decir, con fundamento en la norma el tribunal se halla habilitado a disponer la producción de nuevos medios de prueba manifiestamente útiles (cfr. Navarro Rafael- Garay, Roberto, *Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial*, 2da. edición, Hammurabi, Bs. As., 2006, pp. 1106 y 1107).

Allí se aclara que la expresión pareciera transmitir un límite a la facultad, cual es que la prueba faltante y que se

posibilita adquirir para el proceso no debe ser cualquiera sino tan sólo aquélla que resulte evidentemente vital como producto de la contradicción ocurrida durante el curso del debate.

Asimismo advierten los autores citados que el sistema no ha variado, sigue siendo inquisitivo y que el legislador ha colocado el privilegio de la verdad real por encima del derecho constitucional de defensa en juicio.

En consecuencia, considero que ha sido bien aplicado el art. 388 del ritual, no vislumbrándose afectación alguna a la garantía de la defensa en juicio pues no se trata de un hecho nuevo que incida en la imputación discernida y deje por ende, indefenso al imputado, antes bien es una documentación respaldatoria de los dichos del testigo Clemente que, por lo demás, ilustra y clarifica aún más los testimonios en esa misma dirección, que ya venían receptándose. Repárese que es una prueba documental de las pocas que han pervivido a un centro clandestino de detención, dato éste no menor si se tiene en cuenta cuál era el *modus operandi* a la sazón con relación a este tipo de medios probatorios.

En cuanto al mérito otorgado, observo que el tribunal abordó puntualmente esta cuestión a través de una argumentación sólida brindando las razones por las que consideró esencial la documentación aportada por el testigo Clemente.

En efecto, señaló que "la documentación perteneciente al D2 (inteligencia) aportada en el curso de la audiencia por el testigo Clemente es una prueba concluyente para múltiples hechos

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

materia de la presente causa, en tanto permite tener por acreditada la existencia del centro clandestino de detención Jefatura de Policía en la provincia de Tucumán y la existencia de un colectivo de personas integrante de las fuerzas militares y de seguridad del Estado nacional y provincial que, actuando en su ámbito, investigaron, secuestraron, torturaron y asesinaron a aquellas personas que reputaban como blancos y que debían ser eliminados en el marco del terrorismo de Estado instaurado o, inclusive, en el curso de su instauración".

"Sobre la cuestión cabe tener presente que la documentación provista por Clemente tiene alto valor suasorio, tanto porque el testigo ha estado en Jefatura de Policía, y este extremo no ha sido negado por ninguna de las partes; como en razón de que se han peritado firmas de Albornoz obrantes en algunas de las piezas del material documental que se menciona y su autenticidad ha quedado probada."

"No obstante, la relevancia del material documental que se menciona trasciende los confines de estos autos en la medida en que, y en lo que constituye un hallazgo inhabitual en las causas argentinas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos en el marco de la criminalidad estatal organizada, ilustra acabadamente el accionar del Estado que pervierte su carácter de entidad destinada a organizar y preservar la vida social. La singularidad del hallazgo viene dada

por la circunstancia de que el ocultamiento y la eliminación sistemática de rastros del accionar delictivo constituía un componente siempre presente de dicho accionar; componente que, no obstante, en esta causa, la documentación aportada por el testigo Clemente ha permitido atenuar abriendo camino a la reconstrucción de la verdad real" -vid. fs. 25.728 vta./25.729-.-

De lo expuesto se colige que las consideraciones esbozadas por el *a quo* sobre el material probatorio aportado en la causa se erigen consistentes y lógicas a la luz de la magnitud de los hechos investigados y especialmente teniendo en cuenta que se trata de delitos cuyo modo de ejecución, como expuse *supra*, no deja rastros o éstos se suprimen, destruyéndose deliberadamente documentos, como el propio testigo Clemente aseveró que así sucedía, habiendo manifestado que a la documentación aportada la obtuvo cuando llegó la orden de desmantelamiento, pues presupuso que podía llegar a ser relevante.

En este sentido, considero pertinente evocar su relato. El testigo señaló que "cuando lo pusieron a manejar biblioratos, viendo que algunos papeles eran importantes decidió sacarlos. Dijo que la oficina tenía la tarea de archivar el material en biblioratos que estaban en estantes y tenían títulos, los papeles que decían memorándum los ponía en memorándum, o listas de personal, lo iba clasificando según los biblioratos. Dijo que no tuvo tiempo de revisar el listado ni ningún papel. Dijo que el traslado no duró más de una semana, cuando no hubo que mas sacar,

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

él enterró los papeles en un mueble de mampostería en su cama, en su casa de soltero y después cuando se casó y se fue a vivir a su casa de casado, la enterró en un contrapiso y la logró sacar hace 2 o 3 años porque hicieron una refacción de la casa, dijo que nunca revisó estos papeles. Cree que había 20 biblioratos pero no es algo que él tenga definido, se acuerda estantes con biblioratos. Dijo que en Jefatura reconoció voces y que no sabe por qué está vivo, dijo que no conserva la credencial de la policía, tiene idea que cuando presentó la renuncia en el 84 entregó su credencial de policía. Recordó que sacó la documentación y se la puso en la pierna con la media y así la llevaba, tenía el presentimiento que eran importantes y por eso se quemaban, había gente que seleccionaba y otra que quemaba porque había una fogata, envolvió la documentación y la guardó, que para guardarla usó unas bolsitas anti humedad, eso más plástico, más papeles, más papeles y así los envolvió. Dijo que cuando se casó y se cambió de casa tuvo que hacer todo el envoltorio de nuevo y la puso en un contrapiso. Manifestó que no existió la amenaza "te voy a matar" pero uno entiende cuando los mensajes son claros, lo fueron a visitar y le preguntaban donde estaba Juan Martín y le decían "lo vamos a hacer boleta". Trabajó hasta el año 77 que se produjo el desmantelamiento, dijo que no sabe cuántos cadáveres se entregaron a los familiares, el recibía papeles que decían memorándum, sacaba la carpeta y la ponía en la

carpeta, nadie más sabía que él había llevado esos papeles a su casa, dijo que nunca fue amigo de De Cándido que sólo tenían una relación de trabajo. Respecto a la documentación que presentó al tribunal, dijo que esa era la única que tenía en su poder, no hizo reserva de ninguna otra documentación, hace dos años cuando empezaron a realizarse juicios, vio la posibilidad de presentarla, teniendo la documentación a mano, sacó la primera hoja que era una lista y la mandó a un organismo de derechos humanos de la procuración en forma anónima en Buenos Aires, dijo que cree que nadie más tenía documentación..." -cfr. fs. 25.718-.

En otro andarivel, también cabe desechar la censura de la defensa sobre el testimonio de Juan Martín Martín, habida cuenta de que la circunstancia de que para el recurrente no resulte admisible que los represores "hayan paseado al testigo" no alcanza para desvirtuar la vasta declaración de aquél obrante a fs. 25.658 vta./25.669, a cuyo tenor brinda una acabada composición del *factum* objeto de este juicio.

Testimonio éste que fue reputado como categórico y contundente por el *a quo* -cfr., a modo ilustrativo, fs. 25.766 vta., 25.768 vta., 25.722 vta., 25.806 vta., entre otros pasajes de la sentencia que dan cuenta de la adecuada apreciación de dicha prueba.

Tampoco prosperará la crítica esbozada sobre la valoración del testimonio de Domingo Antonio Jerez, al que calificó como un verdadero "cuentito", pues sólo traduce su disconformidad con el mérito otorgado por el tribunal sin que

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

haya aportado elementos concretos con virtualidad suficiente para sustraerle verosimilitud a sus dichos, habiendo soslayado por lo demás, que el *a quo*, brindó una respuesta sólida y lógica al símil planteo elaborado por la defensa de los imputados de Cándido, durante el transcurso de la audiencia de debate. Oportunidad en la que además se ordenó que se adopten todos los recaudos necesarios para la inmediata custodia y ayuda psicológica del testigo Jerez -cfr. fs. 25.622 vta./25.623-.

Al respecto no resulta ocioso señalar que los testigos, muchos de ellos víctimas del proceso represivo de aquella época, merecen por parte de la judicatura una mayor y más eficiente protección, a fin de que, más allá de la revictimización que su declaración implica, puedan expresarse libremente. En este sentido, cabe destacar la labor del tribunal, ya en su momento, al disponer el resguardo de la seguridad personal del testigo Jerez, en consonancia con las directrices que emanan de las Reglas Prácticas, que fueron dictadas recientemente por esta Cámara (Regla Quinta de la Acordada 1/12).

Resta aclarar que no obsta a la credibilidad de la deposición la alegación defensiva de que no se hubo acreditado la condición de soldado del declarante, si ello no ha merecido para el tribunal duda alguna que amerite acudir a otros medios probatorios para corroborar tal *status*.

Finalmente resulta estéril para enervar la estabilidad del testimonio y por ello deviene insustancial la crítica - desvinculada con la acreditación de la imputación y la veracidad del testimonio- formulada a la extensa y sólida declaración brindada por Mirtha Elizabeth Mántaras, cuya reseña obra a fs. 25.642 vta./25.646 no advirtiéndose de su lectura ninguno de los déficits que el defensor le atribuye.

7- Tampoco tendrá favorable acogida el agravio relativo a la afectación del principio de contradicción y del derecho a la defensa en juicio, pues contrariamente a lo esgrimido por el recurrente, el tribunal ha considerado el alegato de esa parte, observándose en diferentes pasajes de la sentencia, una argumentación que atiende a los planteos introducidos por la parte en la oportunidad del art. 393 del CPPN.

Por lo demás, el planteo esgrimido se exhibe ambiguo e impreciso, no alcánzandose a vislumbrar cuál sería el perjuicio concreto ocasionado a esa parte pues no se ha señalado que alegación defensiva pertinente para una correcta solución del caso fue soslayada arbitrariamente por el tribunal.

8- Corresponde abordar ahora el agravio instaurado bajo la rúbrica "indebida extensión de la responsabilidad penal" mediante el que cual la defensa objetó, por ser ajeno al Código Penal Argentino, la aplicación de la categoría de autor mediato en el dominio del hecho conforme a la teoría de Roxin; adelantando desde ya que este planteo no podrá prosperar.

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

Ciertamente los jueces de la instancia anterior aplicaron el modelo dogmático de autoría mediata por aparato organizado de poder, al analizar y definir la responsabilidad penal que le cupo al imputado en el sub judice, no advirtiéndose de dicha inteligencia vicio error alguno en la aplicación de la ley sustantiva.

Dicho esquema fue diseñado por Claus Roxin como una de las tres formas que reviste el dominio del hecho (dominio del hecho por acción, por voluntad y dominio del hecho funcional). El dominio por voluntad -que es el que adquiere relevancia en este contexto- puede darse en tres modalidades; se puede coaccionar a quien actúa, se lo puede engañar , o puede tratarse de un sujeto que puede intercambiarse libremente. Se alude así, al dominio de voluntad por coacción, por error o en virtud de aparatos organizados de poder.

Esta última, también denominada por Roxin "dominio por organización", consiste en "el modo de funcionamiento específico del aparato....que está a disposición del hombre de atrás" , esquema que funciona sin que sea decisiva la persona individual de quien que ejecuta, de modo prácticamente automático (cfr. Kai Ambos, "Dominio del hecho por dominio de voluntad en virtud de aparatos organizados de poder". Una valoración crítica y ulteriores aportaciones., Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año 5 n° 9-A Ad Hoc, Bs As. 1999, pp. 367 y ss.).

Dicha teoría se encuentra reconocida por la doctrina nacional, sin que se verifique obstáculo para su aplicación en nuestra legislación.

Con relación a este tema ya me he expedido al votar *in re* "Greppi, Néstor Omar y otros s/rec. de casación", causa n 13.667, reg. n 1404/12, de fecha 23 de agosto de 2012, de la Sala IV de esta Cámara.

Allí expresé que, tal como lo explica Zaffaroni en su obra, el Código Penal argentino, además del concepto de autor que surge de cada uno de los tipos penales y del que se obtiene por aplicación del dominio del hecho (como dominio de la propia acción), el artículo 45 del Código Penal también se extiende a los casos de dominio funcional del hecho, en la forma de reparto de tareas (coautoría por reparto funcional de la empresa criminal) y de dominio de la voluntad (autoría mediata).

Por ende, siguiendo al mismo doctrinario, autor individual es el ejecutor propiamente dicho; coautor por reparto de tareas son quienes tomasen parte en la ejecución del hecho, y el dominio del hecho se asume bajo la forma de dominio funcional del hecho; autor mediato es quien se vale de otro para realizar el tipo penal, agregando que existe una forma particular de autoría por dominio del hecho y que consiste en el dominio por fuerza de un aparato organizado de poder -donde el instrumento no obra ni por error ni por coacción ni justificadamente- donde los conceptos referidos al hecho individual no son de aplicación cuando se trata de crímenes de Estado, de guerra ni organización

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

(Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, *Derecho Penal, Parte General*, Ediar, Buenos Aires, 2.000, pp. 745 y ss.).

La autoría mediata a través de aparatos o estructuras de poder organizadas explica con claridad la voluntad de dominio del hecho en casos como el que se encuentra probado en la presente causa, donde los hechos que configuran delitos fueron llevados a cabo por aparatos organizados de poder.

Por ello, al encontrarse acreditado en esta causa que los hechos materia de juzgamiento se enmarcan en el plan sistemático, clandestino y criminal orquestado desde las máximas esferas de las autoridades de facto de la última dictadura militar, el caso se ajusta a los presupuestos que deben estar presentes en la teoría de Roxin para aplicar la autoría mediata por aparatos de poder organizados. Dichos presupuestos son: a) dominio de organización; b) margen de ilegalidad; c) fungibilidad del ejecutor.

El dominio por organización se explica a partir del posicionamiento del agente sobre el funcionamiento del aparato de poder, en el que el sujeto de atrás -también llamado de escritorio- es el que mayor dominio ejerce sobre la vida misma de la organización, emitiendo o transmitiendo órdenes que atraviesan distintos eslabones de la cadena de mando que caracteriza la vertical estructura de poder, confiando su cumplimiento con

independencia del conocimiento que se tenga sobre el agente que, en definitiva, la ejecutará.

Esto implica que la lejanía del autor mediato con la ejecución misma de la acción típica, incrementa su responsabilidad en forma inversa a aquélla distancia, por cuanto la ausencia del autor mediato en la materialización del hecho ilícito se ve neutralizada por el dominio que ejerce sobre el aparato organizado, siendo éste el que posibilita el cumplimiento del acontecer delictivo.

Por esa razón, en el modelo teórico definido por Claus Roxín, la responsabilidad penal se incrementa según el grado de dominio que se verifica dentro de la estructura del aparato de poder del que emana, transita y se cumple la orden de llevar a cabo el delito.

El propio Roxin reafirmó las conclusiones a las que arribó el Tribunal Regional de Jerusalén en el juicio a Eichmann. En él, se aplicó este esquema dogmático y se dijo que “[1]a medida de responsabilidad más bien aumenta cuando más alejado se esté de aquel que con sus manos hace funcionar el arma asesina y más se acerque uno a los supuestos superiores de la cadena de mando” pues apelando al concepto de “crímenes en masa”, se dijo que “en estos crímenes de proporciones gigantescas y múltiples ramificaciones..., en los que han participado muchas personas en distintos puestos de la cadena de mando (planificadores, organizadores y órganos ejecutores de distinto rango) no es adecuado recurrir a aplicar los conceptos comunes del inductor y

*del cómplice"* (Claus Roxin, *Autoría y Dominio del Hecho en el Derecho Penal*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 1998, p. 272).

Lo decisivo, entonces, es que *"quien es empleado de una maquinaria organizativa en cualquier lugar, de un[a] manera tal que pueda impartir órdenes a sus subordinados, es autor mediato en virtud del dominio de la voluntad que le corresponde si utiliza sus competencias para que se cometan acciones punibles. Que lo haga por propia iniciativa o en interés de instancias superiores y a órdenes suyas es irrelevante, pues para su autoría lo único decisivo es la circunstancia de que puede dirigir la parte de la organización que le está subordinada sin tener que dejar a criterios de otro la realización del delito"* (ob. cit. p. 273/274).

El modelo de Roxin, a su vez, requiere que el aparato de poder funcione al margen de la legalidad, fuera del orden jurídico, pues de otra forma, la mera orden de llevar a cabo una acción ilegal, no explica el dominio sobre el acontecer delictivo que se requiere. Ello es así, en tanto, como lo explica Roxin, cuando en un Estado de Derecho una autoridad determina o instruye a sus subordinados a cometer acciones antijurídicas, ello ha de ser valorado siempre como *"inducción"* pues todo el aparato se mueve aquí bajo los cauces del Derecho. Es decir, una instrucción antijurídica en un Estado de Derecho no pone en marcha el aparato

o la organización en movimiento, pues no se trata de una acción de la maquinaria de poder, sino de una iniciativa particular que no actúa con el aparato sino contra él.

Finalmente, se exige la fungibilidad de quien materializa o ejecuta la orden. El sujeto, que puede resultar desconocido por el autor mediano y sustituible por cualquier otro integrante de la organización, actúa libre y responsablemente. De modo que, si bien ejerce el dominio del hecho al concretar la acción típica, antijurídica y culpable, se presenta como un engranaje sustituible -penalmente responsable- de la maquinaria de poder a la que pertenece (cfr. "Greppi" antes cit.).

En definitiva, la teoría de Roxin se erige así como respuesta jurídica a aquellas situaciones en las que no media dominio del hecho por medio de dominio de la voluntad en virtud de acción o de error. En este sentido, advierte que los "crímenes de guerra, de estado y de organizaciones -como los que aquí se analizan- no pueden aprehenderse adecuadamente con los solos baremos del delito individual. De donde se deduce que las figuras jurídicas de autoría, inducción y complicidad, que están concebidas a la medida de los hechos individuales, no pueden dar debida cuenta de tales sucesos colectivos, contemplados como fenómenos global" (cfr. Roxin, Claus, *Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal*, Traducción de la séptima edición alemana por Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo, Madrid 2000, p. 270).

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

De lo expuesto, se colige que el modelo teórico de la autoría mediata por aparato organizado de poder, se encuentra reconocido por nuestra doctrina nacional. Además, constituye una herramienta dogmática que explica, por el contexto en el que se verificaron los hechos, el reproche penal de autoría y/o coautoría en los términos del art. 45 del C.P. que llevó a cabo el tribunal de juicio al condenar a los inculpados.

En efecto, el tribunal *a quo* tuvo por acreditada, sin que se advierte déficits de fundamentación, la existencia del aparato organizado de poder estatal del que formaron parte los imputados para llevar adelante los hechos por los que fueron acusados. El mismo, como se advierte, además de funcionar fuera de los márgenes de la legalidad, estaba integrado por militares y policías provinciales. Los primeros, ocuparon posiciones burocráticas de privilegio a partir de las cuales emitieron y transitaban órdenes ilegales que desencadenaron los hechos juzgados. Los segundos, y con respecto a los policías provinciales imputados, integraron el grupo de personas que llevaron a cabo las acciones criminales verificadas.

A partir de la posición de privilegio que detentaba se le atribuyó la calidad de autor mediato pues tuvo por comprobado que "en la cadena orgánica de mandos, Menéndez pertenecía dentro de este engranaje al grupo de personas posicionadas en las escalas superiores, con un alto poder de decisión y mando sobre

todo lo acontecido bajo su correspondiente jurisdicción.”-cfr. fs. 25.786 vta./25.787-

A la luz de lo expuesto cabe afirmar la coautoría mediata de Luciano Benjamín Menéndez en los hechos que a dicho título le fueron reprochados, habida cuenta de que no se ha acreditado su intervención directa en cada uno de los eventos acaecidos en el centro clandestino denominado “Jefatura de Policía” empero sí y esto es lo determinante, se estableció que detentaba un dominio jerárquico y fáctico del centro de detención donde aquéllos se llevaron a cabo, partiendo de la premisa de que el nombrado se desempeñó como Comandante del IIIer. Cuerpo de Ejército desde setiembre de 1975 a setiembre de 1979, responsable de la zona 3 comprensiva, entre otras provincias, de la de Tucumán, de conformidad con la estructura y los organigramas delineados en esa época.

Como corolario, considero que no constituye crítica suficiente de la teoría observada en la sentencia, la alegación defensiva de que se asienta en criterios de responsabilidad objetiva ajenos a nuestro ordenamiento penal.

Por ello, no se aprecia error *in iudicando* alguno por parte del tribunal *a quo* al definir la calidad de autor en los términos del art. 45 del Código Penal por el que debe responder el inculcado por los hechos por los que fue juzgado y condenado.

9- El argumento defensivo de la existencia de un error de prohibición con incidencia en el plano de la culpabilidad tampoco ha de recibir de mi parte favorable acogida.

Del examen de los determinantes elementos convictivos erigidos durante el debate es dable predicar del imputado que obró con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, no alcanzando para enervar tal aserto las alegaciones esbozadas por la esforzada defensa en torno a la existencia de un error de esa clase, sin haber especificado por lo demás, si era directo o indirecto.

El agravio del casacionista nos sitúa en el plano de la culpabilidad, pues es aquí donde el alegado error encuentra su ámbito de aplicación.

Cabe evocar que la culpabilidad, como el juicio de reproche que se le hace al autor de un injusto por no haberse motivado conforme a la norma, se integra con los siguientes elementos: imputabilidad, el conocimiento potencial de la antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta, de modo tal que cuando alguno de ellos falte estaremos en presencia de una causa de inculpabilidad y por ende no se podrá predicar respecto del injusto del autor su culpabilidad.

En lo que aquí interesa, cabe destacar que la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad decae cuando concurre un error de prohibición, que es el que recae sobre el conocimiento o la comprensión de la ilicitud, que puede ser directo (cuando recae sobre el conocimiento de una norma prohibitiva), e indirecto (cuando recae sobre una causa de

justificación), y a su vez, vencible o invencible, según haya podido ser superado o no, análisis que ha de emprenderse en el caso concreto recurriendo al estándar relativo al deber de examen por parte del autor, característico del delito culposos.

Así, los medios para evitar un error de prohibición son reflexión e información.

La vencibilidad depende de tres presupuestos que se basan uno en el otro: el sujeto tiene que haber tenido un motivo para reflexionar sobre una posible antijuridicidad de su conducta o para informarse al respecto.

Cuando exista un motivo, el sujeto o bien no debe haber emprendido ningún tipo de esfuerzos para cerciorarse o bien éstos deben haber sido tan insuficientes que sería indefendible por razones preventivas una exclusión de la responsabilidad. Cuando el sujeto pese a existir un motivo, se ha esforzado en pequeña medida por conocer el Derecho, su error de prohibición es no obstante vencible sólo cuando unos esfuerzos suficientes habrían llevado a percatarse de la antijuridicidad (cfr. Roxin, Claus, *Derecho Penal, Parte General, T I, Fundamentos de la estructura del delito*, Ed. Civitas, Madrid, 1º ed., 1997, reimpresión 1999, pp. 884 y ss.).

En cuanto al motivo para cerciorarse, dicho autor aprecia una razón para examinar la situación jurídica básicamente sólo en tres grandes grupos de casos: cuando al propio sujeto le han surgido dudas, cuando no tiene dudas pero se mueve en un sector regulado y cuando el sujeto es consciente de que su

conducta perjudica a particulares o a la colectividad.

Este ultimo supuesto se formula expresando que la infracción de "normas sociales elementales" o del orden moral" hace vencible un error de prohibición. Ello es correcto —estima Roxin— en cuanto que la conciencia de perjudicar gravemente suele incluir en sí misma la conciencia de la contrariedad ético social a valores.

Lo cierto es que como bien destaca dicho autor, en el terreno del derecho penal nuclear es poco frecuente un error de prohibición invencible, porque el conocimiento de las circunstancias del hecho la mayoría de las veces incluye aquí sin más el dolo de perjudicar.

No hay dudas, ante el consenso doctrinario y jurisprudencial, que el error de prohibición directo resulta manifiestamente improcedente cuando se trata de hechos aberrantes, como los juzgados en la especie, cuya ilicitud es a todas luces evidente. Es decir, la dañosidad individual y social de dichas acciones son reconocibles sin más, sin esfuerzo alguno.

Por ende, no resiste el menor análisis lo argüido por la defensa de que Menéndez no podía comprender la ilicitud de los hechos al haberse motivado de acuerdo a la ley militar de esa época, pues no resulta plausible sostener que el alegado adoctrinamiento militar hubiera suprimido la capacidad de comprensión de la antijuridicidad de sus acciones —que a la sazón

se encontraban tipificadas como delitos en el CP- a tal punto de haberle obstado a que pudiera reconocer como delitos, las graves violaciones a los derechos humanos que aquellas implicaron.

Por su parte, el error de prohibición indirecto es el que recae sobre la existencia de una causa de justificación, es decir, sobre la permisión de la conducta típica, de ahí que se lo denomine error de permisión.

Esta hipótesis, que no es infrecuente incluso en los tipos más importantes del Derecho Penal nuclear, concurre cuando el sujeto activo conoce que su conducta esta prohibida por un tipo penal pero estima que se encuentra justificada por el ordenamiento jurídico.

Este error puede manifestarse de dos formas; mediante la falsa suposición de que existe una causa de justificación que la ley no reconoce (o sobre los límites de ésta) y mediante la falsa suposición de los presupuestos objetivos de una causa de justificación.

Cabe recordar que Menéndez fue imputado de una cantidad importante de delitos a título de autor mediato en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, emprendido desde el propio estado.

En tal esquema, considerando que la hipótesis introducida por la defensa intenta discurrir sobre un supuesto de error de permisión, habida cuenta del grado de educación de Menéndez, no se vislumbra circunstancia alguna que permita presuponer válidamente que hubiera intervenido en los sucesos

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

endilgados en la falsa creencia de que existía una causa de justificación que legitimaba su marco de actuación.

En definitiva, considero que el error de prohibición en cualquiera de sus acepciones no resulta admisible en el caso de los crímenes contra la humanidad en los que su comisión implica *per se* el total desconocimiento desde el propio Estado de los derechos fundamentales de las personas, que ante todo forman parte de principios inderogables y universales del derecho internacional *–jus cogens–*.

Como epílogo, no puede prosperar el planteo de la defensa pues no se advierte de autos ni tampoco la parte lo ha alegado ninguna circunstancia personal del imputado que haga reflexionar acerca de la posibilidad de que existan causas de exclusión de la imputabilidad, única hipótesis posible en el *sub judice* para que se enerve el reproche por el injusto cometido, a tenor del art. 34, inc. 1 del Código Penal.

En virtud de las consideraciones expuestas propicio al acuerdo el rechazo del recurso de casación deducido por la defensa de Menéndez, con costas y la homologación de la sentencia condenatoria dictada a su respecto (punto dispositivo VII) *–arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y 531 del CPPN–*.

**II-Recurso de casación de la defensa de Roberto Heriberto Albornoz**

1-Liminarmente, cabe aclarar que el primer agravio

planteado por la defensa en su exordio, centrado en lo dispuesto en el punto XII de la parte resolutive de la sentencia impugnada en cuanto se revocó la prisión domiciliaria de su defendido, sin perjuicio de la opinión del suscripto en precedentes que intervine (cfr. causa nº 15.077 "Pascarelli, Hugo Ildebrando s/ recurso de casación" (reg. 217/12, rta. 6/3/12; "Guglielminetti, Raúl Antonio s/recurso de casación", causa nº 15212, rta. el 18/04/12, reg. nº 555/12, ambas de la Sala IV, entre otros) en el *sub lite*, la cuestión ya fue objeto de tratamiento y solución por parte de esta Sala III con integración parcialmente distinta de la actual, bajo las previsiones de la ley 26.374 (cfr. resolución de fecha 16 de febrero de 2011, reg. 81/11, decisión que se encuentra firme).

2-Corresponde abordar el planteo del impugnante relativo a la aplicación del delito previsto en el artículo 210 del Código Penal por considerar que no puede concurrir idealmente con otros hechos que encuentran cada uno de ellos su propia adecuación legal.

Es dable destacar que la circunstancia de que los hechos planeados en el seno de la organización delictiva se hayan consumado no obsta a la aplicación de la figura de asociación ilícita, tipo penal éste que, como es sabido, prevé un delito autónomo, formal y de peligro abstracto que afecta el bien jurídico orden público y que, por tanto, encuentra su perfección en el *iter criminis* en el momento mismo en que los autores se reúnen para delinquir, prolongándose la consumación

como delito permanente; y con prescindencia, claro ésta, de los injustos individuales que mediante ella se cometan.

En esta inteligencia, cabe afirmar su autonomía respecto de aquéllos y en este sentido el concurso real se erige como la solución adecuada para calificar el modo en que concurren los diferentes injustos (art. 55 del CP).

En tal orden de ideas, no resulta ocioso señalar que *"la doctrina tradicional argentina sentó, en su momento, la idea –que hasta hoy se mantiene inalterada– de que la asociación ilícita es un delito permanente, que se consuma con el mero acuerdo entre sus miembros, sin que dicha consumación dependa de que se llegue a la efectiva comisión de los delitos que constituyen el objeto de la asociación; tales delitos, en caso de que lleguen a concretarse, son considerados hechos independientes, y por lo tanto concurren materialmente con el art. 210, CP"* (cfr. Ziffer, Patricia S., *El delito de asociación ilícita*, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, p. 111).

Asimismo se ha sostenido que la criminalidad de este delito no reside en la lesión efectiva de cosas o personas, sino en la repercusión que aquél tiene en el espíritu de la población y en el sentimiento de tranquilidad pública, produciendo alarma y temor por lo que puede suceder (D' Alessio, Andrés José, *Código Penal de la Nación Comentado y Anotado*, 2 edición actualizada, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 1031).

La idea de organización implica que cada partícipe debe tener un rol, una función, un papel dentro de la misma. Esto exige, por lógica, que deba haber una organización interna que lleve a una coordinación entre sus miembros, tanto en la asociación como tal como en la realización de los hechos delictivos (cfr. Donna, Edgardo, *Derecho Penal Parte Especial*, Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, Tomo II.C p. 301), agregando, con cita de Sebastián Soler que *“con esta idea de lo que es la estructura objetiva de la asociación ilícita, se comprende la afirmación de la doctrina argentina en cuanto a que no se trata de castigar la participación en un delito, sino la participación en una asociación o banda destinada a cometerlos con independencia de la ejecución o inejecución de los hechos planeados o propuestos* (ob. cit. p. 302). Lo enfatizado no está en el original.

De este modo dejo formulada mi propuesta de rechazo al planteo del recurrente.

3- En cuanto a la alegada falta de motivación de la condena respecto del hecho consistente en la violación de los domicilios ubicados en la calle Santiago del Estero 4000 y 3750 de la ciudad de San Miguel de Tucumán y del delito de privación ilegítima de la libertad agravada, en perjuicio de Marta Angela López, Ceferina Rosa López, Juan Carlos López y Ramón Francisco López, considero que la sentencia se encuentra correctamente fundada sin que enerve tal aserto los cuestionamientos de la defensa respecto de la declaración vertida por la testigo Marta

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

Angela López.

Para reconstruir la materialidad fáctica atingente al suceso que nos atañe el tribunal se sustentó prioritariamente en el relato brindado por la antes mentada ante la Comisión Bicameral, por lo que ciertamente resulta un "testigo de dichos" mas ese *status* -y aquí mi respuesta al agravio del casacionista- no torna *per se* arbitraria la apreciación que de su testimonio se efectúa en la sentencia.

Cabe recordar que el tribunal tuvo por demostrada la participación de Albornoz como autor material de los delitos de violación de domicilio de calle Santiago del Estero Nº 4000 y Santiago del Estero Nº 3750 y privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Marta Ángela López, Ceferina Rosa López, Juan Carlos López, y Ramón Francisco López (ambos delitos en concurso ideal).

Al momento de la valoración probatoria consideró concluyente el testimonio de Marta Ángela López ante la Comisión Bicameral por los Derechos Humanos, oportunidad en que manifestó que su señor padre *"...fue testigo presencial de estos hechos y reconoció al comisario Roberto Heriberto Albornoz, "Tuerto", entre los que integraban el grupo de intrusos y secuestradores..."*, también precisó que a los pocos días de ocurrido ese hecho, se presentó en el domicilio de su padre el Policía Quinteros -quien vivía aproximadamente a cuatro cuadras

de la casa de la familia donde se produjo el secuestro- y le comentó a su madre que él personalmente había participado, junto a Albornoz, del secuestro de sus hijos y que había actuado por orden de Albornoz. En esa misma ocasión, Marta López relató que el Policía Quinteros se encontraba en calidad de “desaparecido” (cfr. fs. 25.759/25.759 vta.).

Al respecto, cabe señalar que conforme surge del tenor literal del art. 239 del CPPN, testigo es toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad.

Lo relevante es pues el aporte que dicho sujeto pueda realizar en pos del descubrimiento de la verdad real de los sucesos investigados, con prescindencia del modo de adquisición del conocimiento que tuvo sobre ese hecho. En este sentido, puede tratarse de una persona que haya tenido un conocimiento directo como indirecto, es decir, ora que lo percibido haya sido en forma personal, ora a través de las referencias de terceras personas.

No cabe desechar sin más esta última hipótesis como pretende el recurrente, pues no existe en nuestro digesto adjetivo ninguna limitación para la admisión de dicha prueba máxime aún tratándose como en la especie, de delitos que presentan una evidente dificultad probatoria por la modalidad de ejecución y por el tiempo transcurrido, circunstancias que hacen que su reconstrucción fáctica no sea una tarea sencilla para el juzgador.

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

En virtud de lo expuesto, considero que el agravio deducido no puede prosperar.

4- Corresponde abordar ahora la pretendida aplicación del art. 34 inc. 2 del CP. pues, a entender de la defensa, Roberto Heriberto Albornoz habría obrado violentado por las amenazas vertidas por el Teniente González Naya de que si incumplía la orden de custodiar a los presos de la Comunidad de Inteligencia en la Jefatura de Policía podría terminar sus días en uno de esos calabozos.

El tribunal sostuvo que Albornoz, conforme quedó acreditado en la audiencia, era quien ejercía el mando en el D-2, donde se encontraban detenidas clandestinamente las víctimas de este juicio y, por tal motivo, puede afirmarse que fue autor material del delito de privación ilegítima de la libertad de quienes allí estuvieron.-

De seguido aclaró que tal reproche penal le corresponde en virtud de lo prescripto por el art. 144 *bis* del Código Penal, en cuanto prescribe: "*Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo: 1) El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal; 2) El funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales; 3) El*

*funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones o apremios ilegales. Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo 142, la pena privativa de la libertad será de reclusión o prisión de dos a seis años.” -*

Advirtió que se excluía en la calificación de la conducta de Albornoz la figura del art. 142 inc. 1° atento a que, según lo acreditado en la audiencia, no puede afirmarse con el grado de certeza exigido en esta etapa procesal, que el mismo haya protagonizado las detenciones de quienes eran llevados, posteriormente, al centro clandestino de detención que estaba a su cargo. Si bien le cabría el reproche penal, a lo sumo, en carácter de autor mediato por ese tramo inicial de padecimientos en la cadena de injustos perpetrados contra las víctimas, se considera que obedece a una mejor y más clara técnica valorativa enmarcar su conducta en la figura penal descripta por el art. 144 bis. No obstante, conforme se fundamentó *supra*, Albornoz sí debe responder en carácter de autor mediato por la comisión del delito de violación de domicilio de las víctimas que fueron sustraídas de sus hogares -fs. 25.763 vta./25.764-.

A lo expuesto adunó que, según se acreditó en la audiencia, también le corresponde el reproche penal en calidad de autor material por la privación ilegítima de la libertad agravada y violación de domicilio (en concurso ideal) en perjuicio de Marta Ángela López, Ceferina Rosa López, Juan Carlos López y Ramón Francisco López, atento a que en relación a

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

éste caso, no existen dudas respecto a su presencia en el momento de la detención de las víctimas -fs. 25.764-.

El art. 34 inc 2 *in fine* del CP cuya aplicación pretende la defensa, establece que no es punible "el que obrare violentado por [...] amenazas de sufrir un mal grave e inminente".

Conforme surge del tenor literal se alude a amenazas, entendida éstas como el anuncio de un mal grave de producción inminente, exigiéndose su concurrencia real y efectiva, no bastando que el autor se haya representado subjetivamente que tal situación acontecía.

A ello cabe adunar, que la amenaza debe revestir seriedad y con idoneidad intimidante. El Código exige que el mal amenazado además de grave sea inminente y puede provenir de cualquier fuente y amenazar cualquier bien.

Righi sostiene que la solución a la que adscribe que exige que la causa del miedo sea real, conduce a asimilar la coacción con el estado de necesidad.

Se trata de una eximente que rige en el plano de la culpabilidad cuando se realizan acciones en un contexto de necesidad de origen humano o natural, por las que se lesionó o menoscabó un bien jurídico de similar importancia al amenazado, como sucede: 1) en el recurrente ejemplo de quien se encontraba aferrado a un madero que sólo soporta el peso de una persona luego de un naufragio

(causa natural) y ahogó a su compañero para salvar su vida; 2) cuando alguien mata a otro para salvar su vida de la amenaza de muerte de un tercero (causa humana). El primero es un caso de estado de necesidad y el segundo de coacción (Righi, Esteban, *Derecho Penal Parte General*, 1º edición, Bs. As., 2008, Lexis Nexis, p. 283 y 348/349).

Por su parte, Zaffaroni enseña que el estado de necesidad exculpante -que es un supuesto de inexigibilidad de otra conducta previsto en el derecho positivo-, no tiene en nuestro código limitación alguna de fuentes de peligro. La amenaza de sufrir un mal grave e inminente del art. 34 inc. 2, puede provenir de un acto humano tanto como de fuerzas o acontecimientos naturales pues no existe ninguna explicación lógica ni histórica para acotar sus fuentes. El único argumento para restringir su alcance a la coacción sería la interpretación literal más limitativa de la voz amenazas, que indicaría un actuar humano. Pero lo cierto es que, junto al sentido estricto, el verbo amenazar también tiene un sentido figurado, que es el de presagiar un daño. En este segundo sentido, semánticamente la amenaza puede ser una vivencia y el daño provenir de un peligro generado por otro o por la naturaleza ( Zaffaroni. Eugenio Raúl - Alagia, Alejandro- Slokar, Alejandro *Derecho Penal Parte General*, Ediar, 2º edición, Bs. As., 2003, p. 744 y ss.) .

Así, Zaffaroni señala que el estado de necesidad, que tiene lugar cuando entran en conflicto bienes jurídicos y magnitudes de afectación de éstos que resultan equivalentes o

cuando se sacrifica el bien mayor, para casi toda la doctrina es un estado de necesidad exculpante (art. 34 inc. 2 CP), siendo su fundamento, a su entender, la notoria reducción del ámbito de autodeterminación del sujeto en la situación constelacional en que realiza la acción, lo que neutraliza la posibilidad de reproche, advirtiéndose acerca del deber jurídico que tienen algunos sujetos de soportar el riesgo o peligro cuyo injusto es mayor con respecto a quienes no les incumbe ese deber.

De tal modo, destaca que la exigencia de abstenerse del injusto más grave (el cometido por el que viola el deber especial) siempre es mayor que la de abstenerse del más leve (el cometido por el que no tiene dicho deber) y por ende se necesitan causas más poderosamente limitativas de la autodeterminación para excluir el reproche del injusto más grave.

Autorizada doctrina sostiene que necesariamente tendrán que considerarse todas las circunstancias que en realidad mueven a actuar a un sujeto en sociedad. Luego la inexigibilidad de la conducta será un requisito en relación a la responsabilidad del sujeto, ya que lo único que cabe averiguar es si ese sujeto social está en situación de responder de sus actos en contra del derecho y ello dependerá necesariamente de todas las circunstancias que lo motiven a actuar.

La exigibilidad de la conducta implica pues, que junto a la exigencia de la posibilidad de comprensión del injusto se considere, si además se le puede exigir una determinada conducta (de no obrar en contra del ordenamiento) al sujeto, dados los condicionamientos concretos en que se encontraba. De otra manera, no estaría completa la referencia del individuo en su totalidad respecto del hecho injusto realizado, no basta con la referencia al injusto mismo (exigencia de posibilidad de comprensión), sino que necesariamente, además, se tiene que plantear la si la exigencia de la conducta era posible respecto de ese individuo en esa situación. Sólo entonces se puede señalar que el sujeto está en situación de responder por su hecho.

La exigibilidad de la conducta supone, pues un juicio *ex ante* al momento del hecho por parte del sujeto que considere todas las circunstancias que han motivado su actuar y enjuicie a ese ciudadano concreto en esas circunstancias. La inexigibilidad de otra conducta a partir de la situación concreta da lugar a las llamadas causas de exculpación (cfr. Bustos Ramírez, Juan y Hormazábal Malaré Hernán, *Lecciones de Derecho Penal*, Ed. Trotta, Madrid, 1999, pp. 348 y ss.).

A la luz del marco dogmático *supra* expuesto, cabe colegir que no se advierte en el caso particular de Albornoz *ex ante* que su conducta hubiese estado guiada por el condicionamiento propio de quien padece un cuadro de coacción tal que le sea inexigible haber actuado de otro modo, pues no

resulta plausible que dado su rol jerárquico -era quien ejercía el mando en el D-2 dentro de la Jefatura de Policía- no hubiese tenido poder de decisión, ora para cambiar la suerte de las personas que se encontraban allí alojadas bajo su órbita de dominio, ora para desistir de seguir formando parte de esa organización criminal.

El elevado *status* que a la sazón detentaba obsta a la consideración de la existencia de un marco de constreñimiento de su conducta debido a una supuesta intimidación que adujo, sin más, haber sufrido, pues siquiera acompañó un mínimo de prueba que la sustente otorgándole verosimilitud y consistencia a sus dichos.

Ello no significa, aunque resulte obvio aclararlo, una inversión del *onus probandi*, sino antes bien la vigencia de la regla de que quien pretende beneficiarse con una causa de justificación o de exculpación debe acompañar un mínimo de prueba que dé sustento a su alegación.

De este modo su pretensión, que aparece desprovista de fundamento válido, carece de asidero y no alcanza para desvirtuar la afirmación de la culpabilidad del injusto que correctamente le fuera reprochado.

Ergo, no es dable predicar del imputado que se encontraba, *ex ante* en el contexto fáctico de su actuación, impedido, en virtud de las limitaciones que operan en el ámbito

de la culpabilidad, de ajustar su conducta a las normas penales vigentes a la sazón.

Finalmente, no podrá prosperar la tacha de arbitrariedad que la defensa le atribuye a la sentencia por haber obviado pronunciarse acerca de la alegación que esa parte formulara en la oportunidad del art. 393 del ritual con relación a este tópico.

Ello es así, pues los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones sino sólo respecto de aquéllas que consideren pertinentes para una correcta solución del caso. Y ello a estar a las constancias que surgen del expediente y lo argumentado *supra* al descartar la aplicación de la causa de inculpabilidad introducida, no se verifica en la especie.

5) Autoría mediata de los delitos de violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos agravado, torturas seguida de muerte, homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr la impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes.

La defensa pretende enervar la atribución de la autoría mediata de los delitos *supra* referenciados, con sustento en que su asistido no revestía un rol jerárquico.

Ello no tendrá favorable acogida pues, como quedó fehacientemente acreditado, Albornoz efectivamente formaba parte del aparato de poder, situándose en el segundo nivel, al que pertenecen los autores de jerarquía intermedia que ejercitan una

forma de control sobre una parte de la organización y por esto, pueden ser designados como autores por organización (*organisationstäter*) -cfr., en este sentido, Kai Ambos, *Fundamentos y ensayos críticos en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal*, Palestra Editores, Lima 2010, pág. 197).

Desde esa posición, ciertamente elevada, impartía órdenes a sus subordinados para que éstos lleven a cabo la faz ejecutiva del plan criminal diseñado, sin que empecé a ello la circunstancia de que a su vez éste también hubiera recibido directivas de los mandos superiores pues lo dirimente –y aquí mi respuesta a lo nuclear de su planteo– es que haya tenido un dominio respecto de los sujetos que se encontraban en un nivel jerárquico inferior respecto de él.

Y esto último ha quedado cabalmente demostrado en autos.

En efecto, si bien Albornoz recibía instrucciones y se reportaba periódicamente con la jerarquía militar, también impartía órdenes en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía. Ello encuentra respaldo en las constancias que surgen de su legajo personal y asimismo en sus propios dichos, al haber confirmado que era el Jefe del D2. De su legajo se desprende que desde el 10 de septiembre de 1975 se desempeñó como Jefe del Servicio de Confidenciales de la

Policía de Tucumán (SIC) y a partir del 17 de junio de 1976 como Jefe del Departamento de Inteligencia D2.

Cabe adicionar a dichos elementos los contundentes testimonios brindados durante el juicio por quienes estuvieron detenidos en el mencionado centro clandestino, que dan cuenta de que Albornoz ejercía el control en ese ámbito.

Al respecto, repárese en lo manifestado por el testigo Raúl E. Elías quien afirmó que Albornoz era el jefe después de González Naya (cfr. fs. 25.655 vta./25.657. En la misma dirección, confirmando dicho *status* se erigen las contundentes declaraciones de los testigos Juan Martín Martín, Oscar Conte, Noemí T. Pastor Cerezo y Juan Carlos Clemente.

Es harto elocuente lo manifestado por la testigo Pastor Cerezo para graficar el rol jerárquico que revestía el imputado (cfr. fs. 25.704 vta./25.705).

Reforzando esa idea, se observa la declaración de Clemente quien expresó que “...Albornoz era amo y señor de quien se le antojara” –cfr. fs. 25.715 vta./25.719.-

Como epílogo, a este devenir, no albergo duda alguna del alto grado de poder de decisión que detentó Albornoz en los hechos atribuidos por lo que he de postular el rechazo de este agravio.

En definitiva, propicio el rechazo *in totum* del recurso interpuesto por la defensa técnica de Albornoz, con costas (arts. 470 y 471 a *contrario sensu*, 530 y 531 del CPPN).

### **III- Recurso de casación interpuesto por la defensa de**

**Luis Armando De Cándido y Carlos Esteban De Cándido.**

1- Modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva.

Con respecto a esta cuestión, vale destacar que ya he expresado, en distintos pronunciamientos (cfr. Sala IV, causa Nº 14386, "Rei, Víctor Enrique s/recurso de casación", Reg. Nº 213/12, rta. el 2/3/2012; Sala IV, causa Nº 15218, "Guglielminetti, Raúl Antonio s/recurso de casación", Reg. Nº 554/12, rta. el 18/4/2012; entre otras), mi opinión en punto a que la gravedad de las penas impuestas a los imputados cobra especial relevancia a la luz de los estándares definidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -por remisión al Sr. Procurador ante la Corte- para evaluar riesgos procesales en causas donde se investigan y juzgan delitos de lesa humanidad (cfr. causa "Vigo, Alberto Gabriel" -V.621. XLV- cuyos fundamentos fueron compartidos, en lo pertinente, por la C.S.J.N el 14/9/2010; en similar sentido, C.S.J.N "Pereyra" P.666 -XLV-, del 13/11/2010; "Binotti" B.394 -XLV- del 14/12/10; "Clements" C.412 -XLV- del 14/12/10; "Altamira" A.495 -XLV- del 14/12/10, entre otros).

No obstante ello, toda vez que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de pronunciarse respecto de la aplicación de la referida doctrina **al presente caso**, al resolver sobre el recurso extraordinario federal deducido por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia de

esta Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal –con integración parcialmente diferente a la actual– que anuló la orden de detención de Luis A De Cándido emitida por el tribunal de juicio –declarándolo inadmisibile (CSJN *in re* “Albornoz, Roberto Heriberto; De Cándido, Luis Armando s/ rec. de casación –recurso extraordinario–” A. 898. XLVIII. del 7/08/2011)y confirmando, en consecuencia, la resolución de fecha 16/2/2011 (Reg. nº 81/11/3), que ha quedado firme– entiendo que debe estarse a lo resuelto oportunamente por esta Sala III sobre la cuestión.

Empero, nada impide disponer, a los efectos de asegurar el cumplimiento de la presente sentencia, la prohibición de salida del país de Carlos Esteban De Cándido (arts. 280 y 310 del CPPN), lo que así postulo al acuerdo.

Nuestro Máximo Tribunal ha señalado en diversos precedentes la importancia de resguardar la sujeción al proceso de los imputados de delitos de lesa humanidad, con el objeto de salvaguardar derechos constitucionales y cumplir con compromisos internacionales (*in re* “Vigo”, V 261, L XLV, del 14/09/2010; causa “Pereyra”, P 666XLV, del 23/11/2010 y “Acosta”, A. 93. XLV, del 08/05/2012; entre muchas otras).

Atento la decisión adoptada al resolver el recurso de casación interpuesto por el fiscal con relación a la situación de Carlos Esteban De Cándido, con el objeto de asegurar la sujeción del imputado al proceso y la eventual aplicación de la ley penal, considero que la prohibición de salida del país luce proporcional

y adecuada a los efectos de reducir el riesgo procesal existente.

2-Corresponde abordar la alegada arbitrariedad en la valoración de la prueba.

a) Adelanto que no prosperará la crítica esbozada al testimonio de Domingo Antonio Jerez. Ello así pues el tribunal de grado abordó idéntico planteo incoado durante la audiencia de debate, mediante un adecuado razonamiento lógico que no ha podido ser confutado por la parte en su escrito casatorio.

b) En lo concerniente al pedido de nulidad del reconocimiento realizado por el testigo Demetrio Chamatrópolis durante la audiencia advierto que también esta cuestión es una reedición del mismo planteo formulado en aquella oportunidad, cuestión que mereció debido tratamiento y correcta solución, no habiendo logrado el defensor rebatir en la instancia los sólidos argumentos esbozados por el a quo (cfr., al respecto fs. 25.624 vta.). No obstante que ello bastaría para desechar sin más este agravio, he de formular algunas consideraciones.

Existe consenso en admitir que una vez detenido el imputado deviene superfluo reconocerlo por medio de fotografías, pues la disposición contenida en el art. 274 del código adjetivo está prevista para cuando sea menester identificar o reconocer a una persona que no estuviere presente y no pudiere ser habida y de la que se tuvieran fotografías, en cuyo caso se presentarán éstas con otras similares de otras personas ante quien deberá

efectuar el reconocimiento. Ello así pues es un medio de prueba subsidiario del reconocimiento de personas que no pudieron ser habidas.

Empero ello, esta premisa cede, deviniendo por tanto pertinente el reconocimiento, en supuestos, como el de autos, donde se investigan delitos que atentan contra toda la humanidad y que han ocurrido hace más de tres décadas.

Es que no puede soslayarse que el transcurso del tiempo en relación al momento de comisión de los hechos objeto de este juicio reviste una incidencia vital en este aspecto, a cuyo tenor resulta pues plausible asimilar la situación de los imputados a las hipótesis contempladas por el art. 274 del C.P.P.N.

En este orden de ideas, considero que las fotografías de los imputados que se hallan insertas en sus respectivos legajos, desde estimativamente aquella fecha configuran un importante punto de apoyo para el deponente pues le brindan una referencia más precisa acerca de los rostros de sus agresores en aquel momento, fisonomía que, de acuerdo a las reglas de la lógica y de la experiencia común, es evidente que debió haber sufrido modificaciones después de transcurridos 34 años.

Así, de adverso a lo alegado por la defensa, no resulta un reconocimiento extemporáneo el efectuado por el testigo Chamatrópulos.

Reforzando el criterio del tribunal, cabe destacar que no estamos en presencia de un reconocimiento impropio -como lo

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

reputa la parte-, toda vez que no se dirigió a reconocer a los imputados que se encontraban presentes en la sala de audiencias, sino sólo respecto de las fotografías de los mismos insertas en los legajos policiales de la época que le fueron exhibidos.

Establecido ello, lo cierto es que no se constata vicio alguno en el reconocimiento fotográfico realizado por el testigo que amerite la tacha pretendida por el recurrente, ello así, no obstante que la inobservancia del art. 274 del ritual no esté prevista bajo sanción de nulidad, debiéndose aclarar, por lo demás, que no se trató -como insinúa la defensa- de una sustitución de una diligencia por otra, es decir, de un reconocimiento en rueda de personas -que fuera omitido durante la instrucción- por un reconocimiento por fotografías durante el debate, pues claramente aquél no resultaba pertinente a los fines perseguidos.

Dejo así formulada mi propuesta de rechazo a dicho agravio.

c) En lo que respecta al cuestionamiento que centra sobre el testigo Oscar Enrique Conte, observo de la lectura de la sentencia que se han dado fundadas razones para desechar el planteo de falso testimonio argüido por la defensa.

Conforme surge del acta de debate mientras prestaba declaración testimonial Oscar Enrique Conte, el Defensor

Oficial, doctor Lo Pinto solicitó que se declare el falso testimonio del testigo, conforme el art. 252 del C.P.P.N. pues advirtió diferencias sustanciales entre la declaración ante el Fiscal Federal obrante a fs. 13.131 que le fuera exhibida y lo declarado en dicha audiencia (cfr. fs. 25.547 vta.).

El Tribunal resolvió: *"No surgiendo elementos suficientes "prima facie" para ordenar la detención del testigo, resérvese para definitiva la resolución sobre el pedido de remisión de las actuaciones al Juzgado Federal para la investigación por presunto falso testimonio.- Sin perjuicio de lo resuelto, en el marco de lo prescripto por el art. 388 C.P.P.N., líbrese oficio al Ministerio de Justicia de la Nación para que informe si durante el año 1977 se desempeñaba como Alcalde Mayor de la Penitenciaría de Ezeiza, dependiente del Servicio Penitenciario Federal el Sr. Guillermo Wolkys, quien además sería médico y residiría en la actualidad en la localidad de Monte Grande, Provincia de Buenos Aires.- En caso de resultar afirmativo el informe cíteselo como testigo a esta audiencia de debate"* (cfr. fs. 25.548/25.548 vta.)

Llegado el momento de dictar sentencia los judicantes se abocaron en forma preliminar a pronunciarse sobre las cuestiones previas planteadas durante el debate que, en cuanto a su resolución, habían sido diferidas para esa oportunidad.

Así hicieron una reseña de la extensa declaración brindada por Oscar Enrique Conte (cfr. fs. 25.631/25.633 vta.) y después de evaluar dicho testimonio como asimismo el prestado

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

en la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán, ante el Fiscal Nacional, doctor Felix Pablo Crous, durante la instrucción, concluyeron sosteniendo que "si bien a simple vista surgen diferencias cuantitativas entre ambos relatos, lo concreto es que la explicación brindada por el testigo ante estos estrados, en el sentido de que nunca había relatado todo lo realmente vivido en el momento en que secuestraron a Marta y Rolando Coronel, por temor, marca una connotación especial que debe tenerse en cuenta en el marco de los hechos que se juzgan en los presentes autos" (cfr. fs. 25.633 vta./25.634).

El tribunal consideró que la primera declaración estaba incompleta debido a la entidad e idoneidad del temor alegado por Conte, al que reputó una consecuencia lógica a la luz de la gravedad de los acontecimientos aquí ventilados y de la diversa manera en que repercutieron en cada uno de los damnificados.

Contrariamente a lo alegado por la empeñosa defensa, los dichos de Conte ante la fiscalía, si bien parcial en relación con el brindado en la audiencia, resultaron para el tribunal coincidentes entre sí, más allá de detalles intrascendentes y además con el descargo brindado por el propio imputado Albornoz -cfr. fs. 25.633 vta./25.634-.

El examen crítico al que fue sometido el testimonio cuestionado permitió arribar al corolario de que Conte estuvo detenido en Jefatura de Policía como consecuencia de haber sido

secuestrado en el mismo lugar y momento en que secuestraban a Marta y Rolando Coronel.

En consecuencia, se propone el rechazo del agravio examinado.

d-En este acápite se han de abordar en forma conjunta por su intrínseca relación los agravios relativos a la falta de fundamentación de la sentencia para imputarle a Luis Armando de Cándido el delito de "violación de domicilio" y de "privación ilegítima de la libertad agravada", ambos en concurso ideal.

Quedó acreditado en el debate que "a fines del mes de mayo de 1977 aproximadamente a las 11:30 un grupo de personas vestidos de civil y armados (aproximadamente 11, según relatos del testigo Conte) ingresaron al domicilio de la calle Chacabuco 476/478 propiedad de Marta y Rolando Coronel. Quedó acreditado en el curso de la audiencia que en el domicilio se encontraba Marta Coronel, Rolando Coronel y Oscar Enrique Conte. Según testimonio de Conte, vertido en la audiencia, un policía con tonada cordobesa le pegó y le preguntó donde están los otros y dijo "vamos con todos". Los sacaron a los tres, a Conte y a Rolando Coronel los subieron en una camioneta y a Marta en otro auto. El testigo Conte relató que mi entras iban en camino "sintió un ronquido de Rolando, como si lo estuvieran ahorcando, cuando llegaron, abrieron la puerta de la camioneta de atrás y no lo sintió más a Rolando"; el testigo relató que cuando llegaron se le corrió la manta que tenía y vio un patio. Marta y Rolando Coronel fueron llevados al Centro Clandestino

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

de Detención que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán"  
-cfr. fs. 25.755 vta. y ss.-.

En lo que respecta al otro delito atribuido, el tribunal razonó adecuadamente que "...el ingreso a los domicilios de las víctimas se produjo para poder concretar la privación de libertad de las mismas, y siempre ocurrió de manera violenta y arbitraria, a la noche -salvo el caso de Ángel Mario Garmendia, que fue a plena luz del día-, los protagonistas siempre actuaron en grupo, encapuchados o utilizando linternas potentes para impedir que se vieran sus rostros, portando armas de fuego y sin orden judicial que legitime tales procedimientos" -cfr. fs. 25.757/25.757 vta.-

De seguido agregó que "la circunstancia de que, en los casos descriptos *ut supra*, los captores hayan concretado la privación de la libertad de sus víctimas en los domicilios de las mismas y en las demás condiciones que rodearon tal accionar, garantizó a los actores el éxito y la impunidad en dicha empresa, a la vez que disminuyó e incluso evitó la presencia o la mirada de testigos ajenos a las familias así sorprendidas" -fs. 25.757 vta.-

En virtud de ello, se concluyó sosteniendo que la figura penal descripta en el art. 151 concurre idealmente con las propias de los arts. 144 *bis* y 142 inc. 1º, en cuanto tipifica la privación ilegítima de la libertad que se ejecuta empleando

*"violencias o amenazas"*. Por su parte, el art. 54 del C.P. establece que *"cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor"*. Así, si un hecho delictuoso infringe más de una norma simultáneamente, se da un concurso ideal de leyes. De esta manera, se entiende que si bien el ámbito de protección normativa de los tipos difiere, en la especie, con una unidad de plan, los individuos que irrumpieron en las casas de las víctimas, violaron sus domicilios para privarlas de su libertad. Por ello, se razona que en los casos en que se demostró que esa fue la conducta desplegada, cabe encuadrar el accionar en las tipos penales de violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad en concurso ideal -cfr. fs. 25.757 vta.-

Por tanto, el tribunal consideró que a Luis Armando De Cándido le corresponde el reproche penal como autor material del delito de violación del domicilio de calle Chacabuco N° 476/478 de San Miguel de Tucumán en concurso ideal con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Marta y Rolando Coronel.

Para así decidir, se sustentó prioritariamente en el testimonio de Oscar Conte, quien se encontraba en la casa de los Coronel al momento del secuestro. El a quo apreció que su declaración fue determinante para calificar la conducta del imputado al afirmar que *"...había uno con tonada cordobesa que preguntaba dónde estaban los otros..."* -fs. 25.759-.

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

Así, se tuvo por acreditado que la persona de tonada cordobesa referida por el testigo y por otros, conforme se evidenció en la audiencia y se explicitó al analizar la figura de asociación ilícita, era Luis Armando De Cándido, cuyo protagonismo el tribunal también lo infirió del rol que le atribuyeron los testigos en la actuación de "la patota".

Al recalar en el análisis de la figura de asociación ilícita efectuada por el a quo, observo que para atribuirle dicho delito se partió de la premisa de que Luis Armando De Cándido, conforme surge de su legajo personal, se desempeñó como Oficial Sub -ayudante de la Policía de la Provincia de Tucumán, afectado a la realización de tareas en el Servicio de Confidenciales y en Inteligencia de dicha repartición, a lo que se adunó la valoración de las declaraciones prestadas durante el debate no sólo del testigo Conte, sino también la de Raúl Edgardo Elías y Demetrio Chamatrópulos, quienes identificaron al imputado como "el cordobés", y la del testigo Juan Martín Martín, que lo nombró como uno de los que tomaba nota de las declaraciones de los torturados -cfr. fs. 25.753/25.753 vta.-

Con lo expuesto ha quedado evidenciado que el a quo arribó al corolario adoptado en base a un cuadro probatorio que ha sido correctamente valorado, por lo que cabe rechazar la alegada falta de fundamentación.

Cabe destacar que la crítica de la defensa contra la sentencia sobre la supuesta ausencia de acreditación de que Luis Armando De Cándido haya torturado a Marta y a Rolando Coronel, por estar vinculado con un agravio del señor Fiscal, será tratado más adelante.

f-La defensa cuestionó la imputación de asociación ilícita atribuida a su asistido esencialmente por no haber podido ser enjuiciados Antonio Domingo Bussi, Alberto Luis Cattáneo y Mario Alberto Zimmerman.

El agravio planteado ha sido objeto de análisis y adecuada respuesta por parte del tribunal quien brindó las razones concretas en virtud de las cuales resulta plausible la imputación cuestionada, argumentación ésta que no ha podido ser confutada por la parte.

Como es sabido, el tipo penal de asociación ilícita se estructura sobre la base de un acuerdo de voluntades entre tres o más personas, de carácter estable y con atributos de cohesión y organización, con la finalidad de cometer delitos indeterminados, bastando que el sujeto sea consciente de formar parte de una asociación compuesta como mínimo por tres personas. De ahí que el número mínimo exigido debe verificarse no sólo objetivamente sino también a nivel de imputación subjetiva.

Ciertamente, al tratarse de un delito colectivo, el número de intervinientes es relevante pues dicha cantidad brinda mayor eficacia a la organización delictiva.

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

Este es el punto nuclear al que se dirige el embate casatorio toda vez que para el impugnante no es posible condenar al último eslabón si no pudo probarse la existencia de los restantes elementos que conformaron la parte superior de la cadena de mando a lo que adunó que su asistido, por el rango que ostentaba, era un elemento fungible y que como tal no revestía el carácter de miembro permanente.

De consuno con el *a quo* considero que, a los fines de la adecuación típica en el art. 210 del CP, no se requiere que se verifique el requisito numérico en la última fase del proceso, pues no debe identificarse el número de personas sometidas al proceso con las que han llegado a concluir la etapa del juicio oral.

En tal inteligencia entiendo que no es menester que se llegue a condenar a tres miembros de la asociación, siendo suficiente con que la acción penal haya estado dirigida contra tres imputados. En este mismo sentido Soler, afirma que "no es necesaria la presencia simultánea de tres imputados en el proceso, puede alguno hallarse prófugo, pero es preciso que la acción esté dirigida, cuando menos contra tres o que lo haya estado. Puede, en efecto, haberse operado la prescripción para algún partícipe; pero el hecho de que no pueda dictarse condena contra él no impide que pueda condenarse a los otros asociados que interrumpieron la prescripción. Es necesario, sin embargo,

que el juez considere que la asociación constaba realmente de tres sujetos a lo menos ..." (Soler Sebastián, *Derecho Penal Argentino IV*; Tipográfica Editora Argentina, 4º ed., Bs. As., 1987, p. 713).

Por su parte, Núñez señala en una posición más amplia, que incluso el número mínimo puede completarse con un inimputable, refutando a la opinión contraria que exige que el número de participantes en la asociación esté compuesto por individuos penalmente imputables, pues ésto no encuentra fundamento en la razón de la criminalidad del pacto ni es una exigencia para su reconocimiento. La criminalidad del pacto no reside en la punibilidad de sus autores, sino en el peligro que implica el pacto en sí mismo, cualesquiera que sean su autores (Núñez, Ricardo C., *Tratado de Derecho Penal*, Parte Especial, VI, Lerner Editores, Bs. As. 1971, p. 186).

Creus destaca que, acreditada la punibilidad delictiva enunciada por el tipo, no es indispensable que la totalidad de los que componen el número mínimo de asociados sea punible (puede ocurrir, que alguno sea inimputable o por causas de impunidad menos debatidas doctrinalmente, como es el supuesto de fallecimiento, o la prescripción de la acción respecto de uno o algunos de los miembros y no de los demás).

Tampoco se requiere que todos los que integran el número mínimo sean punibles por delitos cometidos en cumplimiento de los objetivos de la asociación, ya que en este aspecto, rige estrictamente la responsabilidad individual de

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

cada uno de los componentes. Algunos indican la necesidad de que la acción penal se haya dirigido por lo menos contra tres integrantes de la asociación, pero no es una exigencia que surja de la ley ni tiene nada que ver con la tipicidad (cfr. Creus, Carlos, ob. cit. p. 110).

Sentado lo expuesto, observo de las constancias de la causa que el fiscal requirió la elevación a juicio con relación a cuatro personas, Albino Mario Alberto Zimmermann, Alberto Luis Cattáneo, Roberto Heriberto Albornoz y Luis A. De Cándido, empero, lo cierto es que sólo dos de ellos pudieron enfrentar el juicio, toda vez que respecto de los dos nombrados en primer término la acción penal se extinguió por sendos fallecimientos durante el curso de la audiencia (cfr. fs. 24.494 y 25.190, respectivamente).

Del mismo modo, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi no participaron de este juicio en virtud de que razones, de índole procesal, como el *ne bis in idem* -por haber sido condenado con anterioridad por este delito en la causa de ese tribunal caratulada "Vargas Aignasse Guillermo s/ su secuestro y desaparición", y biológicas, el deceso para el caso de Bussi, se erigieron en óbices insuperables para arribar a un veredicto definitivo respecto a la imputación de asociación ilícita que pesaba sobre ellos.

En síntesis, la circunstancia de que algunos de los imputados hayan sido sobreseídos no empece a que con relación a los restantes se pueda tener por acreditada su intervención en la asociación ilícita, en calidad de jefe con respecto a Roberto Heriberto Albornoz y de miembro, en el caso de Luis Armando De Cándido.

En cuanto al modo de vinculación y al grado de pertenencia de los integrantes de la asociación, se requiere que actúen en forma organizada y permanente y asimismo que lleven a cabo actos que trasuntan que estamos en presencia de una estructura delictiva estable. Por ello, es menester que el acuerdo o pacto entre sus miembros para cometer delitos sea demostrativo de una cierta continuidad, es decir, esté dirigido hacia la permanencia. En este punto cabe distinguir la convergencia de voluntades hacia la permanencia de la asociación, de la mera convergencia transitoria referida a uno o más hechos determinados, inherente a la participación.

No se exige, cabe aclarar, una permanencia absoluta antes bien basta con una relativa, que es la que demanda la pluralidad delictiva.

En la sentencia quedó debidamente acreditado que Luis Armando De Cándido, conforme surge de su legajo personal, se desempeñó como Oficial Sub-ayudante de la Policía de la Provincia de Tucumán, afectado a la realización de tareas en el Servicio de Confidenciales y en Inteligencia de dicha repartición. A ello se adicionó que en virtud de las pruebas

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

sustanciadas durante la audiencia de debate, no existen dudas de que Luis Armando De Cándido, también aludido por los testigos como "el cordobés", integró la asociación ilícita y le cabe el reproche penal en carácter de miembro de la misma.

En efecto, el a quo tuvo en cuenta lo declarado por el testigo Raúl Edgardo Elías quien identificó a Luis De Cándido en la sala de audiencia y expresó "...el que me secuestró a mí fue De Cándido Luis, el que ocupó la casa de la calle Chacabuco...fue el que más duro me castigó;...y fue el único que después que me liberaron me hostigó durante mucho tiempo, me tiraba el auto encima, me miraba...".

En la misma dirección fue reseñada y valorada la declaración prestada por el testigo Juan Martín Martín, quien lo nombró como uno de los que tomaba notas de las declaraciones de los torturados y asimismo los dichos de Demetrio Ángel Chamatrópulos quien refirió que durante su cautiverio escuchó la voz de alguien con tonada cordobesa que "...era como un jefe de ahí...una noche siento que me dan una patada, era el cordobés, que me dice que me quede tranquilo que me estaban por liberar..." y expresó que después de un año de su liberación, "...mientras caminaba por calle Junín, se para un Falcon al lado mío con toda impunidad y me pregunta ¿cómo le va Sr. Chamatrópulos? Y yo le digo que no lo conocía, entonces me dice ¿cómo te vas a olvidar de mí? ...Ahí reconocí la tonada cordobesa...".

Finalmente se tuvo en cuenta el testimonio de Oscar Conte quien al describir cómo la patota ingresó a la casa de calle Chacabuco, especificó que *"...había uno de tonada cordobesa que era el que me pegaba y tenía el pie sobre mi cara, era un muchacho medio gordito, de mirada fija...ese señor cordobés dijo: vamos con todos, vamos los tres"* -cfr. fs. 25.753/25.753 vta.-

El Tribunal concluyó sosteniendo que "al tiempo de producirse los hechos investigados en la presente causa, las fuerzas armadas de la Nación actuaron de acuerdo a un plan predeterminado por las Juntas Militares, destituyendo a las autoridades constitucionales de la República e instaurando un sistema ilegal que se apartó de las funciones específicas de la organización militar y de las funciones de gobierno, y en ese marco tomaron parte en una asociación ilícita para cometer delitos Roberto Heriberto Albornoz y Luis Armando De Cándido junto a otros miembros, unos ya condenados por este tribunal y otros que si bien no concluyeron la etapa de juicio oral, concurrieron en el hecho *sub judice* como se ha evidenciado en el debate, tal el caso de Albino Mario Alberto Zimmermann y Alberto Luis Cattáneo; ello a los fines estrictos de la calificación jurídica, sin que la descripción en la presente causa permita concluir que solo ellos la hubieran conformado, ya que la experiencia histórica indicaría la existencia de una asociación ilícita integrada por gran parte de los miembros de la fuerzas armadas.

De ese modo, concluyó declarando [a Roberto Heriberto

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

Albornoz coautor del delito de asociación ilícita en carácter de organizador de la misma, conforme el art. 210 del C.P] y a Luis Armando De Cándido, coautor del delito de asociación ilícita en carácter de miembro (conforme los términos del art. 210 y 210 bis del Código Penal).

Ahora bien, considero, de adverso a lo alegado por el recurrente, que en el caso se verifica la cantidad de intervinientes exigida por el artículo 210 del C.P., sin que enerve tal colofón lo esgrimido como otro de los puntos de concreto agravio, de que su asistido era tan sólo un miembro fungible no formando parte de la organización como miembro permanente, pretendiendo con ello desvincularlo de la imputación que se le atribuye.

Ello así pues la defensa confunde fungibilidad con transitoriedad, es decir con la ausencia de permanencia. Y aquí yace, a mi ver, la génesis de la falacia a la que arriba.

Estamos ante dos conceptos, o mejor dicho dos adjetivos calificativos, que modifican uno al sustantivo "ejecutor" – fungible– y el otro a "miembro" –permanente–, que tienen ámbitos de operatividad diferentes y por ende, consecuencias fácticas y normativas también diferentes.

La fungibilidad actúa en el ámbito de la construcción dogmática de la autoría mediata como uno de los pilares sobre los que ésta se cimienta. Mientras que la permanencia es un

requisito predicable respecto de la convergencia intencional de una asociación ilícita.

Es decir, la falta de permanencia o transitoriedad con incidencia en el plano de la tipicidad del delito de asociación ilícita no resulta identificable con la fungibilidad o intercambiabilidad propia de los intervinientes –ejecutores– en un hecho ilícito llevado a cabo por un autor de escritorio, con incidencia en el plano de la imputación de la autoría.

Como corolario de lo expuesto, corresponde rechazar este agravio.

Cabe resaltar que el agravio vinculado con la supuesta ausencia de fundamentación de la condena de Carlos Esteban De Cándido por el delito de usurpación de la propiedad de la calle Jujuy nº 1062 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, será tratado conjuntamente, por su estrecha vinculación, con el planteo que contra dicho *factum*, pero sobre la calificación legal en cuanto al encubrimiento posterior y su modalidad concursal, hiciera el fiscal.

3- Finalmente cabe destacar, en respuesta al planteo defensista de que sus asistidos son condenados por delitos de lesa humanidad sin que exista una prueba contundente de su existencia o participación en el lugar de los hechos, que el agravio del casacionista sólo traduce su divergencia con la valoración de los hechos realizada por el tribunal a cuyo tenor se coligió correctamente y con apego a la sana crítica racional que los sucesos atribuidos a Carlos de Cándido y Luis de Cándido

se sucedieron en el marco de un ataque sistemático implementado desde el estado y dirigido contra la población, y no —como aduce el impugnante— por haber formado parte de la policía de la Provincia de Tucumán al momento de su ocurrencia.

**IV- Recurso de casación del representante del Ministerio Público Fiscal y agravios relacionados con otros de la Defensa Oficial de Luis Armando De Cándido y Carlos De Cándido.**

1-En este acápite se han de abordar en forma conjunta, por su intrínseca relación, los planteos deducidos por la Defensa Oficial de Luis Armando de Cándido y por el fiscal en sendos recursos de casación, vinculados al hecho cuyas víctimas fueron Marta y Rolando Coronel, a cuyo tenor el defensor se agravia de la falta de acreditación de que su asistido haya torturado a Marta Coronel y a Rolando Coronel; mientras que, por su parte, el fiscal recurrente expresa su disconformidad con la calificación de tormentos seguido de muerte, solicitando se condene a Luis Armando de Cándido a la pena de prisión perpetua por considerarlo autor penalmente responsable del homicidio triplemente agravado en perjuicio de Marta y Rolando Coronel.

De la lectura de la sentencia impugnada no advierto la alegada falta de fundamentación que la Defensa Oficial de Luis A. De Cándido le atribuye.

Ello es así pues el tribunal para colegir del modo en

que lo hizo, imputándole al nombrado la autoría en el suceso endilgado, valoró el lugar que Luis A De Cándido detentaba en la estructura organizada de poder, y asimismo lo mencionado por muchos testigos de que era integrante de “la patota” que se encargaba de secuestrar y torturar a las víctimas. A tal fin se remitió a los testimonios de Raúl Edgardo Elías, Demetrio Ángel Chamatrópulos, Juan Carlos Clemente y Juan Martín Martín.

Y, en especial, en lo que a este hecho concierne, se determinó que Luis A. De Cándido integró el grupo de tareas que concretó los injustos de los que fueron víctimas Marta Coronel y Rolando Coronel, con sustento, prioritariamente, en el testimonio brindado por Oscar Conte.

A ello se adunó la consideración del rol que Luis Armando De Cándido revestía a la sazón, habiéndose valorado las constancias que surgen de su legajo personal de la Policía de la Provincia, que dan cuenta que desde el 21 de junio de 1976 hasta el 9 de enero de 1978, prestó servicios en el D2 en la Jefatura de Policía de la Provincia de Tucumán, y luego se desempeñó como jefe de Comisaría de Esquina -fs. 25.771 vta-.

En síntesis, en este contexto, la alegación defensiva de que el fallo condenatorio se ha fundado en meras presunciones carece de correlato en las constancias que surgen de la causa y que fueron reseñadas y valoradas en su conjunto, de conformidad con los principios que gobiernan el sistema de la sana crítica. Plexo cargoso que ha permitido formular adecuadamente la atribución de autoría de Luis Armando de Cándido en los hechos

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

*sub examine*; no verificándose por ende, el déficit de fundamentación consignado por la defensa, por lo que cabe rechazar su planteo en este sentido.

Sin embargo, sí se advierte una errónea aplicación de la ley sustantiva en el juicio de tipicidad formulado por el *a quo*, de modo tal que el agravio del fiscal concerniente a este punto, recibirá de mi parte favorable acogida.

Sentado lo expuesto, habida cuenta de que los sucesos investigados en estas actuaciones se dieron en el contexto histórico de un plan sistemático de represión estatal, corresponde, en primer término, establecer si los delitos probados en autos atribuidos a Luis A. De Cándido configuran la práctica de Derecho Internacional denominada desaparición forzada de personas.

Un hito relevante en el ámbito americano con relación a este tópico lo constituye la resolución 666 (XIII-0/83) del 18 de noviembre de 1983 dictada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos mediante la que se declaró que toda desaparición forzada debía calificarse de crimen contra la humanidad.

A *posteriori* de tal declaración, se erigen las primeras sentencias condenatorias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El *leading case* lo configura el caso "Velásquez Rodríguez", sentencia del 29 de junio de

1988, Serie C n° 4, en el que se condenó al estado de Honduras por la violación de sus deberes de respeto y garantía de los derechos reconocidos en la CADH con relación al estudiante hondureño desaparecido Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, secuestrado en Tegucigalpa por hombres armados de civil conectados con las Fuerzas Armadas de ese país.

En esa oportunidad, la Corte expresó que si bien no existía al tiempo de los hechos *"ningún texto convencional en vigencia, aplicable a los Estados Partes en la Convención, que emplee esta calificación, la doctrina y la práctica internacionales han calificado muchas veces las desapariciones como un delito contra la humanidad (Anuario Interamericano de Derechos Humanos, 1985, págs. 369, 687 y 1103). La Asamblea de la OEA ha afirmado que "es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad" [...]. También la ha calificado como "un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, en detrimento de las normas que garantizan la protección contra la detención arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal"[..]" -parágrafo 153-.*

Luego expuso que *"La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser*

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

*llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto, que infringe el artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a la libertad personal [...] -vid parágrafo 155-*

*Asimismo, afirmó que "el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, lo que constituye, por su lado, la violación de las disposiciones del artículo 5 de la Convención que reconocen el derecho a la integridad personal como sigue [...] "( vid par.156). De seguido, advirtió que "La práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención [...]. La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el*

*sistema interamericano y la misma Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención, [...] -vid párrafos 157 y 158-*

Tal argumentación fue reiteradamente sostenida en posteriores pronunciamientos de ese Tribunal, confróntese, entre otros, caso "Godínez Cruz", sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C n° 5, párrafos 163 y 166; y caso "Blake", sentencia del 24 de enero de 1998 Serie C n° 36, párrafos 65 y 66.

En este último se sostuvo que *"la desaparición forzada o involuntaria constituye una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido. Además, le coloca en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos. De ahí la importancia de que el Estado tome todas las medidas necesarias para evitar dichos hechos, los investigue y sancione a los responsables y además informe a los familiares el paradero del desaparecido y los indemnice en su caso"* -vid par. 67-.

En su jurisprudencia constante iniciada desde 1988 ("caso Velásquez Rodríguez") la Corte ha señalado la naturaleza permanente o continua y el carácter pluriofensivo de la desaparición forzada, en la cual el acto de desaparición y su

ejecución inician con la privación de la libertad y la subsiguiente falta de información sobre su destino y permanece mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos.

Más recientemente, en el caso "González Medina y familiares vs. República Dominicana" sentencia del 23 de febrero de 2012 reiteró como los elementos concurrentes y constitutivos de este delito: "a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada" (par. 128 y asimismo caso "Gómez Palomino vs. Perú", sentencia de 22/11/2005, y caso "Torres Millacura y otros vs. Argentina", sentencia de 26/08/2011. Asimismo la Corte aclaró que dicha caracterización es consistente con otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales, la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, decisiones del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y decisiones de altos tribunales nacionales.

Hasta aquí, una somera reseña de la jurisprudencia interamericana cuyos lineamientos configuran una guía de interpretación de las disposiciones convencionales que deben observarse conforme la doctrina del cimero tribunal.

En cuanto a los textos legales, existen en el ámbito

internacional dos instrumentos de suma trascendencia, a saber: la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (en adelante Declaración contra las desapariciones forzadas) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992, y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 9 de junio de 1994. Esta fue ratificada por el Estado Argentino el 6 de octubre de 1994. Del tenor literal de su artículo II surge con claridad la definición de desaparición forzada como *“la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.”*

Por su parte, la Declaración contra las desapariciones forzadas, prevé en su artículo primero, segundo párrafo, las consecuencias que produce: *“Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al*

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

*reconocimiento de su personalidad jurídica, al derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida o lo pone gravemente en peligro."*

Las graves consecuencias que trae aparejada dicha práctica han sido destacadas por Daniel O'Donnell, autor de "Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano", para la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al señalar que: *"Algunas veces la desaparición forzosa es conceptualizada como una violación agravada del derecho a la vida, debido a las violaciones de otros derechos cometidas con el afán de perpetuar la impunidad de los autores, así como por las consecuencias que tiene la desaparición de una persona en los derechos fundamentales de otras, en particular de los familiares de la persona desaparecida. Si bien esta apreciación es correcta en la mayor parte de los casos, es menester recordar que la desaparición no siempre entraña una violación consumada del derecho a la vida. La muerte de la víctima, como indica la última frase del artículo 1.2 de la Declaración, no es elemento de la definición de la desaparición."*

*"En ciertos casos, cuando no hay indicios claros sobre*

la suerte de la víctima de una desaparición, el Comité de Derechos Humanos ha reconocido la responsabilidad del Estado sobre violaciones de derechos humanos diferentes al derecho a la vida. En el caso *Tshishimbi*, por ejemplo, un ex militar supuestamente involucrado en una tentativa de golpe fue secuestrado por un grupo de militares o paramilitares, negándoseles a sus allegados toda información sobre su paradero. El Comité concluyó que los hechos eran violatorios del derecho a la libertad y seguridad personales, pero no al derecho a la vida. La CIDH, por su parte, fundamenta la conclusión sobre si ha habido una privación arbitraria de la vida —en los casos en los cuales no hay evidencias directas del fallecimiento de la víctima— en el hecho de la falta de información durante varios años sobre el paradero de la misma” (autor cit. en ob. cit. págs. 129 y 130, publicado en <http://www.hchr.org.co>)

Por su parte, el Estatuto de la Corte Penal Internacional también recoge esta figura en el art. 7.1.i, con una definición similar a la de la Convención Interamericana, aunque con la expresión adicional de “una organización política” y con el añadido de un especial elemento subjetivo consistente en la intención de dejar a la persona privada ilegítimamente de la libertad fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

Resta aclarar, como bien lo destacara la Corte en el fallo *Arancibia Clavel*, que “...la ratificación en años recientes de la Convención Interamericana sobre Desaparición

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

Forzada de Personas por parte de nuestro país sólo ha significado, como ya se adelantara, la reafirmación por vía convencional del carácter de lesa humanidad postulado desde antes para esa práctica estatal, puesto que la evolución del derecho internacional a partir de la segunda guerra mundial permite afirmar que para la época de los hechos imputados el derecho internacional de los derechos humanos condenaba ya la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad..." (Fallos 327:3312, considerando 13 del voto de los jueces Zaffaroni y Highton de Nolasco).

Finalmente cabe señalar, como circunstancias características que acompañan esta práctica la negación de lo ocurrido y la ocultación de pruebas. Ello ha sido advertido por la CIDH en los casos antes citados "Velásquez Rodríguez" y "Blacke".

De modo que, en general, la prueba de lo ocurrido siempre descansa, en parte, en presunciones y prueba circunstancial. En la mayoría de los casos hay pruebas o indicios sobre la participación de agentes del gobierno o personas que actúan con su aquiescencia en la detención o secuestro de la persona desaparecida, de manera que la presunción se limita al desenlace de la situación. En ausencia de evidencias claras sobre la autoría material de la detención o el secuestro, la CIDH reconoce una presunción de responsabilidad

del Estado cuando existe una práctica sistemática comprobada de desaparición y los hechos del caso concreto son congruentes con las características de dicha práctica.

La Corte ha verificado la consolidación internacional en el análisis de este crimen, el cual configura una grave violación de derechos humanos, dada la particular relevancia de las transgresiones que conlleva y la naturaleza de los derechos lesionados, por lo que implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el sistema Interamericano y su prohibición ha alcanzado el carácter de *ius cogens* (párr. 130 de “González Medina y familiares vs. República Dominicana” sentencia del 23 de febrero de 2012).

Ahora bien, a la luz de los antecedentes normativos, doctrinarios y jurisprudenciales antes esbozados es dable colegir que los delitos atribuidos al imputado Luis Armando De Cándido se inscriben dentro de dicha práctica delictiva de derecho internacional caracterizada por la secuencia secuestro-tortura-desaparición.

La ausencia a la sazón de tipo penal específico en el ámbito doméstico que aprehenda el disvalor de ese fenómeno no obsta a la tipificación de las acciones en las diferentes figuras del Código Penal -vigente al momento de los hechos-, que describen conductas violatorias de la libertad y dignidad de la persona, la integridad y la vida, tipos penales éstos en los que la desaparición forzada halla su correlato en el orden interno. Formulada la digresión que antecede corresponde analizar el

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

juicio de tipicidad de la conducta atribuida al imputado, conforme el *factum* establecido en la sentencia.

En lo que respecta a los hechos relacionados con Rolando y Marta Coronel, el tribunal tuvo acreditado que "a fines del mes de mayo de 1977, aproximadamente a las 23:30 hs., un grupo de personas vestidas de civil y armadas - aproximadamente once, según relato prestado en la audiencia por el testigo Conte- ingresaron al domicilio de la calle Chacabuco 476/478 propiedad de Marta y Rolando Coronel. Quedó acreditado en el curso de la audiencia que en el domicilio se encontraba Marta Coronel, Rolando Coronel y Oscar Enrique Conte.

El a quo valoró que en la audiencia el testigo Conte expresó que "estábamos comiendo -el sábado 28 de mayo- a eso de las 11:30 de la noche, Rolando estaba arreglando una bicicleta, él estaba sentado en el living de la casa, cerca de la puerta del living, sintió que golpearon la puerta, dijeron "Marta, Marta", y abrió una hoja de la puerta entraron como once hombres, lo tiraron al piso, remontaron las armas, se sintió un ruido de chapas atrás, dijo que era factible que otro grupo hubiera entrado por atrás de la casa, lo tiraron sobre la cama, le taparon la cabeza, Marta pasó al lado llevada por cuatro o cinco personas, vio un auto con las dos ruedas subidas sobre la vereda, cree que ahí se la llevaron a Marta. Recordó que le pegaron a él y a Rolando y les preguntaban donde estaban los

*otros, Rolando decía "no le peguen a los chicos, no los maten".*

También se tuvo en cuenta que el testigo señaló que un policía de aproximadamente 30 años, que tenía tonada cordobesa le pegó y preguntó dónde estaban los otros y dijo "vamos con todos" y los cargaron en una camioneta que estaba en las mismas condiciones que el Ford Falcon -con las dos ruedas en la vereda-, lo cargaron primero al testigo tapado con una manta, atrás a Rolando Coronel, cerraron la puerta, arrancaron la camioneta. Supone el testigo que deben haber transcurrido siete u ocho minutos hasta que llegaron. Recordó que Rolando decía que el testigo no tenía nada que ver, sintió un ronquido de Rolando como que lo estaban ahorcando, cuando llegaron, abrieron la puerta de la camioneta de atrás, ya Rolando no hablaba cuando llegaron, lo bajaron de la camioneta, se le salió un poco la manta y alcanzó a ver que era un patio donde posiblemente haya estado el auto donde fue trasladada Marta, no vio donde lo llevaban a Rolando.

El *a quo* sostuvo que de la audiencia surgió que Marta y Rolando Coronel fueron llevados al centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán, según relato de Conte, que dijo que escuchó una mujer preguntando "donde está mi papá" y cree que era la voz de Marta. El testigo Juan Martín Martín en la audiencia dijo que supo que Rolando Coronel había estado en Jefatura. Marta fue sometida a torturas que le provocaron una infección en los pechos que desembocó en su muerte, conforme quedó acreditado también con la

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

testimonial de Juan Martín Martín que dijo que la vio en Jefatura y "que estaba muy mal, que deliraba, que estaba muy enferma, que según le comentaron, tenía una infección en los pechos por la tortura y murió en Jefatura de Policía ... escuchó que un médico que trabajaba ahí, le había puesto una inyección para que se muriera pronto así dejara de sufrir, la sacaron envuelta en unas mantas, estaba en la zona de calabozos y la subieron a un rastrojero y la llevaron a enterrar, pero que no sabe donde".

El tribunal se sustentó asimismo en los dichos de la testigo Vilma Rivero, quien expresó que le habían comentado que Marta Coronel estaba detenida en Jefatura y tenía una infección en los pechos.

Al momento de calificar las conductas de los imputados Luciano B. Menéndez, Roberto Heriberto Albornoz y Luis A De Cándido en los sucesos que tuvieron como víctimas a Marta y Rolando Coronel, los judicantes, apartándose de lo requerido por el Fiscal al formular su alegato-, consideraron que debían encuadrarse en el delito de tormentos seguido de muerte, previsto en el art. 144 ter, último párrafo, ley 14.616 del CP, toda vez que los nombrados murieron durante su cautiverio como consecuencia de las torturas inflictas a la sazón.

Cabe evocar que el fiscal de juicio había solicitado se condene a Luis A. De Cándido a la pena de prisión perpetua e

inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas por resultar autor directo penalmente responsable, en lo que aquí atañe, de aplicación de tormentos reiterados (art. 144 *ter* del CP según ley 14616) en perjuicio de Rolando Coronel, tormentos seguidos de muerte respecto de Rolando Coronel y Marta Coronel (art. 144 *ter* último párrafo del CP según ley 14616) Desaparición forzada y homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más partícipes y con el fin de lograr impunidad (arts. 79 y 80, incs. 2, 6 y 7 CP) en perjuicio de Marta y Rolando Coronel -*vid.* fs. 25.598-

En tal inteligencia, los jueces argumentaron que Marta Coronel fue sometida a torturas que le provocaron una infección en los pechos que desembocó en su muerte, tal como quedó acreditado con la testimonial de Juan Martín Martín y en el mismo sentido de la testigo Vilma Rivero. En cuanto a Rolando Coronel, consideraron determinante lo expresado por el testigo Oscar Conte.

De ese modo, concluyeron sosteniendo que a Luis De Cándido le cabe el reproche penal en carácter de autor material del delito previsto en el art. 144 *ter* último párrafo del CP habida cuenta del lugar que ocupaba en la estructura organizada de poder a lo que debe agregarse que fue mencionado por muchos testigos como integrante de "la patota" que se encargaba de secuestrar y torturar a las víctimas (testimonios de Raúl Edgardo Elías, Demetrio Ángel Chamatrópulos, Juan Carlos Clemente, Juan Martín Martín) y, en especial, se probó que

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

integró el grupo de tareas que concretó los injustos de que fueron víctimas Marta Coronel y Rolando Coronel (testimonio de Oscar Conte).

A ello, el a quo adicionó que, según las constancias de su legajo personal de la Policía de la Provincia, desde el 21 de junio de 1976 hasta el 9 de enero de 1978 De Cándido prestó servicios en el D2 en la Jefatura de Policía de la Provincia de Tucumán, y luego se desempeñó como jefe de la Comisaría de Esquina (*vid.* fs. 25.771/25.771 vta.).

Sentado lo expuesto, llegado el momento de resolver la cuestión planteada considero que el juicio de tipicidad de los hechos repasados *ut supra* no resulta ajustado a derecho, por lo que se ha de proceder en la instancia a su corrección sólo en lo que atañe a la conducta atribuida a Luis De Cándido, por ser materia de concreto agravio casatorio. Ergo, el cambio de calificación no alcanzará a los coimputados Menéndez y Albornoz, que fueron condenados por su intervención en el mismo suceso, pues respecto de ellos se erige el principio de la cosa juzgada como un óbice infranqueable atento no haber sido recurrida la sentencia a su respecto.

Como se dijo el tribunal de grado tipificó la conducta endilgada a Luis De Cándido en el art. 144 *ter* del CP, último párrafo, versión ley 14.616,- por ser ésta la ley vigente al momento de los hechos-.

Al respecto, no resulta ocioso señalar que dicha disposición establecía que: "será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere, a los presos que guarde cualquier especie de tormento [...]. Si resultare la muerte de la persona torturada, la pena privativa de la libertad será de reclusión o prisión de 10 a 25 años".

Como es dable apreciar del tenor literal, la inflicción de tormentos configura el tipo penal básico mientras que el desenlace mortal constituye una de las agravantes previstas por la norma, en virtud de la cual se eleva la escala punitiva.

Dicho tipo penal preveía un agravamiento de la pena como consecuencia de un resultado preterintencional, en donde se requería un primer tramo doloso (el que corresponde a la imposición de tormento) seguido de un desenlace imprudente (el resultado mortal). Ello guardaba relación con el hecho de que el homicidio doloso mediante la imposición de torturas, generalmente encuadraba en la figura del art. 80 inciso 2, CP y por lo tanto, existía cierta armonía entre los tipos y las penas esperables en cada caso. Pero ese equilibrio se habría perdido a partir de la sanción de la ley 23.097, al llevar la escala penal de la tortura seguida de muerte a la misma pena que los homicidios dolosos agravados -prisión perpetua- y además se introdujeron las lesiones gravísimas como segunda agravante con penas sensiblemente mayores al tipo doloso del art. 92 del CP

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

(en función del art. 91 CP) consistentes en diez a veinticinco años de prisión (cfr. Rafecas, Daniel "La tortura y otras prácticas ilegales a detenidos", 1º ed., Editores del puerto, Bs. As. 2010, pág. 194).

Por su parte, Donna en comentario al texto legal vigente -que castiga con prisión o reclusión perpetua en los casos que resultara la muerte de la víctima- sostiene que "tanto el resultado muerte, como el resultado lesiones deben poder ser imputados objetiva como subjetivamente a la imposición de torturas, de manera que esto exige, desde el punto de vista subjetivo y atento a la penalidad, que el homicidio lo sea a título de dolo, aunque sea eventual" (Donna, Edgardo, Derecho Penal, Parte Especial, T II-A, Rubinzal Culzoni Editores, Bs. As., 2001, pág 198).

Cabe recalcar ahora en los tipos agravados de homicidio previstos en el art. 80 del C.P., cuya aplicación pretende el recurrente. Estos como es sabido, reclaman en su aspecto subjetivo, habida cuenta de la forma de comisión del hecho, dolo directo, es decir, exigen intención homicida por parte del agente.

Los tipos penales que se encuentran en juego en la especie están previstos en el art. 80, incs. 2, 6 y 7 del Código Penal. Rige el caso la ley 21.338 del 16/7/76 por ser la vigente al tiempo de comisión de los hechos , esto es mayo de

1977.

El art. 80 del C.P. reza "se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el art. 52 al que matare: 2° con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso

6°) con el concurso premeditado de dos o más personas

7°) para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.

El homicidio agravado por la alevosía se constata cuando concurren las siguientes circunstancias: el aprovechamiento insidioso de su indefensión, su indefensión, la decisión adoptada por la indefensión y la preordenación.

En otros términos, debe existir una situación real, objetiva de indefensión de la víctima, una falta de posibilidad de defenderse y una situación subjetiva, consistente en que el autor provoque esa circunstancia, la cree o bien, siendo preexistente, la aproveche para actuar sin riesgo, porque si bien no se requiere premeditación, sí, en cambio, exige preordenación.

Cabe aclarar que la indefensión de la víctima no es suficiente *per se* para que se constate la alevosía, es menester también que el autor quiera obrar sobre seguro, sin el riesgo que pueda implicar la reacción de la víctima o de terceros direccionada a neutralizar su acción.

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

Ello exige una preordenación de la actividad del agente para actuar con esa seguridad, es decir, la procuración o el aprovechamiento del estado de indefensión, lo que no implica, necesariamente una premeditación (serena y fría deliberación del contexto del hecho a realizar) puesto que si la premeditación importa preordenación ésta puede darse sin aquélla. Como dice Creus, con cita de Núñez, "para que se dé la alevosía, por tanto, debe ser 'el móvil alevoso' lo que decida al agente a actuar" (cfr. autor cit., Derecho Penal, Parte Especial, Tomo I, Ed. Astrea, 3º ed. 2º reimpression, Bs. As, 1992, págs. 28 y 29).

En derecho comparado encontramos una definición de esta circunstancia agravante del homicidio simple en el Código Penal Español que expresamente define la alevosía en el número primero del art. 22, concepto que es aplicable también al art. 139 *ibídem*. Reza dicho artículo que "Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido".

En lo que respecta al homicidio calificado por el "concurso premeditado de dos o más personas" cabe señalar que esta figura requiere que dos o más personas se hayan puesto de acuerdo en matar juntos y que lo hayan hecho premeditadamente, con cierta reflexión, no bastando obviamente la mera

convergencia ocasional, es decir la simple participación de varias personas en la muerte de la víctima.

Ello importa que los agentes se hayan puesto de acuerdo para matar en concurso, o sea, no es suficiente que se hayan puesto de acuerdo para matar, sino que se deben haber puesto de acuerdo para hacerlo de ese modo (cfr. D'Alessio, José Andrés, Código Penal. Comentado y concordado. Parte especial. Artículos 79 a 306, La Ley, Buenos Aires, 2004, pág. 18).

Finalmente, el homicidio *criminis causae*, tratándose de un tipo penal complejo, reclama en su aspecto subjetivo tanto el dolo de homicidio como el elemento subjetivo adicional que trasciende a éste, y que consiste en la finalidad o conexidad con otro delito -esto es, "para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o para procurar la impunidad para sí o para otro y por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito".

Ahora bien, como adelantara *supra* le asiste razón al fiscal recurrente habida cuenta de que los hechos que tuvieron como víctimas a Marta y Rolando Coronel deben ser calificados como homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de lograr la impunidad.

Ello así toda vez que de conformidad con el plexo probatorio obrante en autos es dable colegir en la desaparición forzada de las víctimas, y por ende en sendas muertes, sin que empecé a ello, por más obvio que resulte aclararlo, que no hayan

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

aparecido sus cuerpos pues tal circunstancia no deviene un óbice para establecer aquel extremo.

Es dable predicar de Marta y Rolando Coronel que sus homicidios se perpetraron en el contexto de su desaparición forzada, cuyo punto de inicio se remonta a la irrupción violenta e ilegal en el domicilio que ambos habitaban por parte del grupo de tareas que encabezaba Luis Armando De Cándido, seguida de la privación ilegítima de la libertad de ambos.

Desde la primera fase de la dinámica del *factum* las víctimas pasaron a ser desaparecidos lo que les permitió a los imputados, merced a la clandestinidad en la que operaban, tener absoluta disposición de sus vidas, es decir, pudieron decidir libremente, con total impunidad y arbitrariedad el destino de las personas que se encontraban bajo la órbita de su dominio.

Ello encuentra sustento incontrastable en la documentación original del D2 aportada por el testigo Juan Carlos Clemente, y que fuera bien apreciada por el *a quo*, en la que aparecen identificados los antes mentados bajo sus respectivos nombres y consignada en el ítem "Observaciones" la sigla "DF" que, significaba "disposición final", es decir, la eliminación o el asesinato de la persona.

En este sentido, resulta clarificador el testimonio de Juan Martín Martín, quien al relatar el modo en que accedió a

las listas, expresó que cuando trasladaba las cosas pensaba en recolectar la máxima información que pudiera por si sobrevivía; que los listados tenían al lado de cada nombre una señal característica, así manifestó que quienes tenían las siglas DF significaba que existía la orden para que se los mate y quienes tenían las siglas PEN serían entregados al Poder Ejecutivo Nacional (cfr. declaración testimonial obrante a fs. 25.658 vta./25.669).

Ello formaba parte del plan pergeñado y ejecutado por las fuerzas de seguridad que actuaron bajo el mando operacional de Roberto Heriberto Albornoz -Jefe del Servicio de Información Confidencial (SIC) y Jefe de Inteligencia del D2-, quien ejercía, en un segundo nivel, el control e impartía las órdenes en el ámbito del centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía de Tucumán y asimismo de Luciano Benjamín Menéndez, en virtud de la jerarquía de mandos.

En el caso del imputado Luis Armando De Cándido su actuación se inscribe también dentro de esa estructura organizada de poder habida cuenta de que al momento de los hechos fue uno de los integrantes del SIC y del D2. En dicho carácter formó parte del grupo de tareas que secuestró en el mes de mayo de 1977 a Rolando y Marta Coronel. De ahí que, cabe predicar de su intervención que lo fue a título de autor, es decir de ejecutor material de los sucesos que en este acápite se examinan (art. 45 del CP).

En efecto, desde el preciso momento en que se procedió

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

al secuestro de las víctimas, inmediatamente seguido por los tormentos que les infligieron ya durante el traslado al centro clandestino de detención, el imputado Luis Armando De Cándido generó el riesgo para los bienes jurídicos en juego (libertad, integridad física, vida). Ello lo obliga a responder por los riesgos jurídicamente desaprobados que, en el caso, se trasuntaron en los resultados a la postre acaecidos.

De modo que, corroborado en autos la ejecución de un plan sistemático que se materializó a través de la consabida secuencia secuestro-tortura- detención clandestina- eliminación y ocultamiento del cadáver para lograr la impunidad, plan de exterminio éste en el que Luis Armando De Cándido tuvo una activa intervención pues tuvo el dominio final del hecho, no cabe sino concluir afirmando su responsabilidad en los homicidios de Marta y Rolando Coronel a título de autor directo (conf. art. 45 del CP).

Ciertamente, el imputado Luis Armando De Cándido al formar parte del grupo de tareas que violó el domicilio donde habitaban los Coronel, procedió a su secuestro y en forma concomitante a la inflicción de torturas, tuvo concretamente desde el inicio de ese esquema de acción, la dirección del suceso hacia el fin perseguido y, en ejercicio del rol de funcionario público que detentaba, tuvo la libre disposición de la libertad y de la vida de las personas que había secuestrado,

situándose por ende, en posición de garante en virtud de la cual debía evitar la producción del resultado.

No tengo duda alguna sobre que Luis Armando De Cándido desplegó su conducta aprovechándose de la absoluta indefensión de las víctimas que se encontraban atadas y vendadas y por ello, a total arbitrio de los que conformaron la patota, de este modo, actuó sin riesgo alguno asegurándose la efectividad del plan, de modo tal que se verificó la conducta delictiva de homicidio por alevosía previsto por al art. 80 inc. 2 del CP.

En el caso de Rolando Coronel, es contundente el testimonio de Oscar Conte, que ya fuera reseñado *ut supra*.

Por otra parte, concurre la agravante prevista en el inciso 6 del art. 80 del CP, pues ha quedado corroborado fehacientemente que la dinámica de los eventos recreados reclamaba necesariamente la intervención de dos o más personas organizadas para secuestrar y ulteriormente proceder a la ejecución de las víctimas.

Finalmente, el transcurso de más de tres décadas sin que hayan aparecido los cuerpos de Marta y Rolando Coronel es un dato relevante pues trasunta la idoneidad del medio deleznable elegido por los autores para procurar su impunidad. Queda de este modo acreditada la circunstancia que califica el homicidio por haber sido cometido con el fin de asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro (art. 80, inc. 7 del CP).

Sentado lo expuesto, advierto que el tribunal, al

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

establecer los hechos probados relacionados con estas víctimas, enfatizó que Marta y Rolando Coronel continúan desaparecidos y figuran en las listas de Jefatura de Policía aportadas en la audiencia por el testigo Clemente con el número 55 -Marta- (fs. 02) y con el número 56 -Rolando Coronel- (fs. 02), ambos con las siglas DF a la par del nombre (fs. 25.738). Empero ello, omitió considerar que se trató de un supuesto de desaparición forzada de personas que lo habilitaba a calificar de otro modo el evento acriminado.

En este orden de ideas, se observa un quiebre lógico en el decurso del razonamiento del juzgador habida cuenta de que con dicha premisa concluyó tipificando la conducta de los imputados a tenor del art. 144 ter últ. párrafo del CP cuando debió efectuarlo a tenor del art. 80, incs. 2, 6 y 7 del CP; máxime aún si se repara que con un plexo probatorio similar, en otros supuestos con relación a otras víctimas extrajo inferencias inculpatorias disímiles arribando por ende a un corolario diverso, es decir, tuvo por acreditado el homicidio agravado (cfr. fs. 25.772/25.775).

En efecto, el a quo sostuvo que "en este juicio se acreditó que la sigla 'DF' escrita a la derecha del nombre de las víctimas que figuraban en la lista mencionada significaba "destino final" o "disposición final", e implicaba la eliminación, el asesinato de la persona a la que se refería". De

seguido aclaró que si bien es cierto que ningún testigo declaró haber presenciado la ejecución, la disposición de "Destino Final" que pesaba sobre las víctimas es determinante para formar la convicción de este Tribunal de que se cumplió efectivamente con ese designio.

A ello adunó que "esta comprobación, ponderada junto a otras, tales como la circunstancia del transcurso del tiempo por más de treinta años sin que se hayan tenido noticias de ninguna de las víctimas, las torturas padecidas por las víctimas, el trato propiciado a los detenidos clandestinamente en el centro de detención que funcionó en la ex Jefatura, la situación de privación de libertad continuada de cada uno de los ofendidos, permiten conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica racional arribar al grado de certeza necesario para tener por probados los asesinatos de las víctimas de esta causa". Así concluyó subsumiendo la desaparición forzada de las 19 víctimas que enunció en el homicidio agravado por cuanto los autores actuaron sin riesgo para su persona y aprovechándose de la indefensión de las víctimas, es decir, con alevosía; con el concurso premeditado de más de dos personas y con el fin de lograr impunidad -fs. 25.773 vta./25.774-.

En virtud de las consideraciones expuestas, propicio al acuerdo hacer lugar al agravio tratado en este acápite y en consecuencia corregir la calificación legal formulada por el *a quo*, debiéndose encuadrar la conducta del imputado Luis A. De Cándido, vinculada con el evento cuyas víctimas son Marta y

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

Rolando Coronel, en el delito de homicidio agravado a tenor del art. 80 incs. 2, 6 y 7 del Código Penal vigente al tiempo de la comisión de los sucesos y, por ello, declararlo culpable de estos injustos.

Y así concluyo pues en el caso no se advierte la concurrencia de alguna causa de justificación y se encuentran ausentes, además, causas de exculpación, correspondiendo, por ende, el juicio de reproche por ser autor materialmente responsable de dichos delitos.

Como consecuencia de ello corresponde que se lleve a cabo una casación positiva y se proceda en la instancia a la determinación punitiva (conforme surge de la causa "Olivera Róvere, Jorge Carlos y otros s/rec. de casación", Reg. nro. 939/12 de la Sala IV, del 13/6/12, votos del juez Hornos y del suscripto).

Después de haber oído al imputado a tenor del art. 41 del CP, de conformidad con la doctrina que fluye del precedente de la CSJN, "Niz, Rosa Andrea y otros" resuelto el 16/6/10 y habida cuenta de que el homicidio agravado, cuya autoría se le atribuye, prevé la pena de prisión perpetua, es decir, una sanción que no admite mensuración, cabe pues aplicarle dicha pena de prisión perpetua, más la inhabilitación absoluta por igual tiempo y demás accesorias legales previstas en el art. 12 del CP y costas.

2) En el presente acápite abordaré también en forma conjunta, dada su estrecha relación, los planteos de la Defensa Oficial de Carlos Esteban De Cándido y del representante del Ministerio Público Fiscal, relacionado con el hecho de la usurpación de la propiedad de la calle Jujuy 1062 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en virtud del cual la defensa aduce falta de fundamentación para condenar a su asistido por el delito de usurpación de dicha vivienda y, por su parte, el fiscal recurrente se agravia de la no consideración del delito de encubrimiento y, por ende de la aplicación de las reglas del concurso, lo que trae aparejado la imposibilidad de una condena efectiva.

Establecido ello, cabe evocar que el tribunal tuvo acreditado que "la casa de la calle Chacabuco y otra, ubicada en la calle Jujuy 1062, ambas propiedad de Rolando Coronel, fueron ocupadas por policías y sus familiares según testimonios de María Magdalena Blanco, Ramón Edgardo Ponce, Juan Martín Martín"-fs. 25.738-.

Al momento de la subsunción legal de la conducta atribuida el a quo aclaró que "un examen detenido de la totalidad de hechos materia de juzgamiento en la presente causa revela que las usurpaciones perpetradas por Luis Armando y Carlos Esteban De Cándido se encuentran inescindiblemente vinculadas con los otros ilícitos que tuvieron por víctimas a Rolando y Marta Coronel". -cfr. fs. 25.777 vta.-

Para así decidir, el tribunal se sustentó en la

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

declaración testimonial prestada por María Magdalena Blanco quien expresó en la audiencia que unos vecinos le habían dicho que a partir de la desaparición de Marta y Rolando tomaron posesión del inmueble policías y militares, con el tiempo se enteró que una de las personas que se había quedado con un inmueble era Luis De Cándido y en la otra propiedad se enteró que la habían tomado otro De Cándido.

También tuvo en cuenta lo declarado por la testigo Vilma Rivero quien manifestó que *"... observó al frente de la casa de esta chica -por Marta-, miró por la cerradura y vio personas, sobre todo hombres que andaban adentro y al frente un Falcon"*.

En lo que respecta a la ocupación de la propiedad de calle Fortunata García se consideró que se encontraba acreditada por la declaración del propio imputado Carlos De Cándido quien manifestó que después de su ocupación se enteró que la casa pertenecía a Rolando Coronel, y por la declaración testimonial de Analía Marteau.

Se reseñó asimismo lo declarado por la testigo Marín quien recordó que Carlos De Cándido le había dicho *"que lo mandaban de la Jefatura por eso vivía ahí"* y que la esposa de De Cándido también le había manifestado que *"Albornoz era padrino de uno de sus hijos y que él lo había mandado a esa casa"*.

A dicho plexo probatorio el a quo adunó las

siguientes piezas procesales que fueron incorporadas por lectura y que acreditan que las dos propiedades de Rolando Coronel fueron usurpadas por Carlos De Cándido y Luis Armando De Cándido, consistentes en la declaración testimonial prestada ante el juez militar, de Analía Marteau (fs. 12.832/12.833), demanda de prescripción adquisitiva iniciada por Analía Marteau y Luis Armando De Cándido (fs. 12.911/12.913), acta de desalojo de calle Fortunata García y Jujuy, que ocupaba Carlos De Cándido (fs. 13.082/vta); autorización del teniente Mario Miguel D'Ursi a Luis Armando De Cándido para que ocupara la propiedad de calle Chacabuco 478 (fs. 14.350), declaración de Luis De Cándido ante la Cámara Federal de Apelaciones (fs. 14.803/vta) -cfr. fs. 25.738 vta/25.739-.

Como es dable apreciar de lo expuesto *supra*, el tribunal arribó a la conclusión adoptada en base a un cúmulo de elementos probatorios, correctamente valorados, que acreditan la materialidad del hecho atribuido y la autoría que en él le cupo al imputado, resultando reconocible el *iter* lógico seguido por los sentenciantes a la sazón, no advirtiéndose ninguno de los déficits aludidos por la empeñosa defensa; por lo que corresponde rechazar el agravio deducido con relación a este aspecto de la sentencia.

Sin embargo, observo que el *a quo* ha incurrido en un vicio *in iudicando* al momento de la tipificación de los hechos.

Conforme surge de fs. 25.595/25.600 el fiscal al formular su alegato solicitó se condene a Carlos De Cándido a la

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

pena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por el máximo tiempo previsto por la ley accesorias legales y costas por considerarlo autor directo penalmente responsable de los delitos de usurpación de la propiedad de Rolando Coronel ubicada en la calle Jujuy 1062 (art. 181 del CP en su redacción actual) y de encubrimiento (art. 277 incisos 1, 2 y 3 en su actual redacción), todos en concurso real (arts. 45, 181, 277 incisos 1,2 y 3 y 55 del CP y art. 18 de la CN), calificándoselos como delitos de lesa humanidad.

No obstante, el tribunal lo condenó a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, considerándolo autor material penalmente responsable de la comisión del delito de usurpación (art. 181 del C.P. según ley 24.454) de ese inmueble, propiedad de Rolando Coronel, y calificándolo como delito de lesa humanidad (arts. 26, 27 bis inc. 1º, 2º y 8º; 29 inc. 3º; 40 y 41 del C.P. del Código Penal; arts. 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación)-cfr. punto dispositivo X de la sentencia sometida a escrutinio-

En efecto, para así decidir, consideró que se había acreditado en el debate que "la casa de la calle Chacabuco y otra, ubicada en la calle Jujuy 1062, ambas propiedad de Rolando Coronel, fueron ocupadas por policías y sus familiares según testimonios de María Magdalena Blanco, Ramón Edgardo Ponce, Juan Martín Martín; Blanco expresó en la audiencia que unos vecinos

le habían dicho que a partir de la desaparición de Marta y Rolando tomaron posesión del inmueble policías y militares, con el tiempo se enteró que una de las personas que se había quedado con un inmueble era Luis De Cándido y en la otra propiedad se enteró que la habían tomado otro De Cándido. La testigo Vilma Rivero en su testimonio manifestó que "... observó al frente de la casa de esta chica -por Marta-, miró por la cerradura y vio personas, sobre todo hombres que andaban adentro y al frente un Falcon".

Quedó acreditada la ocupación de la propiedad de calle Fortunata García por la declaración del propio imputado Carlos De Cándido que manifestó que después de su ocupación se enteró que la casa pertenecía a Rolando Coronel, y la testimonial de Analía Marteau. Asimismo la testigo Marín recordó que Carlos de Cándido le había dicho "que lo mandaban de la Jefatura por eso vivía ahí" y que la esposa de De Cándido también le había manifestado que "Albornoz era padrino de uno de sus hijos y que él lo había mandado a esa casa". Las siguientes piezas procesales incorporadas por lectura acreditan que las dos propiedades de Rolando Coronel fueron usurpadas por Carlos De Cándido y Luis Armando De Cándido: testimonial ante el juez militar de Analía Marteau (fs. 12832/12833), demanda de prescripción adquisitiva iniciada por Analía Marteau y Luis Armando De Cándido (fs. 12911/12913), acta de desalojo de calle Fortunata García y Jujuy, que ocupaba Carlos De Cándido (fs. 13.082/vta); autorización del teniente Mario Miguel D'Ursi a

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

Luis Armando De Candido para que ocupara la propiedad de calle Chacabuco 478 (fs. 14.350), declaración de Luis De Cándido ante la Cámara Federal de Apelaciones (fs. 14.803/vta)" -cfr. fs. 25.738/25.738 vta.-

Al momento de calificar los hechos, el tribunal encuadró la conducta atribuida a Carlos Esteban De Cándido en el tipo penal del art.181 del digesto sustantivo, habiendo aclarado que configuraba un delito de lesa humanidad y que por ello constituía materia de juzgamiento en este juicio pues se dio en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, contexto que en la especie se asocia con el terrorismo de Estado vigente a la fecha de los hechos objeto de esta causa.

De seguido señaló que las usurpaciones perpetradas por Luis Armando y Carlos Esteban De Cándido se encuentran inescindiblemente vinculadas con los otros ilícitos que tuvieron por víctimas a Rolando y Marta Coronel, advirtiéndole que ello no implica menoscabar el carácter de delito autónomo de la usurpación. En tal sentido, aclaró que sólo se trata de hacer explícita mención de la conexión que tiene con otros injustos, de modo tal de poder entender que los despojos clandestinos -ocupaciones subrepticias de la propiedad- mediante los cuales se materializaron las usurpaciones, tienen por antecedente la ausencia forzada y delictiva de Rolando y Marta Coronel, como

consecuencia de acciones ilícitas penales de lesa humanidad.

En dicha dirección, argumentó que "su comisión en el marco de un plan sistemático consiste en el aprovechamiento del abandono del que fueron objeto los inmuebles por el secuestro de sus propietarios. Además, en ambos casos, en el elemento subjetivo del tipo como actuar doloso está presente el conocimiento de que se trataba de bienes desocupados como consecuencia del secuestro y desaparición de sus dueños en acciones ilícitas penales típicas de lesa humanidad" -cfr. fs. 25.777 vta.-

Hasta aquí el juicio de tipicidad formulado a tenor del art. 181 del Código Penal que no merece ningún reparo, sólo he de destacar que la usurpación cabe reputarla como delito de lesa humanidad, dada su íntima vinculación -abarcada por el conocimiento del agente- con otras conductas que dogmáticamente revisten ese status, erigiéndose en consecuencia dentro del contexto al que alude el art. 7 del Estatuto de Roma.

Diversa es la solución a la que he de arribar con relación al delito de encubrimiento.

El tribunal desechó la imputación de encubrimiento formulada tanto por el fiscal como por la querella en la inteligencia de que la calificación de la usurpación como delito de lesa humanidad impide aquella posibilidad, pues el conocimiento del delito antecedente está presente en el tipo subjetivo de la usurpación como delito de lesa humanidad, al conocer que el hecho ilícito tiene conexión directa o consiste

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

en el aprovechamiento de las consecuencias del plan sistemático  
-cfr. fs. 25.780-

Establecido ello y llegado el momento de definir la  
cuestión planteada, resulta menester formular las siguientes  
consideraciones.

Como es sabido el encubrimiento tradicional, si bien  
es un injusto autónomo, se estructura sobre la base de un delito  
precedente en el que el agente no ha participado, de modo que  
para su configuración se requiere que previamente se haya  
cometido aquél.

Ello se infiere sin más del tenor literal del tipo  
penal vigente al momento de la comisión de los hechos, como  
asimismo del art. 277 CP -conf. ley 25.815 B.O. 1/12/03-, texto  
éste cuya aplicación pretende el recurrente-, que establece: 1.  
Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el  
que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que  
no hubiera participado:

a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de  
la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta. b) Ocultare,  
alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o  
instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a  
ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. c) Adquiriere,  
recibiére u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un  
delito. d) No denunciare la perpetración de un delito o no

individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole. e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito. 2. En el caso del inciso 1, c), precedente, la pena mínima será de un (1) mes de prisión, si, de acuerdo con las circunstancias, el autor podía sospechar que provenían de un delito.

3. La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando: a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mínima fuera superior a tres (3) años de prisión. b) El autor actuare con ánimo de lucro. c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento. d) El autor fuere funcionario público.

La agravación de la escala penal, prevista en este inciso sólo operará una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes.

En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena.

4. Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos del inciso 1, e) y del inciso 3, b)".

El presupuesto del delito anterior también era

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

requerido por el art. 278 -texto según ley 21.338, B.O 16/7/76  
-, vigente durante la comisión de los hechos.

Al confrontar el tenor literal de sendos tipos penales a fin de dirimir cuál es el que rige el caso, advierto que el actual ensancha notoriamente la punibilidad toda vez que no sólo amplía el abanico de acciones típicas sino también porque el ánimo de lucro -que en el art. 278 constituía un elemento especial del tipo subjetivo distinto del dolo- ahora ha devenido en una agravante a cuyo tenor la pena será aumentada al doble de su mínimo y máximo (cfr. art. 277 3.b)

Ergo, deviene aplicable a la especie, de conformidad con el principio "*tempus regit actum*" (art. 18 CN y art. 2 del CP. ) el art. 278 según ley 21.338 que establecía que "el que, con fin de lucro, adquiriere recibiere, u ocultare dinero, cosas o bienes que sabe provenientes de un delito en el que no participó, o interviniera en su adquisición, recepción u ocultación, será reprimido con prisión de seis meses a tres años, y con multa de veinte mil a quinientos mil pesos."

Y asimismo se encuentra en juego el art. 277 *ibidem*, por haber omitido Carlos Esteban De Cándido denunciar el hecho estando obligado a hacerlo.

Para el análisis de lo que aquí interesa se observa la exigencia típica en el aspecto objetivo, del delito precedente. En este punto es en el que se centra la argumentación del a quo

en virtud de la cual desecha que el hecho atribuido configure el delito de encubrimiento, razonamiento éste que a mi entender no luce ajustado a derecho. Por tal motivo, el agravio del casacionista ha de recibir de mi parte favorable acogida. Doy mis razones.

Parto de la premisa, pues es un hecho no controvertido, que los delitos individuales juzgados en la presente causa se encuentran ínsitos dentro de un plan sistemático y generalizado de represión contra la población civil que fue instaurado desde el poder político de facto de aquella época (cfr. regla cuarta de la Acordada 1/12 CFCP). De ahí, como lógico corolario, que resulte aplicable el tipo penal internacional de delito de lesa humanidad (art. 7 del Estatuto de Roma).

Es decir, la circunstancia de que los injustos fueron perpetrados al amparo del Estado los hace pasibles de ser reputados como delitos de lesa humanidad, habilitándose por ende su juzgamiento en virtud de la imprescriptibilidad emanada de dicha categoría de derecho internacional.

Categoría que, huelga aclararlo, no encuentra correlato en el orden jurídico penal interno de nuestro país, en el sentido de que no existe un tipo penal autónomo en el digesto sustantivo que describa el supuesto de hecho al que alude el art. 7 del Estatuto de Roma previendo la respectiva sanción penal.

Tal extremo permite sin violentar el *ne bis in idem*,

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

la imputación bajo ese status, de cualquier delito previsto en el CP –de constatarse, claro está, todos los elementos típicos necesarios para su configuración– con la condición de que se hubiera cometido dentro de la mentada estructura estatal de represión de personas civiles.

La circunstancia de que la usurpación configure un delito de lesa humanidad por su pertenencia a un plan sistemático y generalizado de exterminio de un colectivo de personas, no es un óbice para considerar del mismo modo otro ilícito que se constate en dicho contexto. La conexión con el delito precedente –desaparición forzada de personas– a la que el a quo alude puede y debe ser valorada a ese efecto las veces que sea menester para efectuar tal adscripción a tenor del art. 7 del Estatuto de Roma.

Por ello, no deviene en un fundamento válido para que un tipo penal –usurpación– excluya al otro –encubrimiento– el argumento usado por el a quo consistente en que "la calificación en este caso de la usurpación como un injusto con esos alcances (delito de lesa humanidad), elimina la posibilidad de la imputación por encubrimiento, ya que éste conocimiento del delito antecedente está presente en el tipo subjetivo de la usurpación para que pueda considerarse como crímenes de extrema gravedad por afectación del colectivo humanidad" –vid fs. 25.780–

No se trata pues, de un supuesto de unidad de ley (conurrencia aparente o impropia), el que, como es sabido, contempla los supuestos en que si bien la acción es abarcada por dos o más tipos penales considerados aisladamente, cuando se los considera conjuntamente-en sus relaciones- se verifica que una de las leyes concurrentes interfiere la operatividad de las restantes, por lo que se excluye su aplicación al caso, aunque en definitiva lo haga porque incluye las lesiones de éstas (cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, *Derecho Penal, Parte General*, Ediar, Buenos Aires, 2.000, p. 867).

La mayoría de la doctrina reconoce que los casos de unidad de ley se resuelven por medio de tres principios fundamentales: especialidad, consunción y subsidiaridad.

El primero se da cuando se relacionan dos o más tipos y uno de ellos excluye al otro si abarca las mismas características que el otro, agregando además, alguna nota complementaria que toma en cuenta otro punto de vista en cuanto a la lesividad. La relación de consunción se da cuando un tipo encierra al otro no porque lo abarque conceptualmente sino porque consume el contenido material de su prohibición.

Por último, la subsidiaridad se verifica cuando la tipicidad correspondiente a una afectación más intensa del bien jurídico interfiere a la que abarcaba una afectación de menor intensidad (cfr. autor cit. en ob. cit. pp. 868 y ss.).

A la luz de lo antes expuesto, no encuentro un

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

obstáculo que se funde en un concurso aparente de leyes entre el tipo aplicado por los judicantes de usurpación y el reclamado por el acusador, de encubrimiento. Ambos pueden coexistir en el *sub judice* sin violentar ningún principio dogmático (especialidad, consunción, subsidiaridad) ni procesal-constitucional *-ne bis in idem-*. No obstante, se advierte que existe un vínculo entre dichas figuras que más adelante se abordará.

En tal orden de ideas, superado el óbice formal antepuesto por el *a quo* cabe considerar si resulta plausible calificar el hecho *sub examine* como constitutivo del delito de encubrimiento, tal como lo solicita en la instancia el impugnante reeditando su anterior pedido formulado al acusar (art. 393 del CPPN).

El fiscal sostuvo que Carlos De Cándido es autor del delito de encubrimiento ya que no podía ignorar que el dueño de la casa había sido secuestrado con su hija. Relató que Carlos de Cándido se presentó en el inmueble de calle Jujuy donde estaba la señora Marín y dijo que lo mandaba la policía y la señora de De Cándido le dijo que Roberto Albornoz les había dado esa casa porque eran amigos (cfr. fs. 25.596).

No albergo dudas de que Carlos De Cándido sabía cuál era el origen de la propiedad. Reglas de la lógica y de la experiencia común me llevan a colegir de ese modo al valorar los

elementos probatorios obrantes en la causa. No resulta plausible que desconociera la procedencia espuria de dicho bien habida cuenta del contexto global en el que se enmarcó su conducta y las "tareas" que llevaban a cabo tanto su hermano Luis De Cándido como Roberto Heriberto Albornoz, no sólo por el vínculo que los unía y el trato que se dispensaban sino, por sobre todo, porque también él era agente de la Policía de la provincia de Tucumán desde el año 1976.

Existe un contundente cuadro probatorio en ese sentido. Así, la testigo María Teresa Marín da cuenta del conocimiento que existía entre Carlos Esteban De Cándido y Roberto Heriberto Albornoz (cfr. fs. 25.687 vta.).

También la testigo Mirta Del Valle Aldeco, quien trabajaba en la casa de este último, al deponer durante el juicio manifestó que los De Cándido eran personas que frecuentaban la vivienda de Albornoz y asimismo expresó que vio a los De Cándido que iban en los Falcon -cfr. fs. 25.697/25.697 vta.- .

El ánimo de lucro exigido como elemento subjetivo del tipo -distinto del dolo- está dado por el hecho de haberse instalado Carlos De Cándido en una vivienda ajena, sin haber efectuado pago remuneratorio alguno, apropiándose de una casa que era de una familia que, sin dudas, sabía que había sido secuestrada y desaparecida. No resiste el menor análisis lo argüido por la defensa durante el alegato de que "su defendido tenía solamente ánimo de vivir con su familia bajo un techo, el

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

dolo *ab initio* es inexistente, no buscó ventaja económica, no lucró con la propiedad" -cfr. fs. 25.603 vta.-

La conducta desplegada por Carlos Esteban De Cándido, en primer término, consistió en haber habitado una vivienda que se encontraba desocupada, por haber sido sus dueños despojados clandestinamente de su propiedad, a sabiendas -y esto es lo nuclear-, es decir, con conocimiento efectivo y cierto de que provenía de un delito, precisamente el secuestro y la desaparición forzada de sus legítimos dueños, y habiendo obrado con ánimo de lucro.

De ahí, que a dicho comportamiento deba reputárselo de lesa humanidad, a lo que cabe adunar la omisión de denuncia en la que incurrió, habida cuenta de su condición de funcionario (art. 277 CP). En otros términos, Carlos De Cándido tenía un conocimiento pleno e inequívoco del origen ilícito de la propiedad que a la sazón ocupó, aunado a la incontrastable finalidad que persiguió, esto es, obtener un beneficio económico concreto, que en el caso se tradujo en el no pago a sus legítimos propietarios de una contraprestación a cambio del uso y goce de la cosa ajena durante el largo período que ocupó la vivienda.

Repárese que según consta en autos el desalojo recién se llevó a cabo en el año 2004 (cfr. fs. 13.827vta. y 25.738 vta.).

Es decir, Carlos Esteban De Cándido obró con ánimo de lucro obteniendo además un vasto beneficio y, por otra parte, incumplió con el deber que le imponía el *status* que detentaba de efectuar la denuncia pertinente.

De modo que comprobados todos los elementos que integran tanto el aspecto objetivo como el subjetivo del delito, y no existiendo en la especie causas de justificación que excluyan la antijuridicidad de su conducta, configurado ya el injusto, cabe reprochárselo al autor por no verificarse tampoco causas de inculpabilidad (arts. 277 y 278 texto según ley 21.338 y art. 45 del CP).

Establecido ello corresponde determinar el modo en que se vinculan los injustos (encubrimiento y usurpación) reprochados a Carlos Esteban De Cándido.

Es decir, de conformidad con nuestro digesto sustantivo, lo decisivo es definir cuándo hay unidad o pluralidad de hechos (arts. 54 y 55 del CP) más allá de los resultados o el número de tipos que concurren.

A tal fin se han ensayado varios criterios diferenciadores. Así, la "concepción natural de la vida" (Schönke) que fuera seguida por parte de la doctrina y jurisprudencia alemana fracasó por su contenido vago y dio paso a un criterio que sin prescindir de lo óntico apeló a lo normativo, la teoría de "la concepción jurídica". De allí que Welzel haya señalado que la unidad de acción se determinará atendiendo a dos factores: el final y el jurídico. Es decir, la

unidad de acción requiere el factor final como fundamental y primario dato óntico pero no se contenta con éste (cfr. Zaffaroni, en *ob. y loc. cit.* p. 858).

Enseña dicho autor que este presupuesto necesario es el que Welzel llamaba factor final de la unidad de acción y que otros llaman unidad natural, cuidando distinguirlo de la natural concepción de la vida y otros lo denominan unidad simple.

En caso de que la actividad final de la que se debe averiguar si configura una unidad de conducta, se integre con un único movimiento, no hay dudas de que se trata de una única acción. Empero, cuando se trata de una pluralidad de movimientos que es lo que usualmente sucede en una acción es necesario apelar a un factor normativo que diga cuándo una única resolución que da un sentido final a varios movimientos puede ser relevada como una unidad por el tipo. Esto depende de la ley, del tipo penal.

En principio, si tales movimientos no responden a un plan común no puede haber unidad de conducta. La unidad de plan y unidad de resolución son requisitos para que haya unidad de conducta. Son los configuradores del factor final de la unidad de sentido de la acción a los efectos de la prohibición. Es decir, el criterio de delimitación se obtiene del sentido de los respectivos tipos penales (cfr. autor cit. en *ob y loc. cit.* pp. 858 y ss.).

En idéntico sentido, Jescheck afirma que lo determinante para la delimitación sólo puede ser el sentido de los tipos legales vulnerados en cada caso, tal y como se alcance mediante la interpretación (así con cita de Maurach, en Jescheck Hans Heinrich, *Tratado de Derecho Penal Parte General*, cuarta edición completamente corregida y ampliada. Traducción de José Luis Manzanares Samaniego. Ed. Comares. Granada; España, 1993, p. 649).

En el *sub judice*, los tipos penales en juego tutelan bienes jurídicos diferentes, para el caso de la usurpación es la propiedad, a cuyo tenor la norma prohibitiva subyacente al tipo penal ordenaba al imputado no ingresar a un inmueble ajeno; por su parte, en el encubrimiento el bien jurídico protegido es la administración de justicia cuya actividad en la individualización de los autores y partícipes de delitos o en la recuperación de los objetos puede verse perturbada por el accionar de quien encubre (cfr. Creus Carlos, *Derecho Penal. Parte Especial*. T II, Ed. Astrea, Bs. As. 1995, 5° ed. act., p. 351), siendo la conducta debida formular la denuncia correspondiente cuando se enteró del origen espurio del inmueble y no usar la cosa con el ánimo de beneficiarse.

El encubrimiento, por receptación es un delito instantáneo aunque puede eventualmente tener el carácter de permanente, pues se consuma con la realización de las acciones típicas, esto es cuando el imputado recibe la cosa cuyo origen espurio conoce (cfr. Donna Carlos Alberto, *Derecho Penal Parte*

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

*Especial*, T III, Rubinzal Culzoni, Bs As., 2001, p. 505 y  
Creus, Carlos, ob. cit. p. 551). Lo mismo sucede con la  
usurpación.

En el caso, se descarta, de cara a los hechos  
probados, una unidad de acción, antes bien se observa una  
realidad empírica plural consistente en dos comportamientos  
independientes y escindibles entre sí guiados cada uno por un  
dolo diferente, que lesionaron distintos bienes jurídicos.

Al respecto cabe aclarar que no resulta plausible  
predicar del accionar del imputado que las múltiples y  
heterogéneas lesiones de bienes jurídicos que, en el caso,  
claramente se manifiestan como una pluralidad delictiva, deban  
ser consideradas como un concurso ideal en atención a la  
eficacia unificadora que confiere la unidad de voluntad y  
designio del autor. En esos supuestos, el autor, si bien realiza  
actos plurales, en realidad persigue la comisión de un único  
hecho delictivo o plan común.

En el *sub iudice* no se advierte que las conductas  
atribuidas a Carlos de Cándido hayan respondido a una decisión y  
a un plan comunes, por lo que no es dable predicar unidad de  
conducta.

Es decir, no se aprecia que el antes mentado haya  
usurpado la propiedad ajena guiado por el designio primigenio de  
encubrir la desaparición forzada de sus legítimos propietarios

o, viceversa, que haya estado en su plan inicial el dolo de encubrir la desaparición forzada para quedarse finalmente con la vivienda de la familia Coronel.

Antes bien, se verifican, como expresé *supra*, dos conductas diversas, e independientes que fueron guiadas por distintos motivos y finalidades y afectaron diferentes bienes jurídicos, por lo que devienen escindibles entre sí cobrando independencia fáctica que debe ser resuelta a la luz del art. 55 del CP.

Por tanto, considero que Carlos Esteban De Cándido es autor materialmente responsable de los delitos de encubrimiento en concurso real con usurpación por el que ya viene condenado, en el marco de delitos de lesa humanidad (arts. 181, 277 y 278 texto según ley 21.338 y 55 del C.P).

Como consecuencia de ello cabe realizar una nueva determinación punitiva.

A tal efecto, después de haber oído al imputado en audiencia de *visu* (conf. nuevamente doctrina de Fallos "NIZ" de la CSJN), teniendo a la vista el legajo de personalidad del mentado y, toda vez que no se advierten atenuantes en su conducta aunado a la magnitud de los hechos cometidos al amparo de la dictadura represiva de la época, considero que debe imponérsele la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo –monto éste solicitado por el fiscal durante el juicio al cual se remitió posteriormente en su recurso de casación– más accesorias legales y costas.

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

3) En su libelo recursivo el representante del Ministerio Público Fiscal se agravió de la falta de consideración del pedido de pérdida definitiva del grado militar de Luciano Benjamín Menéndez.

Advierto que esta cuestión es una reedición del planteo formulado por el fiscal de juicio en la oportunidad del art. 393 del CPPN.

En efecto, conforme surge de fs. 25.599 vta., observo que en el epílogo de su alegato sostuvo que "por las razones apuntadas, las pruebas aportadas y las constancias de autos, solicita para Luciano Benjamín Menéndez cuyas demás condiciones personales constan en autos la pena de prisión perpetua, e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, pérdida definitiva del grado militar, la baja de las fuerzas Armadas y la imposibilidad de readquirir estado militar (arts. 13, inc. 23, 14 y 19 de la ley 26394) y costas".

Como es dable apreciar de lo reeditado *supra*, dicha petición fue oportunamente introducida por el representante de la vindicta pública empero fue desatendida por el tribunal de mérito al momento de dictar sentencia.

Y si bien, como es sabido, los judicantes no deben seguir a las partes en todas las alegaciones sino sólo respecto de aquéllas que estimen conducentes para una correcta dilucidación del caso, la pretensión del fiscal resultaba

relevante a dicho fin.

De tal modo, la resolución recurrida que no aborda tal planteo, siquiera mínimamente, prescindiendo del examen de una cuestión oportunamente propuesta por la parte, exhibe en este punto una incongruencia omisiva que vicia la fundamentación del fallo (art. 404 inc. 2 del CPPN).

Por razones de economía procesal y más pronta administración de justicia se impone la respuesta definitiva en esta sede no sin antes advertir que la defensa ha tenido oportunidad de confutar las alegaciones del acusador con lo que se encuentra preservado el principio de contradicción y con él la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18 de la C.N).

No cabe hesitación alguna que la naturaleza y duración de la pena inflicta a Luciano Benjamín Menéndez conduce a la imposición de las sanciones accesorias que se encuentran previstas tanto en el artículo 12 del Código Penal como en la legislación especial.

Conforme surge del tenor literal del art. 12 del CP *“la reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado*

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa Nº 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De Cándido  
Carlos y Menéndez  
Luciano s/ rec. de  
casación".  
Sala III C.N.C.P.

*quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces".*

Así la inhabilitación absoluta se erige como inherente a la reclusión o prisión por más de tres años y por ende funciona como accesoria -no complementaria, huelga aclarar- de la pena privativa de libertad que se imponga.

Cabe asimismo considerar la normativa vinculada con el régimen disciplinario de los militares que incurran en alguna falta de conducta.

Deviene aplicable a la especie, dada su mayor benignidad, la nueva ley 26.394 (BO 29/8/08) que derogó el Código de Justicia Militar (ley 14.029), específicamente el Anexo IV "Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas".

Al recalar en esta normativa se advierte que el art. 13 alude a los tipos de faltas gravísimas. Así, establece que constituyen faltas gravísimas las allí enunciadas, entre las que se encuentra en el inciso 23), la que aquí atañe. Dicha norma reza: "Comisión de un delito. El militar que con motivo o en ocasión de su funciones militares, o dentro de un establecimiento militar o en lugares asignados al cumplimiento de tareas militares, cometiere un hecho que pudiera constituir un delito previsto en el Código Penal o en leyes especiales cuya pena máxima sea superior a un año".

La consecuencia jurídica prevista para este tipo de

falta de encuentra establecida en el art. 14 punto 4. *ibídem* y consiste en la destitución, revistiendo ésta el carácter de pena mayor. Ella implica la pérdida definitiva del grado, la baja de las fuerzas armadas y la imposibilidad de readquirir estado militar (cfr. art. 19 *ibidem*).

El imputado ha sido condenado a prisión perpetua por haber sido declarado penalmente responsable de la comisión de delitos de lesa humanidad durante el desempeño de sus funciones militares, es decir, actuó en franca rebelión contra la Ley Suprema. Ergo, no puede seguir ostentando el grado de General de la Nación ni estado militar.

En virtud de lo expuesto, cabe acoger favorablemente el agravio del casacionista, debiéndose remitir copia de la presente al Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de que se aplique a Luciano Benjamín Menéndez, la respectiva pérdida definitiva del grado, su baja de las Fuerzas Armadas y la imposibilidad de readquirir el estado militar.

4) Cabe abordar ahora la crítica del casacionista relativa a la falta de declaración expresa de que los delitos atribuidos a Menéndez; Albornoz y De Cándido, además de ser delitos de lesa humanidad configuran el tipo de derecho penal internacional de genocidio.

Con relación al agravio en trato, cabe señalar que más allá de la controversia suscitada en la doctrina respecto de si los hechos de terrorismo de Estado ocurridos en nuestro país durante la dictadura militar (entre los que se encuentran las

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

conductas objeto de las presentes actuaciones) encuadran, o no, en la categoría de "genocidio" prevista en el art. II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y en el art. 7º del Estatuto de Roma, lo cierto es que no corresponde que la referida cuestión sea resuelta en esta instancia. Ello así, por cuanto la circunstancia de que el tribunal *a quo* no haya incluido, dentro de la calificación legal asignada a los hechos sobre los que se dictó condena en el pronunciamiento atacado, la **declaración** de que esos hechos encuadran en la referida categoría –repárese que el propio fiscal admite que la inclusión de genocidio sería meramente declarativa–, no produjo efectos jurídicos concretos respecto de la situación de los condenados; de lo que se deriva que el acierto o error de dicha declaración no importe una cuestión susceptible de ser analizada por esta Cámara Federal de Casación Penal.

En efecto, se advierte que las consecuencias jurídicas que permitieron el juzgamiento de las conductas reprochadas a los imputados en el debate oral que culminó con el dictado del decisorio puesto en crisis –como la imprescriptibilidad– se derivaron de haberse considerado que los hechos encuadraban en la categoría de "crímenes de lesa humanidad" prevista en el art. 7 del Estatuto de Roma. Por ende, el eventual agregado de la

referencia al "delito internacional de genocidio" —que no reemplaza a la tipificación como delito de lesa humanidad, sino que se suma a ella— no vendría a modificar la situación legal de los encartados, que se mantendría inalterada.

En ese orden de ideas, cabe recordar *"Que desde sus inicios, al examinar la naturaleza de la actividad jurisdiccional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que [...] los jueces sólo pueden pronunciarse respecto de un caso concreto; y no pueden hacer declaraciones en abstracto o de carácter general"* (Fallos: 306:1125 y sus citas). Ello, toda vez que es de la *"...esencia del poder judicial decidir colisiones efectivas de derechos"*, razón por la cual no compete a los jueces de la Nación *"hacer declaraciones generales o abstractas"* (Fallos: 2:254; 12:372; 24:248; 94:444; 107:179; 115:163; 193:524, entre muchos otros). Siendo que, por consiguiente, no se consideran como cuestiones justiciables las consultas y **las resoluciones puramente normativas** (Fallos 28:404; 32:62; 52:432; 100:205; 188:179, entre muchos otros; cfr. Imaz, Esteban / Rey, Ricardo E., *El recurso extraordinario*, Ediciones de la Revista de Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 1943, pág. 40 y ss. —énfasis añadido), deviene insustancial el tratamiento del agravio deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal en orden a esta cuestión.

Habida cuenta de las consideraciones expuestas en los dos últimos acápites postulo al acuerdo hacer lugar recurso de

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

casación promovido por el fiscal, sin costas (arts. 470, 471, 530 y 531 del CPPN) y rechazar *in totum* el recurso de casación promovido por la Defensa Oficial de Carlos Esteban de Cándido y Luis Armando De Cándido, con costas (arts. 470 y 471 a *contrario sensu*, 530 y 531 del CPPN).

**IV-Colofón**

En virtud de lo expuesto, propongo al acuerdo:

**I**-Hacer lugar al recurso de casación promovido por el fiscal con el alcance referido, sin costas en la instancia, casar parcialmente los puntos dispositivos **IX** y **X** de la sentencia impugnada (arts. 470, 530 y 531 del CPPN) y en definitiva:

**I-a.** Condenar a Luis Armando De Cándido, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por ser coautor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita agravada (art. 210 *bis* del Código Penal según ley n° 21.138) autor material penalmente responsable del delito de violación del domicilio de calle Chacabuco N° 476/478 de San Miguel de Tucumán (art. 151 Código Penal) en concurso ideal (art. 54 Código Penal) con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada (arts. 144 bis y 142 inc. 1º del Código Penal) en perjuicio de Marta y Rolando Coronel; homicidio agravado por

alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y para lograr la impunidad (art. 80 incs. 2, 6 y 7 del CP, texto según ley nº 21.338) en perjuicio de Marta Coronel y Rolando Coronel; usurpación (art. 181 del Código Penal) del inmueble de calle Chacabuco nº 476/478 de San Miguel de Tucumán; todo en concurso real (art. 55 del Código Penal) calificándolos como delitos de lesa humanidad (arts. 12, 19, 29 inc 3º, 40 y 41 del Código Penal; arts. 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación).

**I-b.** Condenar a Carlos Esteban De Cándido, a la pena de cuatro (4) años de prisión de efectivo cumplimiento, e inhabilitación absoluta y accesorias legales por igual tiempo de la condena, y costas, por considerarlo autor material penalmente responsable de la comisión del delito de usurpación (art. 181 del Código Penal) del inmueble de calle Jujuy nº 1062 de San Miguel de Tucumán, de propiedad de Rolando Coronel en concurso real con el delito de encubrimiento (arts. 277 y 278 texto según ley 21.338 y 55 del Código Penal); calificándolos como delitos de lesa humanidad (arts. 12, 29 inc. 3º, 40 y 41 del Código Penal; arts. 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación).

**II-a.** Rechazar los recursos de casación promovidos por las defensas de Luciano Benjamín Menéndez, Roberto Heriberto Albornoz, Luis Armando de Cándido y Carlos De Cándido, con

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

costas (arts. 470 y 471 a *contrario sensu*, 530 y 531 del CPPN).

**II-b.** Homologar las condenas impuestas a Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz fijadas en los puntos **VII** y **VIII**, respectivamente, de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Tucumán.

**III-** Remitir copia de la presente al Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de que se aplique a Luciano Benjamín Menéndez, la respectiva pérdida definitiva del grado, su baja de las Fuerzas Armadas y la imposibilidad de readquirir el estado militar.

**IV-** Disponer la prohibición de salida del país de Carlos Esteban De Cándido (arts. 280 y 310 del CPPN) que deberá comunicarse a la instancia anterior para que arbitre los medios a su alcance para hacerla efectiva.

**V-** Tener presente las reservas del caso federal.

El señor juez doctor **Eduardo Rafael Riggi** dijo:

Que habremos de acompañar en sustancia los lineamientos del voto del distinguido colega que lleva la voz de este Acuerdo, doctor Mariano Hernán Borinsky, sin perjuicio de formular algunas salvedades relacionadas con los planteos traídos a estudio de este Tribunal.

**I.-Respecto del recurso de casación interpuesto por la defensa de Luciano Benjamín Menéndez.**

En relación al planteo efectuado por la asistencia técnica del nombrado, referido a la prescripción de los delitos de lesa humanidad, en lo sustancial nos remitimos a cuanto sostuvo esta Sala, con su integración anterior, al resolver en las causas n°6716 "Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/recurso de casación", resuelta el 9 de mayo de 2007, registro n° 469/07; y n° 9896 "Menéndez Luciano Benjamín y otros s/recurso de casación", resuelta el 25 de agosto de 2010, registro n° 1253/10.

En tal sentido, cabe señalar que las cuestiones sometidas a inspección jurisdiccional de esta Cámara guardan identidad con aquéllas que fueran motivo de decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación *in re* "Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad" (Fallos 328:2056), pronunciamiento que habremos de acatar pues emana del Más Alto Tribunal de la Nación, último intérprete de la Constitución Nacional.

Asimismo, nuestros anteriores decisorios siguen también los lineamientos generales de nuestros votos en las causas n° 1975, "Olivares Cusin, Oscar Genaro s/ recurso de casación", registro n° 168, del 16 de abril de 1999, n° 4839, "Guzmán, José Marcelo y otros s/recurso de casación", registro n° 101/04 del 11 de marzo de 2004 y n° 4804, "Sandoval, Orlando Rafael y otro s/recurso de casación", registro n° 154/04 del 19 de mayo de 2004 -entre muchas otras-, oportunidades en las que

invariablemente hemos sostenido la necesidad de que los tribunales inferiores acaten la doctrina que surge de los precedentes emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio de hacer reserva de nuestra opinión discordante, pues coincidimos con los fundamentos vertidos por el Sr. Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Carlos S. Fayt, en el citado fallo "Simón".

Con relación al resto de los agravios deducidos por la asistencia técnica del acusado, nos remitimos al profuso análisis del colega preopinante.

**II. Recurso de casación interpuesto por la defensa de Roberto Heriberto Albornoz.**

En primer lugar, debemos destacar que el recurso de casación interpuesto por la defensa de Roberto Heriberto Albornoz, contra el punto XI) de la sentencia puesta en crisis en cuanto dispusiera la revocatoria de su prisión domiciliaria, ha devenido abstracto, en virtud de lo resuelto por esta Sala III, con distinta integración, en la causa 13.251 caratulada "Albornoz, Roberto Heriberto y De Candido Luis Armando s/recurso de casación", del 16 de febrero de 2011, reg. 81/11, que a la fecha se encuentra firme.

En relación al resto de la impugnación deducida, apreciamos que el doctor Mariano H. Borinsky, en el considerando

**TERCERO punto II**, ha brindado una acabada respuesta a cada uno de los cuestionamientos trazados por la defensa, lo cual, entonces, nos exime de realizar esa tarea. Por ello, también adherimos a cuanto allí se propone.

**III. Recursos de casación de la defensa de Luis Armando de Candido y Carlos Alberto de Candido y del Ministerio Público Fiscal.**

**a.**Al igual que el caso anterior, el recurso de casación deducido por la defensa de Luis Armando De Candido en torno al punto XIII) del fallo que disponía la inmediata detención del nombrado, ha devenido abstracto, dado lo resuelto *in re* “Albornoz, Roberto Heriberto y De Candido Luis Armando s/recurso de casación”, el 16 de febrero de 2011, ya citado.

**b.**Por lo demás, las plurales consideraciones vertidas por el colega preopinante en los puntos **III y IV** del considerando TERCERO -a cuyos fundamentos corresponde remitirse a fin de evitar repeticiones inútiles-, permiten descartar aquellos agravios vertidos por la asistencia técnica de Luis Armando De Candido y Carlos Alberto De Candido contra la sentencia impugnada, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto, con costas.

**c.**También habremos de acompañar la modificación de las calificaciones legales que, para los hechos probados respecto de Luis Armando De Candido y Carlos Alberto De Candido, auspicia el

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

doctor Mariano H. Borinsky, de conformidad con el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal.

Ello así, pues, respecto de Luis Armando De Candido, ha quedado comprobado que formó parte del grupo de tareas que ingresó al domicilio donde se encontraban Marta y Rolando Coronel, que procedió a su secuestro y en forma concomitante a sus torturas, como asimismo, que los nombrados continúan aún desaparecidos y estaban identificados con la sigla DF – "disposición final" que implicaba la eliminación del sujeto–, por lo cual debe necesariamente responder por sus homicidios de la manera en que lo propone el colega preopinante.

Por su parte, y en relación a la situación de Carlos Alberto De Candido, al haberse comprobado que tomó posesión del inmueble de la calle Jujuy 1062 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, propiedad de Rolando Coronel, quien fuera objeto de secuestro, tortura y muerte, en el marco de la represión ilegal comprobada, no sólo convierte a la usurpación de la vivienda así pergeñada en un delito de lesa humanidad, sino que además califica su conducta en el tipo de encubrimiento, en la medida en que, en su calidad de funcionario policial, no podía desconocer el origen espúreo del bien y se encontraba obligado a denunciar hechos de tales características.

Por ello, compartimos la nueva calificación legal

propuesta por el doctor Borinsky (usurpación en concurso real con encubrimiento, delitos calificados como de lesa humanidad). También entendemos adecuada la pena de 4 años de prisión que postula.

**d.** Sí habremos de disentir con la prohibición de salida del país que el distinguido colega sugiere que se imponga al imputado Carlos De Candido en esta Alzada, pues entendemos que corresponde en su caso al tribunal de grado evaluar cuáles son las medidas procesales idóneas para asegurar el sometimiento del imputado al proceso.

**e.** Tampoco habremos de acompañar la pretensión del Ministerio Público Fiscal de disponer la pérdida del grado militar del acusado Menéndez, pues una resolución de esa naturaleza escapa a la competencia de esta Alzada en la medida en que resulta resorte exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional y sus órganos con competencia para ello (art. 99 incisos 12 y 14 de la Constitución Nacional y art. 35 y concordantes de la ley 26.394). Tan es así que, por lo demás, dicha pérdida y la consecuente baja de las fuerzas Armadas fue dispuesta efectivamente mediante la resolución 408/2011 del Ministerio de Defensa de la Nación; desde ésta última perspectiva, incluso, el agravio deviene abstracto.

**f.** Finalmente, consideramos ajustado el rechazo del agravio esgrimido por el Ministerio Público Fiscal en cuanto

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

solicita que se califiquen los hechos también como constitutivos del delito de "genocidio", pues excede la competencia de los tribunales de justicia la pretensión que implica solicitar que se emita una declaración general, un pronunciamiento abstracto o meramente académico sobre la norma penal aplicada. En razón de las condenas impuestas en el caso concreto, la pretensión del recurrente deviene insustancial.

**IV.** Por todo lo expuesto, **con las salvedades realizadas en los puntos "d" y "e"**, apartado **"IV"**, adherimos al voto del doctor Mariano H. Borinsky y emitimos el nuestro en idéntico sentido.

Tal es nuestro voto.

La señora juez **doctora Liliana E. Catucci** dijo:

**A-**Que para dar respuesta a los planteos traídos en primer término por la defensa del acusado Luciano Menéndez, he de remitirme en lo pertinente a los lineamientos que he dejado expuestos en las causas n° 7758 "Simón, Julio Héctor s/recurso de casación", rta. el 15/5/07, n° 7896, "Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/recurso de casación e inconstitucionalidad", rta. el 18/5/07, reg. 10488 -ambas de la Sala I-, n° 9803 "Paccagnini, Rubén Roberto s/recurso de casación", rta. el 4/12/09, reg. 1782 y n° 9896 "Menéndez Luciano Benjamín y otros s/recurso de casación", rta. el 25/8/10, reg. 1253 de esta Sala.

**B**-En lo que hace a las restantes cuestiones puntuales planteadas por la defensa del nombrado y de los demás acusados, como así también por el Fiscal General, adhiero al voto del doctor Mariano Borinsky con las salvedades expuestas por el doctor Eduardo Riggi, a excepción de lo atinente a la situación de Carlos De Candido.

Comparto lo señalado por mis distinguidos colegas en cuanto a que su responsabilidad por el hecho imputado ha sido fehacientemente probada por el Tribunal de Juicio y, por ende, está fuera de discusión, como así también que la conducta del nombrado debe subsumirse en las figuras penales precisadas en las plurales consideraciones efectuadas en el voto del doctor Mariano Borinsky. Sin embargo, disiento en la forma en que dichas normas se enlazan.

En ese aspecto, entiendo que esos delitos de encubrimiento y usurpación concurren idealmente, tal como lo establece el artículo 54 del Código Penal, pues se da en el caso la hipótesis de un hecho que cae bajo más de una sanción penal.

Se ha descripto acertadamente que *"Existe concurso ideal cuando un hecho concreta dos o más figuras penales que no se excluyen entre sí* (MEZGER, *tratado*, T. 11, § 69, II; BINDING, *Grundriss*, A. T, § 60, pág. 129; MAURACH, R., lo considera una unidad de acción con pluralidad de tipos, *Tratado*, T. 11, § 55, I, A). La apariencia de multiplicidad delictiva que ofrece el

concurso ideal se debe a que el autor ha incurrido en la violación de varias disposiciones penales, mereciendo por esto más de una calificación delictuosa. Pero, a esa aparente pluralidad, corresponde una unidad real de la delincuencia atribuible al mismo (NÚÑEZ, *Derecho Penal*, T. 11, pág. 205). Es decir, que lo plural es la adecuación típica, mas no la conducta punible" —FONTAN BALESTRA, Carlos, *Derecho Penal, Introducción y Parte general*, actualizado por Guillermo A. C. Ledesma, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1998, pág. 443-.

En ese orden, a Carlos De Candido se le imputa una única acción humana: la ocupación ilícita de la vivienda de referencia llevada a cabo en un contexto conocido por el acusado y reseñado en el fallo que determinó que se lo calificara acertadamente como de lesa humanidad.

Tal conducta humana, única e indivisible, se subsume en las distintas figuras penales analizadas en el voto que lidera el acuerdo de modo de imponerse la forma concursal propuesta.

El enlace material se descarta a partir de que presupone la existencia de "*varios hechos independientes constitutivos cada uno de ellos de un delito*" —*ibid*— circunstancia que no se da en el caso. Por otra parte, la falta de desplazamiento de una figura por otra, determina la inaplicabilidad del concurso de leyes o aparente.

Establecido el punto y de acuerdo a la escala penal prevista para los delitos tratados, entiendo acertada la pena de tres años impuesta en el fallo por ser el máximo previsto para ambas figuras aplicables.

Sin embargo y siguiendo el propio criterio del Tribunal de Juicio en tanto consideró que se trataba de un delito de lesa humanidad con la extrema gravedad que ello implica según la actual e invariable jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cumplimiento ha de ser efectivo.

Tal es mi voto.

Por ello, en mérito al resultado habido en el acuerdo que antecede, el Tribunal, **RESUELVE:**

**I-**Hacer lugar al recurso de casación promovido por el fiscal con el alcance referido, sin costas en la instancia, casar parcialmente los puntos dispositivos **IX** y **X** de la sentencia impugnada (arts. 470, 530 y 531 del CPPN) y en definitiva:

**I-a.** Condenar a Luis Armando De Cándido, elevando la pena impuesta a la de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por ser coautor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita agravada (art. 210 *bis* del Código Penal según ley n° 21.138) autor material penalmente responsable del delito de violación del domicilio de calle Chacabuco N° 476/478 de San

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
"Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación".  
Sala III C.N.C.P.

Miguel de Tucumán (art. 151 Código Penal) en concurso ideal (art. 54 Código Penal) con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada (arts. 144 bis y 142 inc. 1º del Código Penal) en perjuicio de Marta y Rolando Coronel; modificándose la calificación legal de torturas seguida de muerte por la de homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y para lograr la impunidad (art. 80 incs. 2, 6 y 7 del CP, texto según ley n° 21.338) en perjuicio de Marta Coronel y Rolando Coronel; usurpación (art. 181 del Código Penal) del inmueble de calle Chacabuco n° 476/478 de San Miguel de Tucumán; todo en concurso real (art. 55 del Código Penal) calificándolos como delitos de lesa humanidad (arts. 12, 19, 29 inc 3º, 40 y 41 del Código Penal; arts. 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación).

**I-b.** Condenar, por mayoría, a Carlos Esteban De Cándido, a la pena que se eleva a cuatro (4) años de prisión de efectivo cumplimiento, e inhabilitación absoluta y accesorias legales por igual tiempo de la condena, y costas, por considerarlo autor material penalmente responsable de la comisión del delito de usurpación (art. 181 del Código Penal) del inmueble de calle Jujuy n° 1062 de San Miguel de Tucumán, de propiedad de Rolando Coronel y del delito de encubrimiento aquí tipificado en concurso real (arts. 277 y 278 texto según ley

21.338 y 55 del Código Penal); calificándolos como delitos de lesa humanidad (arts. 12, 29 inc. 3º, 40 y 41 del Código Penal; arts. 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación).

**II-a.** Rechazar los recursos de casación promovidos por las defensas de Luciano Benjamín Menéndez, Roberto Heriberto Albornoz, Luis Armando de Cándido y Carlos De Cándido, con costas (arts. 470 y 471 a *contrario sensu*, 530 y 531 del CPPN).

**II-b.** Homologar las condenas impuestas a Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz fijadas en los puntos **VII** y **VIII**, respectivamente, de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Tucumán.

**III-** No hacer lugar, por mayoría, a la pretensión del Ministerio Público Fiscal de que se aplique a Luciano Benjamín Menéndez, la respectiva pérdida definitiva del grado, su baja de las Fuerzas Armadas y la imposibilidad de readquirir el estado militar.

**IV-** Tener presente las reservas del caso federal.

Regístrese, notifíquese y remítanse las actuaciones al tribunal que las elevó sirviendo la presente de atenta nota de envío.

*Cámara Federal de Casación Penal*

Causa N° 13.085/13049  
“Albornoz, Roberto, De  
Cándido Luis, De  
Cándido Carlos y  
Menéndez Luciano s/  
rec. de casación”.  
Sala III C.N.C.P.

Fdo: Dres. Eduardo R. Riggi – Liliana E. Catucci – Mariano  
H. Borinsky. Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin.  
Secretaria de Cámara.